

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 A시 시장 甲은 1990년에 자연공원법 에 의하여 A시내 산지 일대 5 k m²를 'X시립공원'으로 지정·고시한 다음, 1992년에 X시립공원 구역을 구분하여 용도지구로 지정하는 내용의 'X시립공원 기본계획'을 결정·공고하였다. 甲은 2017년에 X시립공원 구역 내 10,000 m² 부분에 다목적광장 및 휴양관(이하 '이 사건 시설'이라 한다)을 설치하는 내용의 'X시립공원 공원계획'을 결정·고시한 다음, 2018년에 甲이 사업시행자가 되어 이 사건 시설에 잔디광장, 휴양관, 도로, 주차장을 설치하는 내용의 'X시립공원 공원사업'(이하 '이 사건 시설 조성사업'이라 한다) 시행계획을 결정·고시하였다. 甲은 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위하여 그 사업구역 내에 위치한 토지(이하 '이 사건 B토지'라 한다)를 소유한 乙과 손실보상에 관한 협의를 진행하였으나 협의가 성립하지 않자 수용재결을 신청하였다. 乙이 소유하고 있는 토지(이하 '이 사건 B토지'라 한다)는 문화재보호법 상 보호구역으로 지정된 토지로서 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위한 사업구역 내에 위치하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (45점) -31회 1번 변형

물음 1) 국가 이외의 자가 수용권자인 경우 수용권의 주체를 논하시오. (10점)

물음 2) 甲은 공물인 이 사건 B토지를 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위하여 수용할 수 있는가? (15점)

물음 3) 한편, 丙이 소유하고 있는 토지(이 사건 C토지라 한다)는 일부만 사업구역 내에 위치하고 있다. 丙은 잔여토지를 종래 목적대로 사용할 수 없다고 잔여지 수용을 주장한다. 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상의 확장수용을 설명하고, 확장수용청구가 거부된 경우 그 불복방법을 논급하시오. (20점)

【문제 2】 토지보상법상 공익사업준비를 위한 타인토지출입에 대하여 설명하고, 토지소유자가 토지출입을 거부하는 경우 사업시행자가 이를 실력으로 배제할 수 있는지, 그리고 토지점유자에게 사전통지없이 측량조사를 한 경우(단, 내용상 하자는 없다) 그러한 측량조사에 근거하여 이루어진 사업인정의 효력에 대해서 논하시오.(25점)

【문제 3】 공용수용의 내용상 요건에 대해 설명하고, 공공수용과 공공필요의 관계에 대해 설명하시오. (20점)

【문제 4】 사적(私的) 공용수용에 대하여 설명하시오.(10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 국토부장관은 2013. 11. 18. 사업시행자를 'A공사'로, 사업시행지를 'X시 일대 8,958,000㎡'로, 사업시행기간을 '2013. 11.부터 2017. 12. 까지'로 하는 '◇◇공구사업'에 대해서 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정을 고시하였고, 사업시행기간은 이후 '2020. 12.까지'로 연장되었다. 甲은 ㉠토지 78,373㎡와 ㉡토지 2,334㎡를 소유하고 있는데, ㉠토지의 전부와 ㉡토지의 일부가 사업시행지에 포함되어 있다. 종래 甲은 ㉠토지에서 하우스 딸기농사를 지어 왔고, ㉡토지에서는 농작물직거래판매장을 운영하여 왔다. 甲과 A공사는 사업시행지 내의 토지에 대해 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」에 따른 협의 매수를 하기 위한 협의를 시작하였다. 다음 물음에 답하시오.(아래의 물음은 각 별개의 상황임)(30점)

물음 1) 토지보상법상 사업인정 전 협의 취득 절차에 대해 설명하시오. (10점)

물음 2) 토지보상법상 사업인정 전 협의와 사업인정 후 협의를 비교하라. (10점)

물음 3) 토지보상법상 사업인정고시의 효과에 대해 설명하시오. (10점)

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 (약칭: 토지보상법)>

제16조(협의) 사업시행자는 토지등에 대한 보상에 관하여 토지소유자 및 관계인과 성실하게 협의하여야 하며, 협의의 절차 및 방법 등 협의에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2011. 8. 4.]

제26조(협의 등 절차의 준용) ① 제20조에 따른 사업인정을 받은 사업시행자는 토지조서 및 물건조서의 작성, 보상계획의 공고·통지 및 열람, 보상액의 산정과 토지소유자 및 관계인과의 협의 절차를 거쳐야 한다. 이 경우 제14조부터 제16조까지 및 제68조를 준용한다.

② 사업인정 이전에 제14조부터 제16조까지 및 제68조에 따른 절차를 거쳤으나 협의가 성립되지 아니하고 제20조에 따른 사업인정을 받은 사업으로서 토지조서 및 물건조서의 내용에 변동이 없을 때에는 제1항에도 불구하고 제14조부터 제16조까지의 절차를 거치지 아니할 수 있다. 다만, 사업시행자나 토지소유자 및 관계인이 제16조에 따른 협의를 요구할 때에는 협의하여야 한다. [전문개정 2011. 8. 4.]

제20조(사업인정) ① 사업시행자는 제19조에 따라 토지등을 수용하거나 사용하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

② 제1항에 따른 사업인정을 신청하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 수수료를 내야 한다. <개정 2013. 3. 23.> [전문개정 2011. 8. 4.]

제22조(사업인정의 고시) ① 국토교통부장관은 제20조에 따른 사업인정을 하였을 때에는 지체 없이 그 뜻을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인, 관계 시·도지사에게 통지하고 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

② 제1항에 따라 사업인정의 사실을 통지받은 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)는 관계 시장·군수 및 구청장에게 이를 통지하여야 한다.

③ 사업인정은 제1항에 따라 고시한 날부터 그 효력이 발생한다.

[전문개정 2011. 8. 4.]

【문제 2】 (1) 특수전사령부 및 제3공수특전여단 이전사업의 사업부지에 속하는 이천시 (주소 생략) 전 1,319㎡(이하 '이 사건 토지'라 한다)에 관하여는 2009. 8. 6. 사업시행자인 한국토지주택공사와 그 소유권보존등기 명의인인 피고보조참가인(이하 '참가인'이라 한다) 사이에 토지보상법에 따른 토지 취득에 관한 협의가 성립되었다.

(2) 한국토지주택공사는 토지보상법 제29조 제3항에 따라 이 사건 토지의 등기부상 소유명의인인 참가인의 동의를 받고 한국토지주택공사와 참가인 사이의 매매계약서, 협의성립확인신청 동의서, 토지조서 및 보상금지급서류 등에 공증을 받아 피고(중앙토지수용위원회)에게 이 사건 토지에 관한 협의 성립의 확인을 신청하였고 피고는 2015. 3. 26. 이를 수리하였다(이하 '이 사건 처분'이라 한다).

(3) 한편 이 사건 토지에 관한 농지분배 관련 서류들, 즉 분배대상 농지를 확인하는 농지분배부, 상환에 필요한 사항을 기재하는 상환대장, 농지를 국가에 매수당한 지주가 보상을 받는 과정에서 작성된 보상신청서, 지주신고서, 지가사정조서에는 '서울특별시 ○○동' 또는 '서울특별시 중구 ○○동△△'에 주소를 둔 소외인이 그 소유자로 기재되어 있고, 한자부책식 구 토지대장에는 '서울특별시 □□□□가'에 주소를 둔 소외인이 이 사건 토지를 사정받았다고 기재되어 있다. 원고의 부(父)인 소외인의 본적지는 '서울특별시 중구 □□□□가◇◇'이고, 소외인은 '서울특별시 중구 ○○동△△'에서 사망하였다. (즉, 원고는 진정한 소유자의 상속인이다) 다음 물음에 답하십시오. (30점)

물음 1) 협의성립확인의 절차에 대해 설명하십시오. (10점)

물음 2) 협의 성립 확인 신청에 필요한 동의 요건과 위 사안의 동의 흠결에 대해 설명하십시오. (5점)

물음 3) 동의에 흠결이 있는 협의성립확인 신청에 대해 토지수용위원회가 수리한 경우 그 수리의 위법성과 당해 수리를 항고소송으로 취소를 구할 수 있는지 설명하십시오. (15점)

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 (약칭: 토지보상법)>

제29조(협의 성립의 확인) ① 사업시행자와 토지소유자 및 관계인 간에 제26조에 따른 절차를 거쳐 협의가 성립되었을 때에는 사업시행자는 제28조제1항에 따른 재결 신청기간 이내에 해당 토지소유자 및 관계인의 동의를 받아 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용위원회에 협의 성립의 확인을 신청할 수 있다.

② 제1항에 따른 협의 성립의 확인에 관하여는 제28조제2항, 제31조, 제32조, 제34조, 제35조, 제52조제7항, 제53조제5항, 제57조 및 제58조를 준용한다. <개정 2023. 4. 18.>

③ 사업시행자가 협의가 성립된 토지의 소재지·지번·지목 및 면적 등 대통령령으로 정하는 사항에 대하여 「공증인법」에 따른 공증을 받아 제1항에 따른 협의 성립의 확인을 신청하였을 때에는 관할 토지수용위원회가 이를 수리함으로써 협의 성립이 확인된 것으로 본다.

④ 제1항 및 제3항에 따른 확인은 이 법에 따른 재결로 보며, 사업시행자, 토지소유자 및 관계인은 그 확인된 협의의 성립이나 내용을 다툴 수 없다.

[전문개정 2011. 8. 4.]

【문제 3】 국토부장관은 2013. 11. 18. 사업시행자를 'A공사'로, 사업시행지를 'X시 일대 8,958,000㎡'로, 사업시행기간을 '2013. 11.부터 2017. 12. 까지'로 하는 '◇◇공구사업'에 대해서「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정을 고시하였고, 사업시행기간은 이후 '2020. 12.까지'로 연장되었다. 사업시행지 내 피수용자 甲과 A공사는 사업시행지 내의 토지에 대해 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」에 따른 협의 매수를 하기 위한 협의를 시작하였다. 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 별개의 상황임) (30점)

물음 1) 사업인정 후 당사자 간 협의가 불성립한 경우 사업시행자와 피수용자가 할 수 있는 행위로, 토지보상법상 인정되는 절차를 설명하시오. (15점)

물음 2) 협의 과정에서 일부 지장물에 관하여 협의가 이루어지지 않아 甲이 A공사에게 재결신청을 청구했으나 A공사가 재결신청을 하지 않는 경우, 甲의 불복 방법에 관하여 검토하시오. (15점)

【문제 4】 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률상 사업인정의 실효제도를 설명하고, 이로 인하여 불이익을 받게 되는 피수용자에게 손실보상 청구권이 있는지 설명하시오. (10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 서울특별시장은 도시관리계획결정에서 정해진 바에 따라 근린공원을 조성하기 위하여 그 사업에 필요한 토지들을 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률의 규정에 의거하여 협의를 거쳐 취득하고자 하였으나 협의가 성립되지 않아 중앙토지수용위원회에 재결을 신청하였다. 중앙토지수용위원회의 수용재결(수용의 개시일 : 2005. 6. 30.)에 따라 서울특별시는 보상금을 지급하고 필요한 토지에 대한 소유권이전등기를 마쳤다. 서울특별시장은 토지를 취득한 후, 6개월간의 공사 끝에 공원을 조성하였다. 공원조성공사가 완료된 후 2년이 지난 뒤에 위 토지를 포함한 그 일대의 토지들이 택지개발예정지구로 지정되었다(고시일 : 2008. 6. 30.) 국토교통부장관에 의하여 택지개발사업의 시행자로 지정된 대한주택공사는 택지개발사업실시계획의 승인을 얻어 공원시설을 철거하고, 그 지상에 임대주택을 건설하는 공사를 시행하고 있다. 이에 공원조성사업을 위해 수용된 토지의 소유자 甲은 2008. 8. 30. 서울특별시에 환매의 의사표시를 하였으나, 서울특별시는 甲에게 환매권이 없다고 하여 수용된 토지를 되돌려 주지 않았다. 이러한 경우에 甲이 소유권 회복을 위해 제기할 수 있는 소송수단 및 그 인용가능성에 대하여 검토하시오. (40점)-19회 1번

[공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률]

제4조(공익사업) 이 법에 따라 토지등을 취득하거나 사용할 수 있는 사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업이어야 한다.

3. 국가나 지방자치단체가 설치하는 청사·공장·연구소·시험소·보건시설·문화시설·공원·수목원·광장·운동장·시장·묘지·화장장·도축장 또는 그 밖의 공공용 시설에 관한 사업

5. 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 또는 국가나 지방자치단체가 지정한 자가 임대나 양도의 목적으로 시행하는 주택 건설 또는 택지 및 산업단지 조성에 관한 사업

【문제 2】 甲은 A시의 관할구역 내 X토지를 소유하고 있다. A시는 그 동안 조선업의 지속적인 발전으로 다수의 인구가 거주하였으나 최근 세계적인 불황으로 인구가 급격하게 감소하고 있다. 국토교통부장관은 A시를 국제관광특구로 발전시킬 목적으로 기업도시개발특별법이 정하는 바에 따라 X토지가 포함된 일단의 토지를 기업도시개발구역으로 지정하고, 개발사업시행자인 乙이 작성한 기업도시개발계획(동법 제24조 제2항에 따른 X토지 그 밖의 수용 대상이 되는 토지의 세부목록 포함. 이하 같다)을 승인·고시하였다. 乙은 협의취득에 관한 제반 절차를 준수하여 X토지에 대한 협의취득을 시도하였으나 甲이 응하지 않았다. 이에 乙은 X토지에 대한 수용재결을 신청하였고 중앙토지수용위원회는 그 신청에 따른 수용재결을 하였다. 다음 물음에 답하시오. (40점)-28회 1번

1) 甲은 기업도시개발계획승인에 대한 취소소송의 제소기간이 도과한 상태에서 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 제21조 제2항에 따른 중앙토지수용위원회 및 이해관계자의 의견청취절차를 전혀 시행하지 않은 채 기업도시개발계획승인이 발급된 것이 위법함을 이유로 수용재결 취소소송을 제기하려고 한다. 甲의 소송상 청구가 인용될 수 있는 가능성에 관하여 설명하시오. (단, 소송요건은 충족된 것으로 본다.) (20점)

2) 甲은 수용재결 취소소송을 제기하면서, 乙이 기업도시개발계획승인 이후에 재정상황이 악화되어 수용재결 당시에 이르러 기업도시개발사업을 수행할 능력을 상실한 상태가 되었음에도 불구하고 수용재결을 한 위법이 있다고 주장한다. 甲의 소송상 청구가 인용될 수 있는 가능성에 관하여 설명하시오. (단, 소송요건은 충족된 것으로 본다.) (10점)

<참조조문>

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 (약칭: 토지보상법)
제34조(재결) ① 토지수용위원회의 재결은 서면으로 한다.

② 제1항에 따른 재결서에는 주문 및 그 이유와 재결일을 적고, 위원장 및 회의에 참석한 위원이 기명날인한 후 그 정본(正本)을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인에게 송달하여야 한다.

[전문개정 2011. 8. 4.]

기업도시개발 특별법 (약칭: 기업도시법)

제14조(토지등의 수용·사용) ① 시행자는 개발구역에서 개발사업을 시행하

기 위하여 필요할 때에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제3조에 따른 토지·물건 또는 권리(이하 "토지등"이라 한다)를 수용 또는 사용(이하 "수용등"이라 한다)할 수 있다.

② 제1항을 적용하는 경우에 수용등의 대상이 되는 토지등의 세부 목록을 제11조제6항에 따라 고시한 때에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다. <개정 2017. 10. 24.>

③ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제28조에 따른 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다. 다만, 제10조제2항에 따라 공동으로 개발사업을 시행하는 경우에는 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보하기 전에도 재결의 신청을 할 수 있다.

④ 재결의 신청은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제23조제1항 및 제28조제1항에도 불구하고 제11조제6항 본문에 따른 개발계획의 고시일부터 4년 이내에 할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아 그 기간을 2년 연장할 수 있다. <개정 2012. 1. 20., 2013. 3. 23., 2015. 6. 22., 2017. 10. 24.>

⑤ 제1항에 따른 토지등의 수용등에 관한 재결의 관할 토지수용위원회는 중앙토지수용위원회가 된다.

⑥ 시행자는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 개발사업의 시행에 필요한 토지등을 제공함으로써 인하여 생활의 근거를 상실하게 되는 자에 대하여 주거단지 등을 조성·공급하는 등 이주대책을 수립·시행하여야 한다.

⑦ 제6항에 따라 수립하는 이주대책에는 이주대상 주민과 협의하여 당초 토지등의 소유 상황과 생업 등을 고려하여 생활대책에 필요한 용지를 대체하여 공급하는 등 대통령령으로 정하는 사항이 포함되어야 한다.

⑧ 시행자는 토지등의 보상 및 이주대책에 관한 업무를 시장·군수에게 위탁할 수 있다. 이 경우 시장·군수는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

⑨ 제8항에 따라 토지등의 보상 및 이주대책에 관한 업무를 위탁받은 시장·군수는 위탁받은 업무를 직접 이행하기 어려운 경우에는 그 업무 중 일부를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제81조제1항

제2호에서 정한 기관에 재위탁할 수 있다.

⑩ 제1항에 따른 토지등의 수용등에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.

[전문개정 2011. 5. 30.]

【문제 3】 A시는 시가지 철도이설사업을 시행하기 위하여 토지보상법 제16조에 따라 주택용지를 협의취득하면서 그에 따른 일체의 보상금을 B에게 지급하였고, B는 해당 주택을 자진철거하겠다고 약정하였다. 토지보상법89조 및 행정대집행법2조의 대집행 요건을 설명하고, B가 자진철거를 하지 않을 경우 B의 주택에 대하여 대집행을 할 수 있는지 판단하시오. (20점)-22회 3번

【문제 4】 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)상 천재지변 시의 토지의 사용(법 38조)과 시급한 토지 사용에 대한 허가(법 39조)를 비교하시오. (10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 甲은 A道서의 일정지역에서 20년 이상 제조업을 운영하여 왔다. A도 지사는 (가칭) 청정자연보호구역의 지정 및 관리에 관한 법률을 근거로 甲의 공장이 포함되는 B지역 일대를 청정자연보호구역으로 지정하였다. 그 결과 B지역 내의 모든 제조업자들은 법령상 강화된 폐수 배출허용기준을 준수하여야 한다. 이에 대해 甲은 변경된 기준을 준수하는 것이 기술적으로 어려울 뿐만 아니라, 수질정화시설을 갖추는 데 과도한 비용이 소요되므로, 이는 재산권의 수용에 해당하는 것으로 손실보상이 주어져야 한다고 주장하다. (30점) - 18회 1번 변형

물음1) 행정상 손실보상이 인정되기 위한 요건에 대해서 서술하시오.(15점)

물음2) 사례와 같은 甲재산권의 규제에 대한 보상규정이 위 법률에 결여되어 있는 경우 甲주장의 타당성을 검토하시오. (15점)

【문제 2】 손실보상에 있어서 사회적 제약과 특별한 희생의 구별기준에 관하여 경계이론과 분리이론의 입장을 설명하시오.(20점) -14회 문2번

【문제 3】 A군에 사는 甲은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 지정된 개발제한구역 내에 과수원을 경영하고 있다. 甲은 영농의 편의를 위해 동 과수원 토지 내에 작은 소로(小路)를 개설하고, 종종 이웃 주민의 통행에도 제공해 왔다. A군은 甲의 과수원 부지가 속한 일단의 토지에 폐기물처리장을 건설하고자 하는 乙을 폐기물관리법에 따라 폐기물처리장 건설사업자로 지정하면서 동 처리장건설사업실시계획을 승인하였다. 甲과 乙간에 甲 토지에 대한 협의매수가 성립되지 않아 乙은 甲 토지에 대한 수용재결을 신청하고, 관할 지방토지수용위원회의 수용재결을 받았다. 동 수용재결에서는 “사실상 사도(私道)의 부지는 인근 토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 평가한다.”고 규정하고 있는 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙(이하 ‘토지보상법 시행규칙’) 제26조 제1항 제2호의 규정에 따라, 甲의 토지를 인근 토지가에 비하여 3분의 1의 가격으로 평가하였다. 이 수용재결에 대하여 이의가 있는 甲은 적절한 권리구제 수단을 강구하고자 한다. 토지보상액에 대해 불복하고자 하는 甲의 행정쟁송상 권리구제수단을 설명하시오. (20점) -22회 1번 문1

【문제 4】 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 공시지가를 기초로 한 보상액 산정에 있어서 개발이익 배제 및 포함을 논하시오.(20점) -17회 문3번

【문제 5】 헌법상 정당보상의 의미에 대해서 설명하시오.(10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 공부상 지목이 과수원(果)으로 되어 있는 토지의 소유자 甲은 토지상에 식재되어 있던 사과나무가 이미 폐목이 되어 과수농사를 할 수 없는 상태에서 사과나무를 베어내고 인삼밭(田)으로 사용하여 왔다. 또한 甲은 이 토지의 일부에 토지의형질변경허가 및 건축허가를 받지 않고 2005년 8월 26일 임의로 지상 3층 건물을 건축하고, 영업허가 등의 절차 없이 식당을 운영하고 있다. (50점) -18회 3번 변형

- 1) 토시보상법상 손실보상 원칙을 설명하고, 위 토지에 대한 보상평가기준에 대해 설명하십시오.(20점)
- 2) 위 지장물에 대한 보상평가기준에 대해 설명하십시오.(15점)
- 3) 2007년 5월 25일 甲의 토지를 대상으로 하는 공익사업이 인정되어 사업시행자가 甲에게 토지의 협의매수를 요청하였지만 甲은 식당영업에 대한 손실보상을 추가로 요구하면서 이를 거부하고 있다. 甲의 식당영업손실 보상에 관한 주장이 타당한지에 대해 논하십시오. (15점)

【문제 2】 A군에 사는 甲은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 지정된 개발제한구역 내에 과수원을 경영하고 있다. 甲은 영농의 편의를 위해 동 과수원 토지 내에 작은 소로(小路)를 개설하고, 종종 이웃 주민의 통행에도 제공해 왔다. A군은 甲의 과수원 부지가 속한 일단의 토지에 폐기물처리장을 건설하고자 하는 乙을 폐기물관리법에 따라 폐기물처리장 건설사업자로 지정하면서 동 처리장건설사업실시계획을 승인하였다. 甲과 乙간에 甲 토지에 대한 협의매수가 성립되지 않아 乙은 甲 토지에 대한 수용재결을 신청하고, 관할 지방토지수용위원회의 수용재결을 받았다. 동 수용재결에서는 “사실상 사도(私道)의 부지는 인근 토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 평가한다.”고 규정하고 있는 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙(이하 ‘토지보상법 시행규칙’) 제26조 제1항 제2호의 규정에 따라, 甲의 토지를 인근 토지가에 비하여 3분의 1의 가격으로 평가하였다. 이 수용재결에 대하여 이의가 있는 甲은 적절한 권리구제 수단을 강구하고자 한다. 다음의 물음에 답하시오.(30점) -22회 1번

1) 甲은 토지보상액에 대해 불복하여 보상금증액청구소송을 제기하였고, 당해 쟁송에서 피고 측은 甲의 토지에 대한 보상액이 낮게 평가된 것은 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 제2호의 규정에 의한 것으로서 적법하다고 주장한다.

피고의 주장에 대해 법적으로 판단하시오. (15점)

2) 甲은 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 제2호의 규정은 헌법 제23조상의 재산권보장 및 정당보상원칙을 위배하여 위헌적인 것이라고 주장한다. 甲의 주장을 관철할 수 있는 법적 수단을 설명하시오. (15점)

【문제 3】 중앙토지수용위원회는 보상금을 산정하면서, X토지는 그 용도지역이 제1종 일반주거지역이기는 하지만 기업도시개발사업의 시행을 위해서 제3종 일반주거지역으로 변경되지 않은 사정이 인정되므로 제3종 일반주거지역으로 변경이 이루어진 상태를 상정하여 토지가격을 평가한다고 실시하였다. 이에 대해 乙은 X토지를 제1종 일반주거지역이 아닌 제3종 일반주거지역으로 평가한 것은 공법상 제한을 받는 토지에 대한 보상금 산정에 위법이 있다고 주장하면서 보상금감액청구소송을 제기하고자 한다. 乙의 소송상 청구가 인용될 수 있는 가능성에 관하여 설명하시오. (단, 소송요건은 충족된 것으로 본다.) (10점) -28회 1번

【문제 4】 개간비 보상과 평가에 대하여 설명하시오. (10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 함)의 적용을 받는 공익사업으로 인하여 甲은 사업시행자인 한국철도시설공단 乙에게 협의절차를 통해 자신이 거주하고 있던 주거용 건축물을 제공하여 생활의 근거를 상실하게 되었다고 주장하면서 토지보상법 제78조 제1항에 따른 이주대책의 수립을 신청하였다. 이에 대해 乙은 "위 공익사업은 선형사업으로서 철도건설에 꼭 필요한 최소한의 토지만 보상하므로 사실상 이주택지공급이 불가능하고 이주대책대상자 중 이주정착지에 이주를 희망하는 자의 가구수가 7호(戶)에 그치는 등 위 공익사업은 토지 보상법 시행령 제40조 제2항에서 규정하고 있는 이주대책을 수립하여야 하는 사유에 해당되지 아니한다"는 이유를 들어 甲의 신청을 거부하였다. 다음 물음에 답하십시오. (40점) - 27회 1번

- 1) 乙이 甲에 대한 거부처분을 하기에 앞서 행정절차법상 사전통지와 이유제시를 하지 아니한 경우 그 거부처분은 위법한가? (20점)
- 2) 만약 甲이 거부처분 취소소송을 제기하였다면, 乙은 그 소송 계속 중에 처분의 적법성을 유지하기 위해 "甲은 주거용 건축물에 계약체결일까지 계속하여 거주하고 있지 아니하였을 뿐만 아니라 이주정착지로의 이주를 포기하고 이주정착금을 받은 자에 해당하므로 토지보상법 시행령 제40조 제2항에 따라 이주대책을 수립할 필요가 없다"는 사유를 추가·변경할 수 있는가? (20점)

<공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률> 제78조(이주대책의 수립 등) ① 사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는 자(이하 "이주 대책대상자"라 한다)를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하여야 한다.

② <이하 생략>

【문제 2】 인천도시공사는 인천 서구 오류동 일대 인천검단 일반지방산업단지 조성사업(이하 '이 사건 사업'이라 한다)의 사업시행자이다. 甲은 이 사건 사업인정고시일인 2006. 12. 26. 당시 이 사건 사업지구 내에 있는 인천 서구 오류동 (지번 1 생략) 토지에서 일정한 영업시설을 갖추고 제재목과 합판 등의 제조 및 판매업을 영위하고 있었다. 사업인정고시일 이후 위 토지에서 임대차계약기간이 만료되자 甲은 2007년 5월경 같은 사업지구 내에 속하는 같은 동 (지번 2 생략) 토지로 영업장소를 이전하여 기존 상호대로 이미 사용하던 시설 등을 옮겨 동일한 영업을 해왔다. 甲은 영업보상을 요구하면서 수용재결을 청구하였으나 관할 토지수용위원회가 甲의 영업장은 임대기간이 종료되어 이전한 것으로 공익사업의 시행으로 손실이 발생한 것이 아니라는 이유로 甲의 청구를 기각하였다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

물음1) 토지보상법상 영업손실보상에 대하여 설명하시오. (20점)

물음2) 영업손실 보상 대상 여부의 판단 기준일을 토대로 甲이 영업보상 대상이 되는지 검토하시오. (10점)

【문제 3】 X는 도시 및 주거환경정비법 (이하 '도시정비법'이라 함)에 따른 재개발정비사업조합이고, 甲은 X의 조합원으로서, 해당 정비사업구역 내에 있는 A토지의 소유자이다. A토지는 甲이 소유한 건축물의 부지로서 그 건축물의 일부에 임차인 乙이 거주하고 있다. X는 도시정비법 제72조 제1항에 따라 분양신청기간을 공고하였으나 甲은 그 기간 내에 분양신청을 하지 않았다. 이에 따라 X는 甲을 분양대상자에서 제외하고 관리처분계획을 수립하여 인가를 받았고, 그에 불복하는 행정심판이나 행정소송은 없었다. X는 도시정비법 제73조 제1항에 따른 甲과의 보상협의를 이루어지지 않자 A에 관하여 관할 토지수용위원회에 수용재결을 신청하였고, 관할 토지수용위원회는 A토지를 수용한다는 내용의 수용재결을 하였다. 주거이전비에 관하여 甲은 토지보상법 시행규칙 제54조 제1항에 따른 요건을 갖추고 있고, 乙은 같은 조 제2항에 따른 요건을 갖추고 있다. 관할토지수용위원회는 수용재결을 하면서 甲의 주거이전비에 관하여는 재결을 하였으나 乙의 주거이전비에 관하여는 재결을 하지 않았다. 甲은 주거이전비의 증액을 청구하고자 하고, 乙은 주거이전비의 지급을 청구하고자 한다. 甲과 乙의 권리구제에 적합한 소송을 설명하시오. (20점) - 33회 1번

【문제 4】 도지사 A는 "X국가산업단지 내 국도 대체우회도로개설사업"(이하 '이 사건 개발사업'이라 함)의 실시계획을 승인·고시하고, 사업시행자로 B시의 시장을 지정하였다. B시의 시장은 이 사건 개발사업을 시행함에 있어 사업시행으로 인하여 건물이 철거되는 이주대상자를 위한 이주대책을 수립하면서 훈령의 형식으로 'B시 이주민지원규정'을 마련하였다. B시의 시장은 이주대책을 실시하면서 이 사건 개발사업 구역 내에 거주하는 甲에 대하여, 甲은 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법령이 정한 이주대책대상자에 해당됨에도 불구하고 'B시 이주민지원규정'에서 정하는 요건을 이유로 이주대책대상자에서 배제하는 부적격 통보를 하였다. 甲은 'B시 이주민지원규정'에서 정한 추가적 요건을 이유로 자신을 이주대책 대상자에서 배제한 것은 위법하다고 주장한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (10점) - 28회 2번

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 뉴타운(New Town)개발이 한창인 A지역 인근에 주택을 소유한 P는 자신의 주택에 대하여 전년도 대비 현저히 상승한 개별공시지가를 확인하고 향후 부과될 관련 세금의 상승 등을 우려하여 부동산 가격공시에 관한 법률에 따른 이의신청을 하였으나 기각되었다. 이에 P는 확정된 개별공시지가에 대하여 다시 행정심판을 제기하였으나 행정심판위원회는 그 청구를 받아들이지 않았다. 그 후 P는 자신이 소유한 주택에 대하여 전년도보다 높은 재산세(부동산보유세)를 부과 받게 되었다. (40점) - 21회 2번 변형

1) 개별공시지가의 의의 및 법적 성질에 대하여 설명하시오. (10점)

1) P가 이의신청과 행정심판을 모두 제기한 것은 적법한지에 대하여 설명하시오. (10점)

2) P가 소유 주택에 대하여 확정된 개별공시지가가 위법함을 이유로, 그 개별공시지가를 기초로 부과된 재산세에 대한 취소청구소송을 제기할 수 있는지에 대하여 논술하시오. (20점)

【문제 2】 甲은 S시에 임야 30,000㎡를 소유하고 있다. S시장은 甲 소유의 토지에 대하여 토지의 이용 상황을 실제 이용되고 있는 '자연림'으로 하여 개별공시지가를 산정한 다음 A감정평가법인에 검증을 의뢰하였는데, A감정평가법인이 그 토지의 이용상황을 '공업용'으로 잘못 정정하여 검증지가를 산정하고, 시(市) 부동산가격공시위원회가 검증지가를 심의하면서 그 잘못을 발견하지 못하였다.

이에 따라 甲소유 토지의 개별공시지가가 적정가격 보다 훨씬 높은 가격으로 결정, 공시되었다 B은행은 S시의 공시지가를 신뢰하고, 甲에게 70억 원을 대출하였는데, 甲이 파산함에 따라 채권회수에 실패하였다. (30점) -24회 2번

1) B은행은 S시를 대상으로 국가배상을 청구하였다. S시의 개별공시지가 결정행위가 국가배상법 제2조상의 위법행위에 해당하는가에 관하여 논하시오. (20점)

2) S시장은 개별공시지가제도의 입법목적을 이유로 S시 담당공무원들의 개별공시지가 산정에 관한 직무상 행위와 B은행의 손해사이에 상당 인과관계가 없다고 항변한다. S시장의 항변의 타당성에 관하여 논하시오. (10점)

【문제 3】 서울의 A구청장은 이 사건 B토지의 비교표준지로 A구의 C토지(2017. 1. 1. 기준 공시지가가 1㎡당 810만원임)를 선정하고 이 사건 B토지와 비교표준지 C의 토지가격비준표상 토지특성을 조사한 결과 총 가격배율이 1.00으로 조사됨에 따라 이 사건 각 토지의 가격을 1㎡당 810만원으로 산정하였다. 감정평가사 D는 A구청장으로부터 이와 같이 산정된 가격의 검증을 의뢰받고 이 사건 각 토지가 비교표준지와 비교하여 환경조건, 획지조건 및 기타조건에서 열세에 있어 비교표준지의 공시지가를 약 83.9%의 비율로 감액한 1㎡당 680만원을 개별공시지가로 정함이 적정하다는 검증의견을 제시하였다. A구청장은 이 검증의견을 받아들여 2017. 5. 30.에 이 사건 각 토지의 개별공시지가를 1㎡당 680만원으로 결정·공시하였다. B토지소유자는 1㎡당 680만원으로 결정·공시된 B토지의 개별공시지가에 대하여 1㎡당 810만원으로 증액되어야 한다는 취지로 이의신청을 제기하였다. B토지소유자의 이의신청에 따라 A구청장은 감정평가사 E에게 이 사건 토지의 가격에 대한 검증을 의뢰하였다. 검증을 담당한 감정평가사 E는 토지특성 적용 및 비교표준지 선정에는 오류가 없으나 인근 지가와의 균형을 고려하여 개별공시지가를 1㎡당 700만원으로 증액함이 상당하다는 의견을 제시하였다. (이 사건 토지가 비교표준지와 비교하여 환경조건 및 획지조건에서 열세에 있다고 보아 비교표준지의 공시지가에 대하여 약 86.5%의 비율로 감액) 이에 A구청장은 A구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이 검증의견을 받아들여 B토지에 대하여 1㎡당 700만원으로 개별공시지가결정을 하였다. 이에 대하여 B토지소유자는 토지가격비준표와 달리 결정된 개별공시지가결정은 위법하다고 주장한다. 이 주장은 타당한가? (20점) -29회 3번

【문제 4】 부동산 가격공시에 관한 법령상 중앙부동산가격공시위원회에 관하여 설명하시오. (10점) -29회 4번

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 S시의 시장 A는 K구의 D지역(주거지역)을 도시 및 주거환경정비법(이하 '도정법')상 정비구역으로 지정·고시하였다. 그러자 이 지역의 주민들은 조합을 설립하여 주택재개발사업을 추진하기 위해 도정법에서 정한 절차에 따라 조합설립추진위원회를 구성하였고, 동 추진위원회는 토지등소유자의 동의, 정관, 공사비 등 정비사업에 드는 비용과 관련된 자료 등을 첨부하여 A로부터 X조합 설립인가를 받아 등기하였다. X조합은 조합총회를 개최하고 도정법상 토지등 소유자 동의를 얻어 지정개발자로서 Y를 사업시행자로 지정하였다. 다음 물음에 답하시오. (40점) -25회 1번

1) D지역의 토지소유자 중 甲이 "추진위원회가 주민의 동의를 얻어 X조합을 설립하는 과정에서 '건설되는 건축물의 설계의 개요' 등에 관한 항목 내용의 기재가 누락되었음에도 이를 유효한 동의로 처리하여 조합설립행위에 하자가 있다."고 주장하며 행정소송으로 다투려고 한다. 이 경우 조합설립인가의 법적 성질을 검토한 다음, 이에 기초하여 쟁송의 형태에 대해 설명하시오. (20점)

2) Y는 정비사업을 실시함에 있어 이 사업에 반대하는 토지등소유자 乙 등의 토지와 주택을 취득하기 위하여 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률에 의거한 乙 등과 협의가 성립되지 않아 지방토지수용위원회의 수용재결을 거쳤는데, 이 수용재결에 불복하여 Y가 중앙토지수용위원회에 이의재결을 신청하여 인용재결을 받았다. 이 경우 乙등이 이 재결에 대해 항고소송을 제기한다면 소송의 대상은 무엇인가. (20점)

【문제 2】 甲은 2014. 3.경 감정평가사 자격을 취득한 후, 2015. 9. 2.부터 2017. 8. 3.까지 '乙감정평가법인'의 소속 감정평가사였다. 또한 甲은 2015. 7. 7.부터 2017. 4. 30.까지 '수산업협동조합 중앙회(이하 '수협'이라 함)'에서 상근계약직으로 근무하였다. 관할 행정청인 국토교통부장관 A는 甲이 위와 같이 수협에 근무하면서 일정기간 동안 동시에 乙감정평가법인에 등록하여 소속을 유지하는 방법으로 감정평가사 자격증을 대여하거나 부당하게 행사했다고 봄이 상당하여, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 '감정평가법'이라 함) 제27조가 규정하는 명의대여 등의 금지 또는 자격증 부당행사 금지에 위반하였다는 것을 이유로 징계처분을 내리고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (30점) - 29회 2번

1) 국토교통부장관 A가 甲에 대하여 위와 같은 사유로 감정평가법령상의 징계를 하고자 하는 경우, 징계절차에 관하여 설명하시오. (20점)

2) 위 징계절차를 거쳐 국토교통부장관 A는 甲에 대하여 3개월간의 업무정지 징계처분을 하였고, 甲은 당해 처분이 위법하다고 보고 관할법원에 취소소송을 제기하였다. 이 취소소송의 계속 중 국토교통부장관 A는 당해 징계처분의 사유로 감정평가법 제27조의 위반사유 이외에, 징계처분 당시 甲이 국토교통부 장관에게 등록을 하지 아니하고 감정평가업무를 수행하였다는 동법 제17조의 위반사유를 추가하는 것이 허용되는가? (10점)

<감정평가 및 감정평가사에 관한 법률>

제17조(등록 및 갱신등록) ① 제11조에 따른 감정평가사 자격이 있는 사람이 10조에 따른 업무를 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 기간 이상의 실무수습을 마치고 국토교통부장관에게 등록하여야 한다.

②~④ 생략

제27조(명의대여 등의 금지) 감정평가사 또는 감정평가업자는 다른 사람에게 자기의 명 또는 상호를 사용하여 제10조에 따른 업무를 수행하게 하거나 자격증·등록증 또는 인가증을 양도·대여하거나 이를 부당하게 행사하여서는 아니 된다.

【문제 3】감정평가사 甲은 A감정평가법인(이하 'A법인'이라 함)에 형식적으로만 적을 두었을 뿐 A법인에서 감정평가사 본연의 업무를 전혀 수행하지 않았고 그 법인의 운영에도 관여하지 않았다. 이에 대해 국토교통부장관은 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 사전통지를 거쳐 감정평가사 자격취소처분을 하였다. 처분사유는 '甲이 A법인에 소속만 유지할 뿐 실질적으로 감정평가업무에 관여하지 아니하는 방법으로 감정평가사의 자격증을 대여하였다'는 것이었고, 그 법적 근거로 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 (이하 '감정평가법'이라 함) 제27조 제1항, 제39조 제1항 단서 및 제2항 제1호가 제시되었다. 甲은 사전통지서에 기재된 의견제출 기한 내에 청문을 신청하였으나 국토교통부장관은 '감정평가법 제13조 제1항 제1호에 따라 감정평가사 자격취소를 하려면 청문을 실시하여야 한다는 규정이 있지만, 명의대여를 이유로 하는 감정평가사 자격취소의 경우에는 청문을 실시하여야 한다는 규정이 없을 뿐 아니라 청문을 실시할 필요도 없다'는 이유로 청문을 실시하지 않았다. 甲에 대한 감정평가사 자격취소처분이 적법한지 설명하시오. (20점) -33회 3번

<감정평가 및 감정평가사에 관한 법률>

제13조(자격의 취소) ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 자격을 취소하여야 한다.

1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우
2. 제39조제2항제1호에 해당하는 징계를 받은 경우

제27조(명의대여 등의 금지) ① 감정평가사 또는 감정평가법인등은 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 제10조에 따른 업무를 수행하게 하거나 자격증·등록증 또는 인가증을 양도·대여하거나 이를 부당하게 행사하여서는 아니 된다.

제39조(징계) ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할수 있다. 다만, 제2항제1호에 따른 징계는 제11호, 제12호를 위반한 경우 및 제27조를 위반하여 다른 사람에게 자격증·등록증 또는 인가증을 양도 또는 대여한 경우에만 할 수 있다.

② 감정평가사에 대한 징계의 종류는 다음과 같다.

1. 자격의 취소
2. 등록의 취소

3. 2년 이하의 업무정지

4. 견책

제45조(청문) 국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

1. 제13조제1항제1호에 따른 감정평가사 자격의 취소
2. 제32조제1항에 따른 감정평가법인의 설립인가 취소

【문제 4】 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률상 감정평가법인등의 손해배상책임의 성립요건에 관하여 설명하시오. (10점) -33회 4번

1기 1주차 예시답안

[문제1] 45점 – 법규 1기 1주차 예시답안, 윤철신 평가사**<물음 1> 10점****I. 국가 이외의 자가 수용권자인 경우 수용권의 주체 논의****1. 문제점**

국가가 사업시행자인 경우는 논란이 없으나, 국가 이외의 공공단체나 사인(공무수탁사인)이 사업시행자인 경우 수용권의 주체가 누구인지 견해가 대립한다.

2. 학설

① <국가수용권설> 수용권이란 수용의 효과를 야기할 수 있는 능력이므로 수용권자는 국가라고 한다. 사업시행자는 수용권의 발동을 국가에게 청구하는 권리를 갖는데 지나지 않는다고 한다. ②<사업시행자수용권설> 수용의 본질이 특정한 재산권을 취득하는 데 있으므로, 수용권이란 수용의 효과를 누리는 능력이라고 한다. 따라서 수용권자는 사업시행자라고 한다. 이 설이 우리나라 다수설이다.

3. 판례

대법원은 사업인정을 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정해 주는 설권적 형성처분이라 판시하여 사업시행자수용권설의 입장이다.

4. 검토

국가공권력의 개입이 수용의 효과를 야기한다 하더라도, 현행 공용수용제도는 공공단체는 물론 기업이나 사인에게도 수용권을 부여하고 있고, 수용권은 수용의 효과를 누릴 수 있는 능력이라 볼 수 있으므로, 사업시행자수용권설을 취하는 것이 타당하다.

<물음 2> 15점**I. 논점의 정리**

토지보상법 제19조 제2항은 “공익사업에 수용되거나 사용되고 있는 토지 등은 특별히 필요한 경우가 아니면 다른 공익사업을 위하여 수용하거나 사용할 수 없다”고 규정하고 있어 공물의 수용시 별도의 공용폐지가 요구되는가와 관련하여 특별한 필요의 해석이 문제된다.

II. 공물의 수용가능성**1. 학설**

① <긍정설> 토지보상법 제19조 제2항은 현재의 용도보다 한층 공익상 중요한 용도를 위한 특별한 필요가 있는 때에 공용폐지 없이 예외적으로 수용을 허용하는 것으로 본다. ② <부정설> 공물의 수용은 공물의 목적에 반하므로 원칙적으로 허용되지 않지만, 더 큰 공익을 위해 수용이 필요한 경우 공용폐지를 선행해야 한다고 한다.

2. 판례

대법원은 (구)문화재보호법에 의하여 지방문화재로 지정된 토지가 수용대상이 된다고 하여 공적 보존물이 수용의 대상이 될 수 있다고 판시하였고(대판 1996. 4. 26. 95누13241 판결), 헌법재판소는 토지보상법 제19조 제2항에 대하여 공익 또는 수용권의 충돌문제를 해결하기 위한 것으로, 특별한 필요가 있는 경우에는 현재 공익사업에 이용되고 있는 토지도 예외적으로 수용의 목적물이 될 수 있다고 판시하였다(헌재 2000헌바32). 따라서 판례는 대체로 공물의 수용도 가능하다는 입장으로 보인다.

다만, 대법원은 (구)국유림법상 요존국유림은 (구)국유림법에서 정하는 절차와 방법에 따라서만 관리·사용할 수 있을 뿐이고, 불요존국유림으로 재구분되지 않는 이상 관리청이 임의로 처분하지 못하는 것이기 때문에, 토지보상법상 협의 또는 재결의 대상이 될 수 없다고 판시하여 용도폐지가 선행되어야 한다고 본다.(대판 2018. 11. 29. 2018두51904 판결).

3. 검토

생각건데, 공물은 현재 공익목적에 제공되고 있지만, 특별한 필요가 있다면 다른 공익사업에 수용될 수 있다고 본다. 특별한 필요는 비례의 원칙에 따라 종래의 공익과 새로운 공익을 비교형량하여 판단해야 한다. 다만 이 경우에도 국유재산법 등 관련 법률의 규정에 따라 공물의 용도폐지가 선행되어야 한다고 본다.

4. 사안의 해결

특별한 필요는 행정목적과 행정수단 사이 비례성이 인정되어야 한다는 비례의 원칙에 따라 판단한다. B토지는 문화재보호법상 보호구역으로 지정된 공물이지만, 공원사업의 공익성이 더욱 크다면 특별한 필요가 인정되어 수용이 가능할 것이다. 다만, 문화재보호법에 따른 용도폐지가 선행되어야 할 것이다.

<물음 3> 20점

I. 확장수용의 의의·취지

확장수용은 특정한 공익사업을 위하여 목적물의 필요한 범위를 넘어서 수용하는 것이다. 확장수용은 원칙상 인정되지 않는다. 그러나 예외적으로 수용권자와 피수용자간 이해관계를 합리적으로 조정하고, 피수용자에 대한 권리구제에 이바지하며, 사업의 원활한 실시를 위해 법률규정이 있는 경우 인정된다.

II. 유형

1. 완전수용(토지보상법 제72조)

완전수용이란 토지사용으로 인해 토지소유자가 받게 되는 현저한 장해에 갈음하여 수용보상을 가능하게 해 주는 제도이다. 완전수용은 '사용에 갈음하는 수용'이라고도 한다.

2. 잔여지 수용(동법74조)

①잔여지수용이란 동일한 토지소유자에게 속하는 수용 목적 물인 일단의 토지 일부가 매수

또는 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때 토지소유자의 청구에 의해 사업시행자가 해당 토지의 전부를 매수하거나 관할 토지수용위원회가 수용하는 것을 말한다.

3. 이전수용(동법75조)

토지상의 지장물은 이전에 필요한 비용(이하 "이전비"라 함)을 보상하고 이전하는 것이 원칙이다. 이전수용이란 물건 등의 이전을 강행하는 것이 소유자나 사업시행자에게 과중한 손실을 가져올 우려가 있는 예외적인 경우 수용할 수 있도록 하는 제도이다.

Ⅲ. 확장수용의 성질

1. 학설

① <사법상 매매설> 사업시행자의 재산권 취득은 피수용자와의 합의를 바탕으로 하므로 사법상 매매의 성질을 띤다고 한다. ② <공법상 특별행위설> 확장수용이 해당 공익사업의 시행상 필요 최소한도를 넘긴 하나, 피수용자의 청구에 의해 이뤄진다는 점에서 공법상 특별행위라고 한다. ③ <공용수용설> 확장수용은 피수용자의 청구를 요건으로 하는 사업시행자의 일방적 권리취득 행위로서, 그 본질은 일반적 수용과 다른 것이 없다고 한다. 이 견해가 다수설이다.

2. 판례

대법원은 잔여지 수용청구권이 그 요건을 갖춘 때에는 토지수용위원회의 특별한 조치를 기다릴 것 없이 청구에 의하여 수용의 효과가 발생하므로, 이는 형성권적 성질을 가진다고 판시하여 공용수용설 입장이라고 할 수 있다.

3. 검토

확장수용은 피수용자에 대한 권리구제의 보충적 필요에 의의가 있으므로, 본래의 수용개념과는 구별된다. 그러나 확장수용은 피수용자의 청구를 요건으로 한 사업시행자의 권리취득 행위로서 공용수용의 효과가 발생하므로, 공용수용설이 타당하다.

Ⅳ. 확장수용재결의 불복

1. 문제점

확장수용은 수용재결에 의하여 이루어지므로 확장수용 거부 시 이에 대한 불복은 토지보상법 제83조 및 제85조의 규정에 따르면 된다. 이때 항고소송을 제기하지 않고 보상금증감청구소송을 제기할 수 있는지, 민사소송의 제기는 가능한지 문제된다.

2. 이의신청(동법83조)

토지보상법 제34조에 따른 재결에 이의가 있는 자는 토지보상법 제83조에 따라 재결서 정본 송달일로부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있다. 토지보상법은 이의신청을 임의적 절차로 규정하여 행정심판법의 행정심판 임의주의의 입법취지와 균형을 맞추어 신속한 권리구제를 도모하고 있다.

3. 보상금증감청구소송의 가능성

1) 학설

- ① <부정설>은 확장수용에 대한 다툼은 보상금액의 문제가 아니라 보상의 범위에 관련된 문제이므로 불가하는 견해,
- ② <긍정설>은 보상금액과 보상범위는 밀접한 관련이 있어 긍정하는 견해가 있다.

2) 판례

잔여지 수용청구권은 형성권적 성질을 가지므로, 잔여지 수용청구를 받아들이지 않은 토지 수용위원회의 재결에 대하여는 사업시행자를 피고로 하여 토지보상법 제85조 제2항에 규정되어 있는 “보상금의 증감에 관한 소송”을 제기해야 한다고 판시하였다.

3) 검토 및 사안의 해결

보상금증감청구소송의 제도 취지가 분쟁의 일회적 해결로서 피수용자의 권리구제를 위한 것이므로, 보상금증감청구소송에서 목적물 범위까지 심리하여 다툴 수 있도록 함이 타당하다. 따라서 丙은 항고소송을 제기하지 않고 보상금증감청구소송을 통하여 불복할 수 있다.

4. 민사소송의 가능성

<대법원>은 수용재결 및 이의재결에 불복이 있으면 재결청과 기업자를 공동피고로 하여 그 이의재결의 취소 및 보상금의 증액을 구하는 행정소송을 제기하여야 하며 곧바로 기업자를 상대로 하여 민사소송으로 잔여지에 대한 보상금의 지급을 구할 수 없다고 하여 이를 부정하였다.

[문제2] 25점**I. 타인토지 출입(토지보상법9조)****1. 의의**

사업시행자는 공익사업을 준비하기 위하여 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다(제9조 제1항).

2. 법적성질

① 토지에 출입할 수 있는 권리를 부여한다는 점에서 강학상 특허이며, 재량행위로 보아야 한다. ② 출입 측량·조사 행위 자체는 비권력적 사실행위이나, 토지보상법상 토지점유자의 인용의무(제11조)가 부과되므로, 사실행위와 수인하명이 결합된 합성행위로서 권력적 사실행위에 해당하고, 처분성이 인정된다.

3. 요건 및 절차

사업시행자는 타인토지에 출입, 측량·조사하려면 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받거나 통지하여야 한다(제9조 제2항). 사업시행자는 출입하려는 날의 5일 전까지 그 일시 및 장소를 특별자치도지사 등에게 통지하여야 하고, 특별자치도지사 등은 그 토지점유자에게 통지하여야 한다.

4. 효과

① 사업시행자는 타인토지출입권, 장애물 제거·시굴허가 신청권, 손실보상의무, 반환 및 원상회복의무(48)가 발생한다.
② 피수용자는 손실보상청구권(안 날로부터 1년/발생한 날로부터 3년), 인용의무(11), 인용의무 위반 시 200만원 이하의 벌금(97)의 효과가 발생한다.

Ⅲ. 실력행사의 가부**1. 문제점**

타인토지출입 측량조사와 같은 권력적 행정조사 중, 상대방이 조사를 거부하는 경우 벌칙규정은 존재하지만, 실력행사에 관한 명문 규정이 없는 경우 직접 실력행사를 통해 필요한 출입 측량·조사를 할 수 있는지 문제된다.

2. 학설

① <긍정설> 제재규정을 둔 것은 피조사자의 수인의무 위반을 위법으로 보아 비례의 원칙 안에서 실력을 가할 수 있는 규정으로 볼 수 있다고 한다. ② <부정설> 토지보상법상 벌칙 규정만을 둔 취지는 조사의 실효성을 간접적으로 확보하려는 것으로서 실력행사는 허용되지 않는다고 한다.

3. 검토

국민의 신체나 재산에 대한 실력행사는 명문의 근거가 있어야 하므로 부정설이 타당하다.

IV. 위법한 측량조사에 따른 사업인정의 효력

1. 문제점

측량·조사의 내용에 흠이 있어 그 정보에 기초하여 내려진 사업인정은 내용상 위법하다. 그러나 내용상으로는 정확하나 측량·조사가 절차를 위반한 경우, 즉 상기와 같은 실력행사를 하여 측량·조사를 마쳤다가 하는 등과 같은 절차 위반 시, 그 측량·조사에 의해 수립된 정보에 기초하여 내려진 사업인정이 위법한 것으로 되는지 문제된다.

2. 학설

① <적극설> 절차의 적법성 보장 원칙에 비추어 행정조사가 위법한 경우 당해 조사를 기초로 한 행정행위는 위법하다. ② <소극설> 행정조사는 법령에서 특히 행정행위의 전제조건으로 규정되어 있는 경우를 제외하고는 일응 별개의 제도로 볼 수 있어 조사의 위법이 바로 행정행위를 위법하게 하지는 않는다. ③ <절충설> 행정조사와 행정처분은 하나의 과정을 구성하므로 적정절차 관점에서 행정조사에 중대한 위법사유가 있으면 그에 기초한 행정행위도 위법한 것으로 볼 수 있다.

3. 판례

판례는 위법한 세무조사에 기초한 부가가치세 부과처분은 위법하다고 하여 적극설을 취하고 있다. 다만, 행정조사 절차하자가 경미한 경우에는 위법사유가 되지 않는 것으로 본다.

4. 검토

사업인정에 필요한 정보를 수집하기 위해 행해진 측량·조사가 위법한 경우 당해 행정행위의 절차하자가 있는 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 경우 사업인정의 효력은 절차 하자의 문제가 될 것이다.

[문제3] 20점**I. 공용수용의 의의·취지 및 근거**

①공용수용(公用收用)이란 특정한 공익사업을 위해 사업주체가 국가권력으로 타인의 재산을 강제적으로 취득하는 것을 말한다. ②공용수용제도는 공익사업을 위해 권리자의 의사에 관계없이 토지소유권 등을 강제적으로 취득하는 길을 열어두기 위해 마련된 제도이다. ③현대복지국가의 공공복리 증진 등 이론적 근거로 헌법23조3항과 토지보상법 등 개별법에 근거를 둔다.

II. 공용수용의 요건(헌법23조3항)**1. 공공필요가 있을 것**

공공필요란 대표적 불확정개념으로, 공익을 위해 재산권의 수용·사용·제한이 불가피한 경우를 말한다. 공공필요의 판단은 비례의 원칙에 따라 공익사업으로 달성하려는 공익과 이로 인하여 침해되는 사익을 이익형량하여 판단한다.

2. 재산권에 대한 공권적 침해일 것

① 재산권이란 법에 의해 보호되는 모든 재산적 가치 있는 권리를 말한다. ② 이러한 재산권에 대해 공권력에 의한 침해, 즉 재산권의 수용·사용·제한이 있어야 한다.

3. 재산권 침해의 법적 근거가 있을 것

침해가 법률에 근거한 것이어야 하며 법률에 위반하지 말아야 한다. 법률의 근거가 없거나 법률에 위반하여 행하여지는 경우에는 국가배상의 원인이 된다.

4. 특별한 희생이 발생할 것

재산권의 사회적 제약을 넘어서는 특별한 희생이 발생해야 한다. 사회적 제약과 특별한 희생을 구별하는 기준으로는 형식적 기준설과 실질적 기준설이 있으며, 구체적인 사정을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

5. 보상규정이 존재할 것

보상규정이 존재해야 손실보상이 가능하다. 보상규정이 존재하지 않는 경우의 손실보상에 대해서는 견해가 대립한다.

III. 공용수용과 공공필요**1. 헌법23조 3항의 공공필요**

①공공필요는 대표적 불확정 개념으로 현대복지국가이념에 따라 확대화 경향이 있다. ②헌법 제23조 제3항에 따라 재산권에 대한 공권적 침해는 공공필요가 있을 때만 행해질 수 있으므로, 공공필요는 공용침해의 실질적 허용요건이자 본질적 제약요소이다.

2. 토지보상법 제4조 및 별표, 제4조의2 수용적격사업

토지보상법은 공공필요가 있는 사업을 수용적격사업으로 규정하고 있다(제4조 및 별표, 제4

조의2). 사업의 공공성을 확보하기 위해 사업인정 발령 시 실질적 공공필요가 있는지 판단한다.

3. 공공필요의 판단기준

공공필요는 공용침해를 통하여 얻어지는 공익과 재산권자의 재산권 보유이익 간에 이익형량을 통해서 그 여부가 결정되고, 그 입증책임은 사업시행자에게 있다.

[문제4] 10점**I. 사적 공용수용의 의의·취지**

공공적 사용수용(사적 공용수용, 사용수용)이란 특정한 공익 사업을 위하여 사적 주체가 타인의 특정 재산권을 법률의 힘에 의해 보상을 조건으로 강제적으로 취득하는 것이다. 민간활력의 도입, 사업의 확대 등에 취지가 있다.

II. 사적 공용수용의 요건(헌법23조3항)

① 공공적 사용수용은 공익사업의 목적에만 인정된다. ② 사적 주체로서 국가권력에 의해 수용권을 부여받는다. ③ 대상은 특정한 재산권이다. ④ 법률에 근거하여 타인의 재산권을 강제적으로 취득한다. 강제적 취득이란 권리자의 의사에 상관없이 일방적으로 재산권을 취득하는 것을 말한다. ⑤ 공공적 사용수용은 공용수용과 마찬가지로 재산권자에게 특별한 희생을 발생시키므로, 정당한 보상을 지급하여야 한다.

III. 사적 공용수용 인정여부**1. 독일의 논의**

독일에서는 일반 사기업도 공익을 위해 수용이 허용된다고 보는 것이 일반적이다. 생존배려형 사기업의 공익사업은 국가적 과제이므로 사기업에게 수용권한을 부여하는 것은 당연하며, 경제적 사기업인 경우에도 공익적 요청에 의한 것이라면 정당화될 수 있다고 봄이 일반적 입장이다.

2. 판례 및 검토

① <대법원>은 어떤 사업이 공익사업인가의 여부는 그 사업자체의 성질에 의하여 정할 것이고, 사업주체의 여하에 의하여 정할 것이 아니라고 판시하였고,
② <헌법재판소>도 관광진흥법 위헌소원사건에서 재산권의 수용의 주체를 한정하지 않고 있는바 합헌이라고 보았다.

IV. 계속적 공익실현의 보장책

① 공공적 사용수용의 사적 주체는 이윤추구의 목적도 함께 가지고 있으므로 언제든지 사업을 중도에 포기할 가능성이 있어 보장책이 필요하다. ② 토지보상법상 환매권 및 사업인정의 실효제도나 ③ 개별법상 사업시행자에 대한 감독명령과 처분이나 행정쟁송, 위헌법률심판 등 입법·사법적 통제 등 여러 보장수단이 규정되어 있으나 추상적이고 제한적이어서 실효성 있는 수단으로 개괄적 규정이 마련되어야 할 것이다.

1기 2주차 예시답안

[문제1] (30점)**<물음1> (10점)****I. 개설**

사업인정 전 협의에 의한 취득의 절차는 토지·물건조서의 작성(제14조), 보상계획의 공고·열람 등(제15조), 보상액의 산정(제68조), 협의(제16조), 보상계약의 체결(제17조) 단계로 이루어져 있다.

II. 토지조서 및 물건조서의 작성(토지보상법 제14조)

① 토지조서 및 물건조서란 공익사업을 위해 취득 또는 사용할 토지와 그 토지상의 물건내용을 사업시행자가 일정한 절차를 거쳐 작성하는 문서이다. 조서작성은 당사자간 분쟁 소지를 미리 예방하고, 원활한 공익사업 시행에 취지가 있다. ②사업시행자는 토지조서와 물건조서를 작성하여 서명 또는 날인을 하고 토지소유자와 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 하거나 일정한 사유로 받을 수 없는 경우 그 사유를 적어야 한다.

III. 보상계획의 공고 및 열람(토지보상법 제15조)

사업시행자는 토지조서와 물건조서를 작성하였을 때에는 공익사업의 개요, 토지조서 및 물건조서의 내용과 보상의 시기·방법 및 절차 등이 포함된 보상계획을 전국을 보급지역으로 하는 일간신문에 공고하고, 토지소유자 및 관계인에게 각각 통지하여야 하며, 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장에게도 통지하여야 한다.

IV. 보상액의 산정(토지보상법 제68조)

①사업시행자는 보상액을 산정하려는 경우 감정평가법인등 3인(감정평가법인등을 추천하지 아니하는 경우에는 2인)을 선정하여 토지 등의 평가를 의뢰하여야 한다. ②사업시행자는 보상평가서를 검토한 결과 그 평가가 관계법령에 위반하여 평가되었거나 합리적 근거 없이 비교 대상이 되는 표준지의 공시지가와 현저하게 차이가 나는 등 부당하게 평가되었다고 인정하는 경우에는 당해 감정평가법인등에게 그 사유를 명시하여 다시 평가할 것을 요구하여야 한다.

V. 협의와 계약체결(토지보상법 제16조, 제17조)**1. 협의의 의의와 법적성질**

①협의란 공익사업에 필요한 토지 등의 권리 취득 및 소멸 등을 위해 행하는 사업시행자와 피수용자 간의 임의적 합의를 말한다(제16조). ②법적성질 관해 견해대립이 있으나 판례는 손실보상의 협의는 공공기관이 사경제주체로서 행하는 사법상 계약의 실질을 가지는 것으로 본다.

2. 협의의 효과

① 협의 성립 시 협의의 내용에 따른 사법상 계약의 효과가 발생한다. ②협의 불성립시 사업시행자는 협의경위서를 작성하여 토지소유자 등의 서명 또는 날인을 받아야 하며 받을 수

없는 경우 그 사유를 기재하여야 한다. 사업시행자는 공익사업의 진행을 위해 국토교통부장관에게 사업인정을 신청할 수 있다.

<물음2> (10점)

I. 개설

협이란 공익사업에 필요한 토지 등의 권리 취득 및 소멸 등을 위해 행하는 사업시행자와 피수용자 간의 임의적 합의를 말한다. 토지보상법상 사업인정 전 협의 취득(제16조)과 사업인정 후 협의 취득(제26조)을 규정한다. 이하 양자를 비교한다.

II. 공통점

1. 제도적 취지

협이는 임의적 합의를 바탕으로 하여 최소 침해의 원칙을 구현하고, 토지소유자 및 관계인에게 해당 사업의 취지를 이해시켜 신속하게 사업을 수행하고자 함에 그 취지가 있다.

2. 협의의 내용(토지보상법 제50조)

협의를 할 내용은 토지·물건조서의 작성범위 내이고, 구체적 내용으로는 토지보상법 50조의 수용 또는 사용할 토지의 구역 및 사용방법, 손실보상, 수용 또는 사용의 개시일과 기간, 그 밖에 이 법 및 다른 법률에서 규정한 사항 등이 있다.

III. 차이점

1. 법적성질 및 권리구제 차이

사업인정 전후 협의의 법적성질 관련 논의가 있으나 ①사업인정 전 협의는 다수설과 판례는 <사법상 계약>으로 보고, 사업인정 전 협의에 대해 다툼이 있는 경우 <민사소송>에 의한다. 반면, ②사업인정 후 협의에 대해 판례는 <사법상 계약>으로 보나, 다수설은 수용권 실행 방법의 하나로 <공법상 계약>으로 이해하고 있다. 다수설에 의할 경우 사업인정 후 협의에 대해 다툼이 있는 경우 <공법상 당사자소송>에 의하게 된다.

2. 필수적 절차 여부

사업인정 전 협의는 임의적 절차이나, 사업인정 후 협의는 필수적 절차이다. 토지보상법은 사업인정 전 협의는 사업시행자의 성실협의의무만을 규정하고 있지만, 사업인정 후 협의는 반드시 거칠 것을 의무로 규정하고 있다. 단지 절차의 중복을 피하기 위하여 사업인정 후 협의를 일정한 경우 하지 않을 수 있는 규정을 두고 있을 따름이다.

3. 효과상 차이(확인제도 유무)

①사업인정 전 협의는 협의성립확인 제도가 없으며, 사업인정 후 협의는 협의성립확인을 받으면 재결로 간주되는 규정이 있다. 이에 ②사업인정 전 협의 성립 시 승계취득으로 보면, 사업인정 후 협의 성립 시 협의성립확인 받기 전엔 승계취득, 협의성립확인 후엔 재결로 간주하는바, 원시취득으로 본다.

4. 협의불성립시 이후 절차상 차이

- ① 사업인정 전 협의 불성립 시 사업인정 신청을 시작으로 강제수용절차를 진행할 수 있고,
- ② 사업인정 후 협의 불성립 시 사업시행자는 재결신청을, 피수용자는 재결신청청구를 할 수 있다.

IV. 양자의 관계

- ①<선후관계> 양 협의 간에는 사업인정 이전인지 이후인지에 따른 기본적인 선후관계가 존재한다. 그러나 구속력이 있는 것은 아니다. ②<생략 가능성> 사업인정 후 협의는 원칙상 필수절차이지만 일정요건을 충족하면 생략할 수 있다.

<물음 3> (10점)

I. 사업인정고시(토지보상법 제22조)

사업인정고시란 사업인정 효과가 미치는 범위를 누구에게나 확인할 수 있도록 나타내는 절차이다. 사업인정은 통지가 있었다 하더라도 고시가 없으면 효력이 발생되지 아니한다.

II. 사업인정고시의 효과

1. 토지수용권의 발생

사업인정이 고시됨으로써 사업시행자는 자기가 시행하는 공익사업을 위하여 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 목적물을 수용할 수 있는 권한이 부여된다.

2. 수용목적물의 확정

사업인정이 고시되면서 토지세목고시를 통해 수용 또는 사용할 토지의 범위가 특정된다. 사업시행자는 수용 또는 사용할 토지의 위치와 예정 면적의 범위가 정해지면 그 범위 내에서 공익사업의 시행에 따른 권리를 행사할 수 있고 현재 또는 장래의 권리자에게 대항할 수 있다.

3. 관계인의 범위 제한

사업인정 고시가 있는 후 권리를 취득한 자는 기존 권리를 승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 아니한다(제2조 제5호). 사업인정고시가 있는 후 새로이 권리를 취득한 자는 관계인으로 인정되지 않기 때문에 보상금을 받을 수 없다. 관계인의 범위를 한정하는 것은 수용절차에 참여하는 자를 제한함으로써 절차를 간소하게 하는 데 이바지한다.

4. 토지 등의 보전의무

사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나, 제3조에 규정된 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못한다(제25조 제1항). 이 규정을 위반한 자는 원상회복의무를 부담하며 이에 관한 손실보상을 청구할 수 없다.

5. 토지·물건조사권의 발생

사업인정고시 후 사업시행자 또는 감정평가를 의뢰받은 감정평가법인등은 조서작성이나 감정평가를 위하여 필요한 경우 허가 없이도 해당 토지나 물건에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다. 이 경우 출입의 통지(제10조 제3항), 토지점유자의 인용의무(제11조) 및 증표 등의 휴대 규정(제13조) 규정을 준용한다(제27조 제1항).

<끝>

[문제2] 30점**<물음1>10점****I. 논점의 정리**

협의성립확인 은 재결절차를 준용하는 경우와 공증을 받아 신청하는 경우의 두 절차가 있는 바, 이하 설명한다.

II. 의의 및 취지

- ① 사업인정 후 협의가 성립하면 사업시행자가 피수용자의 동의를 받거나 또는 공증을 받아 관할 토지수용위원회의 확인을 받는 제도이다.
- ② 계약 불이행에 따른 분쟁 예방, 공익사업의 원활한 진행에 규정취지가 있다.

III. 협의성립확인의 절차**1. 일반적 확인절차(토지보상법 제29조 제1항)**

- ① 협의가 성립되었을 때 사업시행자는 재결신청기간 내에 피수용자의 동의를 얻어 관할 토지수용위원회에 협의성립의 확인을 신청할 수 있다.(제29조 제1항)
- ② 관할 토지수용위원회의 확인절차는 재결절차를 준용한다.
- ③ 따라서 토지수용위원회는 협의성립확인신청서를 접수한 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 지체없이 이를 공고하고 공고한 날로부터 14일 이상 관계서류의 사본을 일반이 열람할 수 있도록 하여야 한다.(제31조 제1항)
- ④ 토지수용위원회가 제1항의 규정에 의한 공고를 한 때에는 관계서류의 열람기간 중에 토지소유자 또는 관계인은 의견을 제시할 수 있다.(제31조 제2항)
- ⑤ 토지수용위원회는 열람기간이 지났을 때에는 지체 없이 해당 신청에 대한 조사 및 심리를 하여야 하고(제32조), 14일 이내에 확인(제35조)하여야 한다.

2. 공증에 의한 확인절차(동조 제3항)

사업시행자가 협의가 성립된 토지의 소재지·지번·지목 및 면적 등 대통령령으로 정하는 사항에 대하여 「공증인법」에 따른 공증을 받아 제1항에 따른 협의 성립의 확인을 신청하였을 때에는, 관할 토지수용위원회가 이를 수리함으로써 협의성립이 확인된 것으로 본다.(제29조 제3항)

<물음2> 5점**I. 토지보상법 제29조 동의요건****1. 협의성립확인의 법적정당성의 원천**

간이한 절차만을 거치는 협의 성립의 확인에, 원시취득의 강력한 효력을 부여함과 동시에 사법상 매매계약과 달리 협의 당사자들이 사후적으로 그 성립과 내용을 다툴 수 없게 한 법적 정당성의 원천은 사업시행자와 토지소유자 등이 진정한 합의를 하였다는 데에 있다.

2. 진정한 소유자의 동의가 필요

여기에 공증에 의한 협의 성립 확인 제도의 체계와 입법 취지, 그 요건 및 효과까지 보태어 보면, 토지보상법 제29조 제3항에 따른 협의 성립의 확인 신청에 필요한 동意的 주체인 토지소유자는 협의 대상이 되는 '토지의 진정한 소유자'를 의미한다.

II. 동의흡결인지 여부

본 사안에서 사업시행자는 등기부상 소유자의 동의를 받았으나, 관련 증거들에 의해 진정한 소유자는 원고인 것으로 나타났다. 따라서 본 사안에서는 소유자의 동의가 흡결된 하자가 존재한다.

<물음3> 15점**I. 논점의 정리**

동의요건 흡결이 있는 협의성립확인 신청을 관할 토지수용위원회가 수리했을 경우 그 수리의 위법성 및 위법성 정도를 검토하고, 소송요건 검토를 통해 당해 수리가 항고소송으로 취소할 수 있는지 검토한다.

II. 수리의 위법성**1. 수리행위의 의의**

수리행위란 법상 행정청에게 수리의무가 있는 경우에 신고, 신청 등 타인의 행위를 행정청이 적법한 행위로서 받아들이는 행위를 말한다.

2. 위법성 여부**1) 관련 판례**

<판례>는 토지보상법 제29조 제3항에 따른 협의 성립의 확인 신청에 필요한 동意的 주체인 토지소유자는 협의 대상이 되는 <토지의 진정한 소유자>를 의미한다고 보아야 하며, 진정한 토지소유자의 동의가 없었던 이상, 사업시행자의 과실이 있었는지 여부와 무관하게 그 동意的 흡결은 <수리행위의 위법사유>가 된다.

2) 검토

토지보상법 제29조 제3항에서 보다 간이한 협의성립확인 절차에 강한 효력을 부여할 수 있는 법적 정당성의 근거는 <진정한 소유자>와의 합의를 전제로 하는 데에 있다. 따라서 단

순히 등기부상 소유명의자와의 동의만을 공증받아 협의성립확인을 신청하였음에도 이를 수리하였다면 위법하다고 본다.

2. 위법성 정도

① 하자가 중대하면 무효라는 중대설, 중대하고 명백하면 무효라는 중대명백설, 보충적으로 명백성을 요구하는 명백성 보충요건설 등이 있으나 ②통설 및 판례는 <중대명백설>을 취하고 있다. ③ 행정의 법적 안정성과 국민의 권리구제의 요청을 적절히 조화시키는 중대명백설이 타당하며, 동의 흠결이 있는 협의성립확인 신청의 수리는 그 하자가 중대하나 일견 명백하지 않아 <취소사유의 하자>이다.

IV. 항고소송으로 취소를 구할 수 있는지

1. 소송요건 충족여부

1) 대상적격

①토지보상법 제29조 제3항에 따라 '수리'함으로써 협의성립이 확인된 것으로 본다. ②이는 행정청이 수리를 하여야 비로소 법적 효과가 발생하므로, 행정청의 수리 또는 수리의 거부는 준법률행위적 행정행위의 하나로서 행정소송법상의 처분의 개념에 해당한다.

2) 원고적격 및 기타 소송요건

진정한 소유자의 상속인인 원고는 처분의 당사자로 법률상 이익이 있는바, 원고적격이 있으며, 협의소익, 제소기간 등 그 외 소송요건은 특별한 문제가 없는 것으로 본다.

2. 당해 수리를 항고소송으로 취소할 수 있는지(사안의 해결)

본 사안은 소송요건을 충족하고, 진정한 토지소유자의 동의를 결여한 <수리>의 위법성이 인정되고, 그 위법성의 정도가 취소사유이므로, 인용판결을 받을 수 있을 것이다.

[문제3] 30점**<물음 1> (15점)****I. 개설**

토지보상법은 사업인정 후 협의 불성립 또는 불능시 사업시행자에게는 재결신청권을, 토지 소유자와 관계인에게는 재결신청청구권을 인정하고 있다.

II. 사업시행자의 재결신청권(토지보상법 제28조)**1. 의의 및 근거**

재결신청은 협의 불성립시 사업시행자가 토지수용위원회에게 수용 또는 사용의 재결을 구하는 절차 행위이다. 토지보상법 제28조에 근거를 둔다.

2. 요건 및 절차

① <재결신청권자> 재결신청권자는 오직 사업시행자 뿐이다. ② 재결은 협의 불성립시 관할 토지수용위원회에 하며, 토지보상법상 사업인정고시일로부터 1년 이내에 할 수 있다. 재결신청의무는 반드시 해야 하는 의무는 아니다. 재결신청기간이 경과하면 사업인정의 효력도 상실되므로 재결신청의 근거도 없어진다. 다른 개별법에서 재결신청기간이 특별히 규정되어 있다면 그 기간을 따르면 된다. 사업시행자의 재결신청을 기각하는 재결이 확정되었다 하더라도 재결신청기간의 제한규정에 저촉되지 않는 한 다시 재결신청을 할 수 있고, 토지수용위원회는 이에 근거하여 다시 수용재결을 할 수 있다.

3. 사업시행자에게만 재결신청권을 인정하는 이유

① 토지보상법 구조상 피수용자에게 재결신청권을 인정할 수 없고, ② 피수용자에게 재결신청권 부여시 공익사업 계획에 지장이 생길 우려가 있으며, ③ 목적물 취득권과 보상 의무는 사업시행자에게 있는 점, ④ 형평차원에서 피수용자에게 재결신청청구권(토지보상법 제30조)이 인정되는 점 등을 고려할 때, 사업시행자에게만 재결신청권을 인정함이 타당하다.

III. 피수용자의 재결신청청구권(토지보상법 제30조)**1. 의의, 취지, 법적성질**

① 재결신청청구권은 사업인정 후 협의가 성립되지 않을 경우 피수용자가 사업시행자에게 서면으로 재결신청을 조속히 할 것을 청구하는 권리이다. ② 수용의 법률관계의 조속한 확정을 통한 피수용자의 권익보호와 수용당사자간 공평의 원칙에 그 취지가 있다.

2. 요건, 내용, 형식, 청구기간

사업인정 후 협의 불성립시, 협의기간 만료일 이후 사업인정고시일로부터 1년 이내(재결신청기간 만료일)에 청구하여야 한다. 청구권자는 피수용자로 사업시행자에게 서면으로 청구한다. ① 협의 불성립·불능 시, ② 사업인정 후 상당 기간이 지나도록 사업시행자의 협의 통지가 없는 경우, ③ 협의 불성립이 명백한 경우에 협의기간 종료 전이라도 재결신청청구가 가능(판례)하다.

3. 효과

1) 사업시행자의 재결신청의무(법 제30조 제2항)

사업시행자는 재결신청청구 받은 날로 60일 내 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 한다. 판례는 협의 불성립이 명백한 경우 협의 기간 만료일부터 60일을 기산한다.

2) 사업시행자의 지연가산금 지급의무(법 제30조 제3항)

<지연가산금지급> 청구 받은 날로 60일 초과하여 재결신청 시, 토지수용위원회의 재결보상금에 지연된 기간에 대해 법정이율을 적용한 금액(지연가산금)을 가산하여 지급하여야 한다.

<물음 2> (15점)

I. 논점의 정리

A공사의 재결신청을 하지 않은 것이 부작위에 해당하는지 검토 후 불복방법으로 의무이행 심판, 부작위위법확인소송, 의무이행소송 등을 검토한다.

II. 부작위위법확인소송 제기 가능여부

1. 의의 (행정소송법 제4조 제3호)

부작위위법확인소송은 행정청의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 소송으로 행정청이 신청에 따른 일정 처분을 하여야 함에도 아무런 응답을 하지 않는 것이 위법하다는 확인을 구하는 소송이다.

2. 대상적격 충족여부

1) 부작위의 의의

부작위는 행정청이 당사자의 신청에 대해 상당한 기간 내 일정한 처분을 해야 할 법률상 의무가 있음에도 이를 하지 않는 것을 의미한다.

2) 당사자의 신청

부작위가 성립하기 위해서는 당사자의 신청이 있어야 하며, 판례는 당사자에게 법규상*조리상 신청권이 있어야 한다고 본다. 본 사안에서는 피수용자의 신청이 있었고, 토지보상법 제30조 제1항에서 법규상 신청권을 인정하고 있다.

3) 상당한 기간의 경과

부작위가 위법한 것이 되려면 당사자의 신청 후 상당한 기간이 경과하도록 행정청이 아무런 처분을 하지 않은 경우이어야 한다. 여기에서 <상당한 기간>이란 처분을 하기 위해서 통상 요구되는 기간을 의미하며, 처분의 성질·내용 등을 고려하여 판단하여야 한다. 본 사안에서는 상당한 기간이 경과한 것으로 보인다.

4) 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있을 것

토지보상법 제30조 제2항에서 사업시행자는 재결신청청구 받은 날로 60일 내 관할 토지수

용위원회에 재결을 신청하여야 한다고 규정하여 법률상 의무가 존재한다.

5) 아무런 처분을 하지 않을 것

피수용자의 신청에 대하여 사업시행자는 아무런 처분을 하고 있지 않다.

6) 소결

위 요건을 충족하여 사안의 부작위는 대상적격을 충족한다.

3. 그외 소송요건

그외 소송요건은 특별히 문제되지 않는 바, 충족된 것으로 본다. 따라서 부작위위법확인소송의 제기가 가능할 것이다.

Ⅲ. 취소소송 제기 가능여부

1. 의의(행정소송법 제4조 제1호)

행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송을 말한다.

2. 제기 가능여부

판례는 토지소유자나 관계인의 재결신청 청구에도 불구하고 사업시행자가 재결신청을 하지 않을 때 토지소유자나 관계인은 사업시행자를 상대로 거부처분 취소소송 또는 부작위위법확인소송의 방법으로 다투어야 한다고 판시한 바 있다. 사안의 재결신청을 하지 않은 것을 묵시적 거부처분으로 볼 경우, 취소소송의 방법으로 불복할 수 있다.

Ⅳ. 의무이행심판 (행정심판법 제5조 제3호)

의무이행심판이란 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대해 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판을 의미한다. A공사는 재결신청할 법률상 의무가 있으나 부작위하고 있으므로, 甲은 의무이행심판의 청구가 가능하다.

Ⅴ. 의무이행소송 등 가능성

① 의무이행소송이란 행정청의 거부처분 또는 부작위에 대하여 법상의 작위의무의 이행을 청구하는 소송을 말한다. ② 판례는 의무이행소송은 현행법상 허용되지 않는다고 하여 <부정설>의 입장이다. ③ 판례는 인정하고 있지 않으나, 의무이행소송이 인정된다면 가장 실효적인 권리구제수단이 될 것이다.

[문제4] 10점**I. 개설**

실효란 유효하게 성립한 행정행위가 객관적 사실의 발생으로 그 효력이 당연히 상실되는 것이다. 토지보상법상 실효제도는 크게 사업인정의 실효와 재결의 실효로 볼 수 있다.

II. 사업인정의 실효**1. 재결신청 해태로 인한 실효(법 제23조)**

사업시행자가 제22조 제1항에 따른 사업인정의 고시가 된 날부터 1년 이내에 제28조 제1항에 따른 재결신청을 하지 아니한 경우에는 사업인정고시가 된 날부터 1년이 되는 날의 다음 날에 사업인정은 그 효력을 상실한다.

2. 사업의 폐지·변경으로 인한 실효(법 제24조)

사업인정고시가 된 후 사업의 전부 또는 일부를 폐지하거나 변경함으로 인하여 토지 등의 전부 또는 일부를 수용하거나 사용할 필요가 없게 되었을 때 사업시행자의 신고 또는 시도지사의 판단에 따른 고시로, 고시가 된 날부터 그 내용에 따라 사업인정의 전부 또는 일부는 효력을 상실한다.

III. 사업인정 실효로 인한 손실보상(법 제9조5항~7항 준용)

① 사업인정의 효력이 상실되며 사업시행자는 사업인정이 실효됨으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실을 보상하여야 한다. ② 손실의 보상은 사업시행자와 피수용자가 협의하여 결정하며 협의 불성립 시 사업시행자나 피수용자는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다. ③ 즉, 피수용자에게 손실보상청구권이 있으며 이는 손실이 있음을 안 날부터 1년, 발생한 날부터 3년 이내 청구해야 한다.

1기 3주차 예시답안

【문제 1】 40점**I. 논점의 정리**

환매권의 법적 성질을 전제로 甲이 제기할 수 있는 소송수단을 검토하고, 토지보상법 제91조의 환매권 행사요건의 충족 여부 및 공익사업 변환 제도를 바탕으로 甲의 청구 인용 가능성을 검토한다.

II. 환매권의 법적 성질**1. 환매권의 의의**

공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우, 원소유자가 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 토지를 다시 취득할 수 있는 권리를 말한다.

2. 환매권의 근거**1) 이론적 근거**

원소유자가 사업시행자로부터 정당한 보상을 받았다 하더라도 자발적 의사에 기한 소유권 상실이지 아니므로 공익상 필요가 소멸한 경우 토지의 소유권을 회복해 주는 것이 <공평의 원칙>, <재산권 보장 이념>, <원소유자의 감정 존중>에 부합한다.

2) 실정법적 근거

① 헌법으로부터 직접 도출되는 권리라는 견해, ② 개별 법령의 근거가 있어야 한다는 견해가 있다. ③ 생각건대, 헌법 제23조 제1항은 재산권의 내용과 한계를 법률에 유보하고 있으므로 법률에 근거가 있어야 함이 타당하다.

3. 환매권의 법적 성질**1) 공권**

① 공권설은 환매권은 수용 등 공법적 원인에 의해 형성된 법률관계를 전제로 하는 공권이라 보며, 사권설은 환매권은 원소유자와 그 포괄승계인에게만 한정되고, 환매권자의 이익을 위해 행사하므로 사권으로 본다.

② 대법원의 주류적 입장은 환매권을 사권으로 보며, 헌법재판소도 환매권은 헌법소원심판의 대상이 되는 공권력의 행사로 볼 수 없다고 하였다.

③ 환매권은 공권력 행사의 주체인 사업시행자에게 행사하며, 그 구체적 발생요건이 되는 공공필요의 소멸 여부의 판단 역시 공익적 판단에서 비롯하므로 공권으로 봄이 타당하다.

2) 형성권

환매권은 환매기간 내에 환매의 요건이 발생하면 환매권자가 수령한 보상금 상당금액을 사업시행자에게 지급하고 일방적으로 의사표시를 함으로써 사업시행자의 의사에 관계없이 성립되는 <형성권의 일종>으로 보는 것이 타당하다.

3) 물권적, 채권적 효력설

① 환매권 행사로 물권적 효력이 발생한다고 보는 견해, 채권적 효력이 발생한다고 보는 견해가 있다. ② 판례는 환매권 행사는 채권적 효력으로서 소유권이전등기청구권이 발생하며, 10년의 소멸시효에 걸린다고 판시했다. ③ 환매권 행사만으로 소유권이 환매권자에게 이전되는 물권적 효력을 인정한다면 등기 없이 소유권이 변동되는 결과가 초래되므로 채권채무 관계를 발생시키는 채권적 효력설이 타당하다.

Ⅲ. 환매권 행사요건**1. 전부 또는 일부가 필요 없게 된 때****1) 토지보상법 제91조 제1항**

① 공익사업의 폐지*변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 토지의 취득일 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인은

② 사업의 폐지*변경으로 인한 경우에는 관계 법률에 따라 사업이 폐지*변경된 날, 그 밖의 사유로 인한 경우에는 사업완료일로부터, 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.

2) 구체적 의미

① <폐지*변경>이란 공익사업을 아예 그만두거나 다른 공익사업으로 바꾸는 것을 말한다.
 ② <필요 없게 된 때>란 취득 목적사업을 위해 취득한 토지가 사용할 필요 자체가 없어진 경우를 말하며, 필요 없게 되었는지는 사업시행자의 주관적인 의사를 표준으로 하는 것이 아니라 객관적·합리적으로 판단해야 한다.

2. 전부를 이용하지 않을 때**1) 토지보상법 제91조 제2항**

취득일로부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업에 이용하지 아니하였을 때에는 취득일로부터 6년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금 상당 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.

2) 구체적인 의미

① <전부>란 특정 환매권자의 해당 필지를 기준으로 판단해서는 안되고, 사업시행자가 취득한 토지의 전부를 기준해야 한다.
 ② <이용하지 아니하였을 때>란 사업에 이용할 필요가 없게 된 것이 아니라, 단지 사실상 사업에 제공되지 않은 경우를 말한다.

3. 토지보상법 제91조 제1항과 제2항의 관계

그 요건을 서로 달리하고 있으므로, 어느 한쪽 요건에 해당되면 다른 쪽의 요건을 주장할 수 없게 된다고 할 수 없고, 양쪽 요건에 모두 해당한다고 하여 더 짧은 제척기간을 정한 제2항에 의하여 제1항의 환매권 행사가 제한된다고 할 수도 없다.

4. 사안의 경우

근린공원 조성공사가 완료된 후 甲의 토지는 더 이상 근린공원으로 사용되지 않고 택지개발 사업에 제공되고 있다. 이는 토지보상법 제91조 제1항이 정한 그 밖의 사유로 취득한 토지가 당초 취득 목적사업에 필요 없게 된 경우에 해당하므로 甲의 환매권 행사요건은 충족된다.

IV. 공익사업 변환

1. 의의, 취지(토지보상법 제91조 제6항)

- ① 공익사업 변환이란 공익사업의 토지취득 후 다른 공익사업으로 변경된 경우 별도의 취득 절차 없이 다른 공익사업에 이용하도록 하는 제도이다.
- ② 공익사업을 위해 토지를 재취득하는 무용한 절차의 반복을 방지하기 위한 제도이다.

2. 요건

- ① 변환 전 사업주체는 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이어야 한다.
- ② 변환 전 공익사업은 사업인정을 받았어야 하고, 변환 후 공익사업은 공익성의 정도가 높은 토지보상법 제4조 제1호 내지 제5호의 공익사업으로 변경된 경우여야 한다.
- ③ 판례는 변환된 공익사업도 사업인정을 받거나 사업인정을 받은 것으로 의제되어야 한다고 본다.
- ④ 환매토지가 제3자에게 처분되지 않았어야 한다.

3. 사업시행자의 동일성 문제

1) 문제점

토지보상법 규정상 변경 전 사업시행자에 관한 규정은 존재하나, 변경 후 사업시행자가 누구인지에 대한 규정은 없기 때문에, 공익사업 변환이 사업시행자가 동일한 경우에만 인정될 수 있는 것인지 문제된다.

2) 학설

- ① 공익사업 변환은 그 인정 자체가 보다 높은 공익성을 갖는 사업으로의 전환을 의도하는 것이므로 사업시행자의 변경까지 제한하는 것은 아니어서 변경시에도 적용된다는 견해와
- ② 사업시행자 변경시 폐지된 공익사업시행자가 아무런 이유 없이 토지가액의 변동으로 차액을 얻게 되는 불합리함이 있으므로 동 규정은 적용할 수 없다는 견해가 있다.

3) 판례

대법원은 (구)토지수용법 등 관계 법령의 규정 내용이나 그 입법 이유 등으로 미루어 볼 때 공익사업 변환이 국가, 지방자치단체 또는 정부투자기관 등 사업시행자가 동일한 경우에만 허용되는 것은 아니라 한다.

4) 검토

- ① 공익사업 변환 제도는 공공필요의 소멸이라는 수용 본질의 한계상 인정되는 것으로 이러한 취지에 반하는 예외적 규정은 좁게 해석함이 국민의 권리구제에 유리하다.
- ② 또한 변환 규정에 의해 환매권이 형해화되는 결과를 초래할 우려가 있으므로, 사업시행자 변경시에는 공익사업 변환은 인정되지 않는 것으로 봄이 타당하다.

4. 사안의 경우

변환 전 근린공원 조성사업은 사업인정을 받은 공익사업이고, 사업시행자는 서울특별시로서 지방자치단체에 해당한다. 변환 후 공익사업은 토지보상법 제4조 제5호에 해당하는 사업이며, 이에 대한 실시계획 승인이 있어 사업인정을 받은 것으로 의제되는 공익사업에 해당한다. 다만, 변환 후 사업시행자가 서울특별시가 아닌 대한주택공사로 변경되었으므로, 사업시행자의 동일성이 인정되지 않아 공익사업 변환이 적용될 수 없다.

V. 甲의 소송수단 및 그 인용 가능성**1. 소송수단**

환매권은 공권으로서 공법상 당사자소송으로 해결해야 한다. 따라서 甲은 행정소송으로서 당사자소송을 제기해야 한다. 다만, 판례는 환매권을 사권으로 보고 민사소송으로서 소유권 이전등기청구소송 등으로 해결하고 있다.

2. 대항력(토지보상법 제91조 제5항)

환매권은 「부동산등기법」이 정하는 바에 따라 공익사업에 필요한 토지의 협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다. 환매권자가 제3자에게 대항할 수 있다는 것은 제3자에 대해 권리 주장을 할 수 있다는 것을 말한다.

3. 인용 가능성 여부

甲의 환매권 행사요건이 충족되며 사업시행자의 동일성이 인정되지 않아 공익사업 변환으로서 환매권 행사를 제한할 수 없다. 또한 甲의 환매토지는 수용의 등기가 되어 있으므로 제3자에게 대항할 수 있다. 따라서 甲의 당사자소송은 인용되는 것이 타당하다.

다만, 사업시행자의 동일성을 요구하지 않는 판례에 따르면 甲의 청구는 기각될 것이다.

[문제2] (30점)**(물음1) (20점)****I. 논점의 정리**

의견청취 절차를 거치지 않은 기업도시개발계획승인에 하자가 있음에도 이미 불가쟁력이 발생하였으므로, 그 하자를 수용재결 취소소송에서 다툴 수 있는지가 문제된다. 즉, 하자의 승계가 인정되는지 여부를 바탕으로 甲의 소송상 청구 인용 가능성을 검토한다.

II. 관련 행정작용의 법적 성질**1. 기업도시개발계획승인**

기업도시법 제14조에 제2항 따라 기업도시개발계획승인은 사업인정(의제)에 해당한다. 사업인정은 사업시행자에게 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 일정한 내용의 수용권을 설정해주는 형성적 처분이며, 재량행위이자 제3자효 행정행위의 성질을 가진다.

2. 수용재결

수용재결이란 사업인정고시 후 협의불성립*불능의 경우 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는 수용결정의 최종적 판단절차를 말한다. 수용재결은 수용권의 구체적 내용을 결정하는 형성적 처분의 성질을 가진다.

III. 기업도시개발계획승인의 위법 여부**1. 절차상 하자 유무**

기업도시법 제14조 제10항에 따라 토지 등의 수용 등에 관하여는 토지보상법이 준용되고, 토지보상법 제21조는 의견청취 절차를 규정한다. 따라서 의견청취 절차를 결여한 기업도시개발계획승인처분은 절차상 하자가 있다.

2. 절차적 하자의 독자적 위법사유

① 절차상의 하자가 독자적인 위법사유인지에 대해 긍정설, 부정설, 절충설(기속행위와 재량행위로 구별하는 학설)이 대립한다. ② 판례는 재량행위, 기속행위를 구별하지 않고 절차상 하자는 독자적인 위법사유가 될 수 있다고 본다. ③ 취소소송 등의 기속력이 절차의 위법을 이유로 하는 경우에도 준용되므로 긍정설이 타당하다.

3. 위법성의 정도

의견청취 절차의 결여는 일반인의 관점에서 외관상 명백하지만, 적법요건의 중대한 위반이라 보기 어려우므로 취소사유에 해당한다.

IV. 하자의 승계**1. 의의**

하자의 승계란 둘 이상의 행정행위가 연속적으로 행해지는 경우 선행행위의 위법이 후행 행정행위에 승계되어 후행 행위를 다툴 수 있는지에 대한 문제를 말한다.

2. 전제조건

① 선행행위와 후행행위가 모두 항고소송의 대상이 되는 처분일 것, ② 선행행위는 취소사유가 존재할 것, ③ 후행행위는 적법할 것, ④ 선행행위는 불가쟁력이 발생할 것이 요구된다.

3. 인정범위(하자승계 해결논의)

1) 학설

① 선행행위와 후행행위가 결합하여 하나의 법적 효과를 완성하는 경우에는 하자의 승계를 인정하는 하자승계론과 ② 선행행위가 후행행위에 대하여 구속력이 미치는 범위(한계)내에 서는 하자의 승계를 부정하는 구속력론이 대립한다.

2) 판례

① 원칙적으로 하자승계론에 따라 판단하고 있다.
 ② (ㄱ) 대집행절차상 계고*영장에 의한 통지*대집행의 실행*비용징수의 각 행위, (ㄴ)강제징수절차상 독촉*압류*매각*청산의 각 행위 사이에는 하자승계를 긍정하였다.
 ③ 반면 (ㄱ)표준지공시지가결정과 개별공시지가결정, (ㄴ)표준지공시지가결정과 조세부과처분, (ㄷ)건물철거명령과 대집행 계고, (ㄹ)사업인정과 수용재결 사이, (ㄴ) 재조사청구 조정결정 통지를 받은 개별공시지가결정과 과세처분 사이에는 하자승계를 부정하였다.
 ④ 다만, (ㄱ)개별통지가 없는 개별공시지가결정과 과세처분, (ㄴ)표준지공시지가결정과 재결(보상금증감청구소송)은 별개의 법적효과를 목적으로 함에도 불구하고, 예측가능성이 없고, 수인한도를 넘는 경우에는 하자승계를 긍정한 바 있다.

3) 검토

① 하자승계론은 일정한 기준을 제시하여 객관적이고, 구속력론은 예측 가능성과 수인 가능성을 고려한다는 점에서 구체적 타당성을 기할 수 있으므로 양자 모두 합리성이 인정된다.
 ② 따라서 하자승계론을 기준으로 예측가능성이 있는지, 수인한도를 넘는지 등의 사정을 종합 고려하여 하자승계 여부를 개별적*구체적으로 판단함에 타당하다.

4. 사안의 경우

(1) 전제조건

① 기업도시개발계획승인과 수용재결은 모두 처분이고, ② 선행행위에 취소사유가 있으며, ③ 선행행위는 제소기간이 도과하여 불가쟁력이 발생했고, ④ 특별한 사정이 없는 한 수용재결은 적법하므로 전제요건은 모두 충족한다.

(2) 인정범위

① 기업도시개발계획승인은 공익사업을 인정하고 사업시행자에게 수용권을 설정해주는 행위이며, 수용재결은 수용권의 구체적 내용을 결정하고 그 실행을 완성시키는 행위이므로 양자는 하나의 법률효과를 목적으로 하지 않는다. ② 또한 甲은 협의취득을 응하지 않았으며 수용재결이 있을 것을 예측할 수 있으므로 甲의 수인한도 및 예측가능성을 침해한다고 보기 어렵다. 따라서 하자의 승계가 인정되지 않는다.

V. 甲 청구의 인용 가능성

1. 관련 판례

사업인정과 수용재결에 대하여 판례는 사업인정 자체가 중대하고 명백하여 당연무효인 하자가 아닌 한, 이러한 하자는 수용재결의 선행처분인 사업인정 단계에서 다투어야 할 것이므로 그 쟁송기간이 이미 도과한 이후에 사업인정의 하자를 이유로 수용재결의 취소를 구할 수는 없는 것이라고 판시했다.

2. 결론

사안은 하자의 승계 전제요건은 충족되나 인정범위와 관련하여 하나의 법률효과를 목적으로 하지 않으며, 甲의 수인한도와 예측가능성을 침해하지 않으므로 하자의 승계는 부정된다. 따라서 후행처분인 수용재결에 대한 甲의 소송상 청구는 인용 가능성이 없다.

(물음2) (10점)

I. 논점의 정리

사업인정의 내용상 요건과 판례를 바탕으로 甲의 소송상 청구 인용 가능성을 검토한다.

II. 사업인정의 내용상 요건

① 토지보상법 제4조의 공익사업에 해당해야 하며, ② 공용수용을 할 만한 공익성과 필요성이 있어야 하고, ③ 사업시행자에게 해당 공익사업을 수행할 의사와 능력이 있어야 한다.

III. 사업인정과 수용재결의 관계

공용수용은 사업인정-협의-수용재결의 보통절차로 이루어진다. 사업인정에서 사업의 공공필요 및 사업시행자의 의사와 능력 등을 검토하며, 수용재결은 협의 불성립 시 수용권의 구체적인 내용을 결정하고 그 실행을 완성시키는 것이다.

IV. 관련 판례

판례는 공익사업이 공용수용을 할 만한 공익성을 상실하거나 사업인정에 관련된 자들의 이익이 현저히 비례의 원칙에 어긋나게 된 경우 또는 사업시행자가 해당 공익사업을 수행할 의사나 능력을 상실하였음에도 여전히 그 사업인정에 기하여 수용권을 행사하는 것은 수용권의 공익 목적에 반하는 수용권의 남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시했다.

V. 甲 청구의 인용 가능성

수용재결은 수용권의 구체적 내용을 결정하는 행위이므로, 수용재결 시에도 사업인정 요건인 사업시행자가 공익사업을 수행할 의사와 능력이 있어야 한다고 보는 것이 타당하다. 따라서 乙의 사업 수행능력을 상실한 상태에서 이루어진 수용재결은 수용권 남용에 해당한다. 중대명백설에 따르면 그 위법의 정도는 중대하기는 하나, 외견상 명백하다고 볼 수는 없으므로 취소사유에 해당하며 甲이 제기한 취소소송은 인용 가능하다.

【문제 3】 20점**I. 논점의 정리**

토지보상법 제16조에 따른 협의의 법적 성질과 동법 제89조 및 행정대집행법 제2조의 대집행 요건을 바탕으로 B의 자진철거 의무가 공법상 의무에 해당하는지와 B 주택에 대해 대집행을 할 수 있는지를 검토한다.

Ⅱ. 사업인정 전 협의(토지보상법 제16조)**1. 의의 및 취지**

- ① 협의란 사업시행자가 공익사업에 제공될 토지 등에 대한 권리를 취득하거나 소멸시키기 위해 토지소유자 및 관계인과 합의하는 것을 말한다.
- ② 수용 등에 의한 강제취득보다는 합의를 통해 토지 등을 취득함으로써 비례원칙을 지키고 공익사업의 신속한 진행에 취지가 있다.

2. 법적 성질

사업인정 전 협의의 법적 성질에 대해 사법상 계약으로 보는 견해, 공법상 계약으로 견해로 보는 견해가 있으나, 통설 및 판례는 사업시행자가 사경제주체로서 행하는 사법상 계약의 실질을 가지는 것으로 사법상 계약으로 본다.

Ⅲ. 대집행 요건**1. 의의 및 취지**

- ① 대집행이란 대체적 작위의무의 불이행에 대하여 당해 행정청이 스스로 또는 제3자로 하여금 의무를 이행하게 하고, 의무자에게 비용을 징수하는 제도를 말한다.
- ② 공익사업을 원활하게 시행하기 위한 의무이행 확보수단이다. 토지보상법 제89조에 근거 규정이 있으며, 토지보상법에서 규정되지 않은 것은 행정대집행법을 따른다.

2. 요건**1) 토지보상법상 요건(토지보상법 제89조)**

- ① 이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무를 이행하여야 할 자가 ② 그 정하여진 기간 이내에 의무를 이행하지 아니하거나 완료하기 어려운 경우 ③ 또는 그로 하여금 그 의무를 이행하게 하는 것이 현저히 공익을 해친다고 인정되는 사유가 있는 경우에는 ④ 사업시행자는 시·도지사나 시장·군수 또는 구청장에게 「행정대집행법」에서 정하는 바에 따라 대집행을 신청할 수 있다.

2) 행정대집행법상 요건(행정대집행법 제2조)

- ① 법률에 의하여 직접 명령되었거나 또는 법률에 의거한 행정청의 명령에 의한 행위로서 ② 타인이 대신하여 행할 수 있는 행위를 의무자가 이행하지 아니하는 경우 ③ 다른 수단으로써 그 이행을 확보하기 곤란하고 또한 ④ 그 불이행을 방지함이 심히 공익을 해할 것으로 인정될 때에는 ⑤ 당해 행정청은 스스로 의무자가 하여야 할 행위를 하거나 또는 제3자로 하여금 이를 하게 하여 그 비용을 의무자로부터 징수할 수 있다.

IV. B의 주택에 대한 대집행 가능성 여부

1. 관련 판례

판례는 협의 취득 시 건물소유자가 매매대상 건물에 대한 철거의무를 부담하겠다는 취지의 약정을 하였다고 하더라도 이러한 철거의무는 공법상의 의무가 될 수 없고, 이 경우에도 행정대집행법을 준용하여 대집행을 허용하는 별도의 규정이 없는 한 이와 같은 철거의무는 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되지 않는다고 판시했다.

2. 대집행 가능성 여부

대집행은 침익적 행위이므로 법률에 규정된 요건이 충족된 경우에만 허용된다. 사업인정 전 협의 및 자진철거 약정은 사법상 계약에 해당하므로 토지보상법 또는 토지보상법에 따른 처분으로 인한 의무가 아니며, 공법상 의무 불이행도 아니다. 따라서 대집행 요건을 충족하지 못하므로 B의 주택에 대해 대집행을 할 수 없다.

【문제 4】 (10점)**I. 의의**

- ① 약식절차란 토지의 수용 또는 사용에 관한 보통절차 가운데 그 일부를 생략하고 행하는 절차를 말한다.
- ② 천재지변 시 토지의 사용이란 천재지변이나 그 밖의 사변으로 공공의 안전을 유지하기 위한 공익사업을 긴급히 시행할 필요가 있을 때 특별자치도지사·시장·군수·구청장의 허가를 받아 타인의 토지를 사용할 수 있게 하는 약식절차이다(법38조).
- ③ 시급한 토지사용에 대한 허가란 공익사업이 진행되는 동안 재결이 지연됨으로써 재해를 방지할 수 없거나 공공의 이익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되는 경우 재결신청을 받은 토지수용위원회의 허가로서 토지를 사용할 수 있게 하는 약식절차이다(법39조).

II. 양자의 비교**1. 공통점****1) 취지 및 요건**

- ① 보통절차를 거칠 여유가 없는 경우 원활한 사업진행을 도모하는 데 취지가 있다.
- ② 공용사용의 경우에만 허용되며 관련 행정청의 허가 및 토지소유자 등에 대한 통지가 요구된다.

2) 사용기간, 효과, 보상의 특징

- ① 사용기간은 6월 이내이다. ② 사업시행자는 공용사용권을 취득하고, 사용기간 만료 시 반환 및 원상회복 의무를 부담하며, 대행·대집행 신청권을 가진다. 토지소유자는 토지 인도의 의무를 부담하며 손실보상청구권을 갖는다. ③ 토지보상법 제62조의 사전보상 원칙에 대한 예외로서 사후보상의 특징을 가진다.

2. 차이점**1) 허가권자 및 담보물 제공 여부**

- ① 천재지변 시 토지사용의 허가권자는 특별자치도지사·시장·군수·구청장이며 사업시행자는 담보를 제공하지 않아도 된다. ② 반면, 시급한 토지사용의 허가권자는 재결신청을 받은 토지수용위원회이며 사업시행자가 국가나 지방자치단체가 아닌 경우 담보를 제공해야 한다.

2) 손실보상

- ① 천재지변 시 토지 사용에 따른 손실보상은 토지보상법 제9조 제5항 내지 제7항을 준용하므로 사업시행자와 손실을 입은 자의 협의 절차로 보상액을 결정하며, 협의 불성립 시 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다. ② 반면, 시급한 토지 사용에 따른 손실보상은 토지보상법 제41조에 따라 토지소유자 등이 청구하면 협의 절차 없이 사업시행자가 산정한 보상금을 지급해야 하며 재결에 따른 보상금 지급시기까지 이를 지급하지 않으면 토지소유자 등은 담보를 취득한다.

1기 4주차 예시답안

【문제 1】 30점**(물음 1)****I. 손실보상의 개요****1. 의의 및 취지**

행정상 손실보상이란 공공필요에 의한 적법한 공권력 행사로 인하여 개인의 재산권에 가해진 특별한 희생에 대하여, 사유재산권 보장과 공평부담의 차원에서 행정주체가 행하는 조절적인 재산적 보상을 말한다.

2. 근거

- ① 이론적 근거는 공익을 위해 특정 개인의 재산권에 가해진 특별한 희생을 공평부담의 원칙에 따라 사회 전체가 부담해야 한다는 데 있다.
- ② 실정법적 근거는 헌법 제23조 제3항과 손실보상에 관해 일반법적 지위를 가지는 토지보상법 및 각 개별법령에 규정되어 있다.

3. 손실보상청구권의 법적 성질

- ① 손실보상청구권의 원인행위가 공권력 작용이라는 점에서 공권으로 보는 견해와, 그 법률관계가 사법상 채권·채무관계라는 점에서 사권으로 보는 견해가 대립한다.
- ② 대법원은 종전에 사권으로 보았으나, 하천법과 관련된 전원합의체 판결에서 공권으로 보았고, 토지보상법에 따른 손실보상청구권 역시 공법상 권리로 본다.
- ③ 손실보상청구권은 공권력의 행사로 인해 발생한 권리이므로 공권으로 봄이 타당하다.

II. 손실보상의 요건**1. 공공필요****1) 개념**

- ① 공공필요는 전형적인 불확정개념으로서, 헌법재판소는 이를 국민의 재산권을 그 의사에 반하여 강제적으로라도 취득해야 할 공익적 필요성으로 이해하여 왔다.
- ② 공공필요는 기본권의 일반적 제한요건인 공공복리보다 엄격한 개념이다.

2) 공공필요의 판단

구체적인 사안에서 공용침해를 통해 얻게 되는 공익과 재산권을 침해하는 사인의 이익을 비교형량에서, 공용침해를 정당화할 정도의 공익의 우월성이 인정되어야 한다.

3) 공공성의 확대화 경향

오늘날에는 공공성 개념이 복지국가주의의 요청, 행정수요의 증대 등으로 인해 그 개념이 확대되고 있는 추세이다.

2. 공권력에 의한 적법한 침해

1) 공권적 침해

- ① 공권력 주체에 의하여 직접적으로 의도된 재산권에 대한 침해가 있어야 한다. 따라서 비의도적 침해의 경우에는 수용적 침해의 법리가 적용된다.
- ② 손실보상이 인정되기 위해서는 재산권에 대한 침해가 현실적으로 발생하고 공익사업과 손실 사이에 상당한 인과관계가 있어야 한다.

2) 적법한 침해

- ① 적법한 침해란 법률에 근거한 침해를 의미한다. 여기서 법률은 형식적 의미의 법률을 의미한다. ② 불법행위로 인한 손해는 손실보상이 아니라 손해배상의 문제가 된다.

3. 재산권에 대한 침해

- ① 재산권이란 소유권 뿐만 아니라 법에 의하여 보호되고 있는 재산적 가치가 있는 일체의 권리를 말한다. ② 재산가치는 현존하는 것이어야만 하므로, 기대이익은 포함되지 않는다.

4. 특별한 희생

1) 의의 및 문제점

- ① 손실보상이 인정되려면, 그 침해로 인한 손실이 특별한 희생에 해당하여야 한다.
- ② 다만, 구체적인 경우에 있어서 어떤 손실이 보상을 요하는 특별한 손실인지, 보상을 요하지 않는 사회적 제약인지 구분이 문제된다.

2) 학설

(1) 형식적 기준설

- ① 침해행위의 인적범위를 특정할 수 있는지 여부를 기준으로 판단한다.
- ② 즉, 재산권에 대한 침해가 특정인 또는 한정된 범위의 사람에게 가해진 경우에는 특별한 희생에 해당하고, 재산권 침해가 일반적으로 행해지면 사회적 제약에 해당한다고 본다.

(2) 실질적 기준설

a. 의의

실질적 기준설은 재산권을 침해하는 행위의 실질적 내용(침해의 본질성 및 강도)에 따라 공용수용의 개념을 규정하려고 하는 이론이다.

b. 종류

- ① 보호가치가 있는 재산권에 대한 침해만을 보상을 요하는 특별한 희생으로 보는 <보호가치성설>, ② 재산권의 본질인 배타적 지배를 침해한 것은 수인 한도를 넘는 것으로 특별한 희생에 해당한다고 보는 <수인한도설>, ③ 재산권의 침해가 종래 재산권의 이용목적에 침해하는 경우에 특별한 희생으로 보는 <목적위배설>, ④ 재산권의 사적 효용을 본질적으로 침해하는 경우에는 특별한 희생에 해당한다고 보는 <사적효용설>, ⑤ 재산권마다 그 위치나 상황이 다를 수 있으므로 보상 여부 결정에 있어서도 구체적인 상황을 고려하여야 한다는 <상황구속성설>, ⑥ 재산권 침해의 중대성과 정도를 기준으로 특별희생인지를 판단하는 <중대성설> 등이 있다

3) 판례**(1) 대법원**

(구)도시계획법상 개발제한구역지정으로 인한 토지소유자의 재산권행사의 제한은 사회적 제약에 불과하다고 보았다.

(2) 헌법재판소

① 개발제한구역 지정으로 인한 개발가능성 소멸과 그에 따른 지가하락은 토지소유자가 감수해야 하는 사회적 제약이라고 판시하였다.

② 그러나 토지를 종래의 목적으로도 사용할 수 없거나 실질적으로 토지의 사용·수익의 길이 없는 경우 등 사회적 제약의 한계를 넘는 가혹한 부담이 발생하는 예외적인 경우에도 보상규정을 두지 않은 것은 비례의 원칙에 위반되어 헌법에 위반된다고 판시하였다.

4) 검토(복수기준설)

① 우리나라의 통설은 형식적 기준설과 실질적 기준설을 종합하여 특별한 희생과 사회적 제약을 구별하여야 한다고 본다.

② 형식적 기준설에 따라 재산권의 침해가 특정 범위의 사람에 대하여 가해진 것인지 여부와, 실질적 기준설에 따라 침해의 본질성 및 강도를 고려하여 특별한 희생인지 여부를 판단해야 한다.

5. 보상규정의 존재

개별법률에서 손실보상에 관한 규정이 있어야 공용침해에 대한 손실보상이 가능하다.

Ⅲ. 사안의 경우

청정자연보호구역 지정 및 폐수 배출허용기준의 강화는 ① 환경보전으로서 공공필요에 의한 ② A도지사의 적법한 공권력 행사이다. ③ 이로 인해 甲의 재산권이 침해되었다. ④ 그 침해는 B지역 내 제조업자에게 특정적으로 가해졌고, 수질정화시설을 갖추는 데 과도한 비용이 소요되어 수인하기 어렵다는 점을 고려할 때 사회적 제약을 넘는 특별한 희생에 해당한다. ⑤ 다만, 손실보상에 관한 규정은 존재하지 않는다.

(물음 2)**I. 논점의 정리**

甲에게 공공필요에 의한 재산권에 대한 적법한 공권력 행사로 특별한 희생이 발생하였음에도 보상규정이 없는 경우 손실보상을 받을 수 있는지가 문제된다. 이에 따라 보상규정 흠결 시 손실보상이 가능한지를 바탕으로 甲 주장의 타당성을 검토한다.

Ⅱ. 보상규정 흠결 시 손실보상 가능성**1. 학설****1) 직접효력설**

헌법 제23조 제3항이 직접 국민에 대하여 효력을 가진다고 보아, 개별규정에 보상규정이 없는 경우에도 헌법 제23조 제3항을 직접 근거로 하여 손실보상을 청구할 수 있다고 한다.

2) 방침규정설

헌법 제23조 제3항은 규범적 효력은 없고 단지 입법자에 대한 입법방침규정에 불과하므로 보상규정을 둘 것인가 하는 문제는 입법자의 재량판단의 문제라고 본다. 따라서 보상규정이 없으면 손실보상을 청구할 수 없다고 한다.

3) 위헌무효설

헌법 제23조 제3항을 불가분조항으로 보아 공용침해를 규정하면서 보상규정을 두지 않은 법률은 위헌으로 무효이고, 그에 근거한 공용침해행위는 위법한 직무행위가 되므로, 그 경우 「국가배상법」에 의거한 손해배상 청구만 가능하고 직접 헌법규정에 근거하여 손실보상을 청구할 수는 없다고 한다.

4) 보상입법부작위 위헌설

공공필요를 위하여 공용침해를 규정하면서 손실보상규정을 두지 않은 경우 그 공용침해규정 자체는 헌법에 위반되는 것은 아니고, 손실보상을 규정하지 않은 입법부작위가 위헌이라고 한다.

5) 유추적용설

공용침해에 따르는 보상규정이 없는 경우에는 헌법 제23조 제1항(재산권 보장규정) 및 제11조(평등원칙)를 근거하여 헌법 제23조 제3항 및 관계규정을 유추적용하여 손실보상을 청구할 수 있다고 한다.

2. 판례**1) 대법원**

최근 대법원은 유추적용설 입장에서 공용침해로 인한 특별한 손해에 대해 보상규정이 없는 경우 관련 보상규정을 유추적용하여 손실보상을 하여야 한다고 판시하고 있다.

2) 헌법재판소

개발제한구역 지정으로 토지소유자에게 사회적 제약의 범위를 넘는 가혹한 부담이 발생하는 예외적인 경우에도 보상규정을 두지 않은 것은 위헌성이 있는 것이고, 보상의 구체적인 기준과 방법은 입법자가 정할 사항이라고 판시하였다. 이는 위헌무효설을 취한 것으로 평가되기도 한다.

3. 검토

현행 헌법 제23조 제3항이 정당보상의 원칙을 선언하고 있고, 정당보상액을 법원이 결정할 수 있으므로 국민의 권리구제의 실효성을 위하여 <직접효력설>이 타당하다.

Ⅲ. 甲 주장의 타당성

직접효력설에 따라 청정자연보호구역의 지정 및 관리에 관한 법률에 보상규정이 없더라도 甲은 헌법 23조 3항을 직접 근거로 하여 손실보상을 청구할 수 있다. 따라서 甲의 주장은 타당하다.

【문제 2】 20점

I. 헌법 제23조의 내용

- ① 헌법 제23조 제1·2항은 재산권의 내용과 한계에 대해서 규정하고 있으므로 <내용규정>이라고 하고, 제3항은 공용침해가 있는 경우 손실보상이 필요하다고 규정하고 있으므로 <공용침해규정>이라고 한다.
- ② 제2항에서는 재산권에 사회적 제약이 가해지는 경우에는 보상이 필요없으나, 제3항에서 공용침해로 인해 특별한 희생이 발생하는 경우에는 손실보상이 필요하다고 규정하고 있다.
- ③ 그러나 현실적으로 재산권에 대한 어떠한 제한이 사회적 제약인지 특별한 희생인지 구별이 쉽지 않다.
- ④ 이에 이를 구분하기 위한 이론이 <경계이론과 분리이론>이다.

II. 경계이론

1. 의의

경계이론은 재산권의 사회적 제약과 공용침해는 서로 분리된 별개의 제도가 아니라 <재산권 침해의 정도>에 따라 경계 지어진 것에 불과하다고 보는 견해이다.

2. 사회적 제약과 특별한 희생의 구분

보상이 필요하지 않은 사회적 제약에 해당하는 재산권 침해의 경우에도 재산권 침해가 일정 정도를 넘어서게 되면 특별한 희생이 되어 보상이 필요한 공용침해로 전환된다.

3. 재산권의 가치보장에 중점

사회적 제약을 벗어나는 침해에 의해 특별한 희생이 발생하면 보상규정의 유무를 불문하고 보상이 따라야 한다고 본다.

III. 분리이론

1. 의의

분리이론은 재산권에 대한 사회적 제약과 공용침해를 완전히 서로 독립된 제도로 보아, 양자를 재산권 제한의 정도가 아니라 <입법의 형식과 목적>에 의해 구분한다.

2. 위헌심사기준

위헌심사의 기준도 재산권의 내용규정(사회적 제약)은 일반적인 기본권제한 법률과 마찬가지로 비례의 원칙, 평등의 원칙 등을 기준으로 위헌여부를 판단하지만, 공용침해규정은 공공 필요, 정당한 보상 등 헌법 제23조 제3항이 정하고 있는 요건만을 기준으로 판단한다.

3. 사회적 제약이 수인한계를 넘으면 위헌성

분리이론에 따르면 재산권의 사회적 제약이 경우에 따라 과도한 침해(수용적 효과)를 가져 오더라도 이로 인하여 그것이 공용침해로 전환되어 개인에게 보상이 필요한 것이 아니고, 그러한 규정이 비례의 원칙, 평등의 원칙 등을 위반한 경우에 위헌·위법이 되는 것이다.

4. 재산권의 존속보장에 중점

재산권에 대한 위헌적 침해의 경우에는 침해행위를 배척함으로써 재산권의 존속자체를 원칙적으로 보장해야 한다는 입장이다.

IV. 판례의 입장

1. 대법원

종래 우리 대법원은 경계이론의 입장이라고 보았으나, 최근에는 분리이론을 따르고 있다는 견해도 제기되고 있다.

2. 헌법재판소

- ① 개발제한구역지정으로 인한 토지소유자의 재산권행사의 제한에 대해, 사회적 제약을 넘는 가혹한 부담을 가져오는 예외적인 경우에는 보상규정을 두지 않은 것이 비례원칙에 위반되어 위헌이라고 헌법불합치결정을 한 바 있다.
- ② 재산권 침해와 공익간의 비례성을 다시 회복하기 위해서 보상규정을 두어야 하고, 반드시 금전보상을 해야 하는 것은 아니고 토지매수청구권과 같은 방법도 사용할 수 있다고 판시하였다.

【문제 3】 20점**I. 개설**

- ① 토지수용위원회의 재결에 대한 불복절차로 이의신청과 행정소송이 인정된다.
- ② 수용재결 또는 이의재결에 대한 불복에는 수용 자체를 다투는 경우와 보상액을 다투는 경우가 있다.
- ③ 불복이 수용 자체를 다투는 것인 때에는 재결에 대하여 이의신청(토지보상법 제83조), 취소소송 또는 무효확인소송을 제기하고(동법 제85조 제1항), 보상금의 증감을 청구하는 것인 때에는 이의신청과 보상액의 증감을 청구하는 소송을 제기하여야 한다(동법 제85조 제2항).
- ④ 甲은 토지보상액에 대해 불복하는 경우이므로 이의신청 또는 보상금증액청구소송을 제기할 수 있다.

II. 이의신청**1. 의의 및 성격(특별법상 행정심판, 임의전치주의)**

- ① 관할토지수용위원회의 위법부당한 재결에 불복이 있는 토지소유자 및 사업시행자가 중앙토지수용위원회에 이의를 신청하는 것으로서 특별법상 행정심판에 해당한다.
- ② 따라서 특별법인 토지보상법에 행정심판의 규정이 있으면 먼저 적용되며, 그 외 사항은 일반법인 행정심판법이 적용된다.
- ③ 종래에는 이의신청절차가 행정심판전치주의인지에 대하여 논란이 있었으나, 토지보상법 제83조에서 <~할 수 있다>고 규정하여 임의주의적 성격을 갖는다.

2. 요건

- ① 중앙토지수용위원회의 재결에 이의가 있는 자는 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다.
- ② 지방토지수용위원회의 재결에 이의가 있는 자는 해당 지방토지수용위원회를 거쳐 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다.
- ③ 이의의 신청은 재결서의 정본을 받은 날부터 30일 이내에 하여야 하는데, 판례는 30일의 불복기간은 토지수용의 특수성, 전문성을 고려하여 수용의 신속을 기한 것으로 국민의 재판을 받을 권리를 제한한 것이 아니라고 하였다.

3. 이의신청에 대한 재결(동법 제84조)

- ① 중앙토지수용위원회는 수용재결이 위법 또는 부당하다고 인정할 때에는 그 재결의 전부 또는 일부를 취소하거나 보상액을 변경할 수 있다.
- ② 보상금이 늘어난 경우 재결서 정본을 받은 날로부터 30일 이내에 사업시행자는 증액된 보상금을 지급 또는 공탁해야 한다.

4. 재결의 효력

- ① 쟁송기간 도과 등으로 이의재결의 확정시 민사소송법상의 확정판결이 있는 것으로 보고 재결서 정본은 집행력 있는 판결의 정본과 동일한 효력을 갖는 것으로 본다(동법 제86조).
- ② 이의신청은 사업의 진행 및 토지의 사용·수용을 정지시키지 아니한다(동법 제88조).

5. 대상

- ① 이의신청의 대상은 토지수용위원회의 제34조에 따른 재결이다.
- ② 토지수용위원회의 재결은 수용재결부분과 보상재결부분으로 분리될 수 있는데, 수용재결과 보상재결 중 한 부분만에 대하여 불복이 있는 경우에도 토지수용위원회의 재결 자체가 이의신청의 대상이 된다.

Ⅲ. 보상금증감청구소송

1. 의의 및 취지

보상금증감청구소송이란 수용재결 중 보상금에 대하여서만 이의가 있는 경우에 보상금의 증액 또는 감액을 청구하는 소송을 말한다. 이는 분쟁의 일회적 해결 및 권리구제의 신속성·실효성 확보하는 데 취지가 있다.

2. 소송의 성질

1) 형식적 당사자 소송

보상금증감청구소송은 기본적으로 보상금액을 다투는 소송이며 소송을 제기함에 있어 재결청을 피고로 하는 것이 아니라 그 법률관계의 일방 당사자를 피고로 하는 소송에 해당하게 되므로 형식적 당사자소송이라 할 것이다.

2) 확인·급부 소송

- ① ㉠ 보상금증감청구소송을 재결에서 정한 보상액의 취소·변경을 구하는 형성소송으로 보는 견해, ㉡ 보상금증감청구소송을 정당보상액을 확인하고 금전지급을 명하거나 과부된 부분을 되돌려 줄 것을 명하는 확인·급부 소송이라는 견해가 대립된다.
- ② 보상당사자 사이에서 보상금의 증감에 관한 분쟁을 종국적으로 해결하도록 한 입법취지를 고려하고, 분쟁을 일회적으로 해결하도록 한 취지 등을 고려할 때, 확인·급부소송으로 봄이 타당하다.

3. 소송의 대상

- ① 재결로 형성된 법률관계인 보상금의 증감에 관한 것을 소송의 대상으로 삼아야 하며 보상금의 증감에 관한 사항 외에는 소송의 대상이 될 수 없다.
- ② <원재결로 형성된 법률관계인 보상금의 증감>에 관한 것을 소송의 대상으로 삼아야 한다.

4. 소제기의 요건

- ① 관할 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자 또는 관계인이 소송을 제기하는 경우에는 사업시행자를 피고로, 사업시행자가 소송을 제기하는 경우에는 토지소유자 또는 관계인을 피고로 하여, ② 재결서를 받은 날로부터 90일 이내에, 이의신청을 거친 경우에는 이의재결서를 받은 날로부터 60일 이내에 피고의 소재지를 관할하는 행정법원 또는 토지소재지 관할 행정법원에 소송을 제기할 수 있다.

5. 소송의 범위(심리범위)

손실보상금의 증감, 손실보상의 방법, 보상면적 등이 법원의 심리 범위가 되며, 판례는 잔여지 수용청구권은 형성권적 성질을 가지므로 잔여지 수용청구를 거부한 재결에 대해 보상금의 증감에 관한 소송으로 다투어야 한다고 본다.

6. 입증책임

당사자소송에 있어서 입증책임은 민사소송법상 일반원칙에 따라 분배된다고 보는 것이 일반적이다. 그러나 대법원은 보상금증감청구소송에 있어서 재결에서 정한 보상금액보다 정당한 손실보상액이 많다는 점에 대한 입증책임은 원고에게 있다고 판시하고 있다.

7. 보상항목간의 유용

개인별 총액으로서 보상액의 당부를 소송물로 보아 보상항목간 유용을 허용함이 합리적이다. 판례 또한 보상항목 상호간의 유용을 허용하여 과다 부분과 과소 부분을 합산하여 보상금의 합계액을 결정하여야 한다고 본다.

【문제 4】 20점

I. 개발이익 배제

1. 의의

① 개발이익란 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시되거나 공익사업의 시행, 그 밖에 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행하여진 토지이용계획의 설정·변경·해제 등으로 인하여 토지소유자가 자기의 노력에 관계없이 지가가 상승되어 현저하게 받은 이익으로서 정상지가 상승분을 초과하여 증가된 부분을 말한다.(표준지 조사 평가기준 제2조 제2호).

② 개발이익 배제란 보상금 산정 시 해당 공익사업으로 인한 토지 등의 가격 변동을 고려하지 않는 것을 말한다.

2. 취지 및 필요성

개발이익은 피수용자인 토지소유자의 노력이나 자본에 의해발생한 것이 아니므로 형평의 관념상 토지소유자에게 당연히 귀속될 객관적 가치가 아니라, 투자자인 사업자 및 궁극적으로 국민 전체에게 귀속되어야 할 이익이라는 데 취지가 있다.

3. 개발이익의 범위와 한계

대법원은 당해 사업과 관계없는 다른 사업의 시행으로 인한 개발이익은 이를 배제하지 않는 가격으로 평가해야 한다고 판시하고 있다.

4. 개발이익 배제의 내용

1) 적용공시지가의 적용(사업인정고시일 전 공시지가 기준)

토지보상법이 사업인정고시일 전의 공시지가를 기준으로 보상액을 결정하는 것으로 하고 있는 것은 손실보상에서 공익사업으로 인한 개발이익을 배제하기 위한 것이다.

2) 해당 공익사업으로 인한 가격변동 배제

① 보상액을 산정할 경우에 해당 공익사업으로 인하여 토지 등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다(토지보상법 제67조 제2항).

② 보상액을 산정함에 있어서 당해 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 않는 지역의 지가변동률을 참작하여야 한다(동법 제70조 제1항).

3) 변경되기 전의 용도지역을 기준

공법상 제한을 받는 토지에 대하여는 제한받는 상태대로 평가하되, 그 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 기준으로 평가하여 개발이익을 배제한다(시행규칙 제23조 제1항).

II. 개발이익 배제의 정당보상 합치여부

1. 문제점

토지보상법상 개발이익 배제가 헌법 제23조 3항의 정당보상원칙에 위반되는지에 관하여 견해가 대립한다.

2. 학설

1) 위헌설

주변토지소유자와 피수용자 사이의 형평성이 심히 침해되고, 개발이익이 배제된 보상금으로는 도저히 종전과 같은 생활을 유지할 수 없는 경우 등에는 개발이익을 일체 보상하지 않는 것이 헌법상의 재산권보장 및 평등원칙에 위배된다고 본다.

2) 합헌설

개발이익은 국가 등의 공공투자 또는 사업시행자의 투자에 의해 발생하는 것으로서 피수용자의 노력이나 자본에 의해 발생하는 것이 아닌 불로소득이므로, 그러한 개발이익은 형평의 관념에 비추어 볼 때, 토지소유자에게 귀속시키는 것은 타당하지 않다고 보는 견해이다.

3. 판례

1) 대법원

대법원은 개발이익을 배제한 보상액 산정이 타당하다는 입장을 유지해 오고 있다. 개발이익을 배제하고 손실보상액을 평가하는 것이 정당보상의 원리에 합당하다거나, 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 계획의 승인·고시로 인한 가격변동은 고려하지 아니하여야 한다고 한다.

(2) 헌법재판소

공익사업의 시행으로 지가가 상승하여 발생하는 개발이익은 기업자의 투자에 의하여 발생하는 것으로서 피수용자인 토지소유자의 노력이나 자본에 의하여 발생한 것이 아니므로, 오히려 투자자인 기업자 또는 궁극적으로는 국민 모두에게 귀속되어야 할 성질의 것이라라고 판시한 바 있다.

4. 검토

개발이익은 피수용자의 노력이나 자본 투자에 의해 발생하는 것 아니므로 토지소유자에게 귀속시키는 것은 타당하지 않으며 사회로 귀속시켜야 하는 점을 고려할 때 합헌설이 타당하다.

Ⅲ. 결론

개발이익 배제는 헌법상 정당보상 개념에 합치한다. 다만, 현실적으로 피수용자와 사업시행 주변지역 토지소유자간 형평성 문제가 제기된다. 따라서 공익사업시행지 주변 토지의 개발이익을 환수하는 법제도를 정비하여야 할 필요성이 있다.

【문제 5】 10점**I. 정당보상****1. 문제점**

- ① 헌법 제23조 제3항은 <공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다>고 규정하고 있다.
- ② 정당한 보상이 무엇을 의미하는가에 관하여 학설상 견해의 대립이 있다.

2. 학설**1) 완전보상설**

- ① 공용침해로 인하여 발생한 객관적 손실 전부를 보상하여야 한다는 견해이다.
- ② 일반적으로 완전보상은 피침해재산의 객관적 가치의 보상과 함께 부대적 손실의 보상도 포함하는 것으로 이해하고 있다.
- ③ 오늘날에서는 생활보상도 포함시키고자 하는 견해가 새롭게 제기되고 있다.
- ④ 단, 정신적 손해와 개발이익은 완전보상에 포함되지 않는다.

2) 상당보상설

- ① 재산권의 공공복리 적합의무의 관점에서 공·사익을 형량하여 보상내용이 결정되어야 한다는 견해이다.
- ② 완전보상을 원칙으로 하되 합리적인 이유가 있는 경우에는 완전보상을 하회할 수도 있다는 입장이다.

3) 절충설

정당한 보상이 상황에 따라 완전보상 또는 상당보상일 수 있다는 견해이다.

3. 판례

- ① <대법원>은 보상의 시기·방법 등에 어떠한 제한도 없는 완전한 보상을 의미한다고 하였다.
- ② <헌법재판소>는 완전보상이란 원칙적으로 피수용재산의 객관적인 재산가치를 완전하게 보상하는 것으로서, 보상금액뿐만 아니라 보상의 시기나 방법 등에 있어서도 어떠한 제한을 두어서는 아니 된다는 것을 의미한다고 하였다.

4. 검토

- ① 헌법 제23조 제3항의 정당보상이 상황에 따라 완전보상을 하회할 수 있다는 상당보상설은 평등원칙에 위배될 소지가 있다.
- ② 따라서 피침해자의 재산적 가치를 완전하게 보상하는 완전보상설이 타당하다.

II. 정당보상 의미의 확대

- ① 보상대상은 일반적으로 당해 재산권에 대한 보상으로 이해되어 왔다.
- ② 손실보상 이론에 사회복지국가 이념이 도입됨에 따라 보상은 부대적 손실까지 포함하는 재산권보상은 물론 피수용자의 생활안정까지 확대하여 생활보상도 포함해야 한다는 주장이 일반화되고 있다.

1기 5주차 예시답안

【문제 1】 50점**(물음1) (20점)****I. 논점의 정리**

토지보상법상 손실보상의 원칙을 설명하고, 토지보상법 시행규칙 제24조를 바탕으로 사안 토지의 보상평가기준에 대해 검토한다.

II. 손실보상의 원칙**1. 사업시행자 보상(토지보상법 61조)**

공익사업에 필요한 토지 등의 취득 또는 사용으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실은 사업시행자가 보상해야 한다.

2. 사전보상(동법 62조)

사업시행자는 해당 공익사업을 위한 공사에 착수하기 이전에 토지소유자와 관계인에게 보상액의 전액을 지급해야 한다. 다만, 제38조에 따른 천재시변 시의 토지 사용과 제39조에 따른 시급한 토지 사용의 경우 또는 토지소유자 및 관계인의 승낙이 있는 경우에는 그렇지 않다.

3. 현금보상(동법 63조)

손실보상은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 현금으로 지급해야 한다. 다만, 토지소유자가 대토보상을 원하는 경우로서, 사업시행자가 해당 공익사업의 합리적인 토지 이용계획과 사업계획 등을 고려하여 토지로 보상이 가능한 경우에는 토지소유자가 받을 보상금 중 현금 또는 채권으로 보상받는 금액을 제외한 부분에 대해 해당 공익사업의 시행으로 조상한 토지로 보상할 수 있다.

4. 개인별 보상(동법 64조)

손실보상은 토지소유자나 관계인에게 개인별로 하여야 한다. 다만, 개인별로 보상액을 산정할 수 없을 때에는 그렇지 않다.

5. 일괄보상(동법 65조)

사업시행자는 동일한 사업지역에 보상시기를 달리하는 동일인 소유의 토지 등이 여러 개 있는 경우 토지소유자나 관계인이 요구할 때에는 한꺼번에 보상금을 지급하도록 해야 한다.

6. 사업시행 이익과의 상계금지(동법 66조)

사업시행자는 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부를 취득하거나 사용하는 경우 해당 공익사업의 시행으로 인하여 잔여지의 가격이 증가하거나 그 밖의 이익이 발생한 경우에도 그 이익을 그 취득 또는 사용으로 인한 손실과 상계할 수 없다.

7. 시가보상 (동법 67조 제1항)

보상액의 산정은 협의에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다.

8. 개발이익 배제(동법 67조 제2항)

보상액을 산정할 경우에 해당 공익사업으로 인하여 토지 등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 않는다.

Ⅲ. 토지의 보상평가기준

1. 헌법상 기준

헌법 제23조 제3항은 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용·제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급해야 한다고 규정한다. 정당한 보상의 의미에 대해 완전보상설, 상당보상설, 절충설이 있다. 피수용재산의 객관적 재산가치를 완전하게 보상하고, 보상의 시기·방법 등에 어떠한 제한도 없는 완전한 보상을 의미한다고 보는 완전보상설이 타당하며 판례도 이를 취한다.

2. 토지보상법상 기준

(1) 공시지가 기준 평가 및 현황 기준 평가

- ① 취득하는 토지를 평가함에 있어서는 평가대상토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 이상의 표준지공시지가를 기준으로 한다(동법 70조 1항, 동법 시행규칙 22조 1항).
- ② 가격시점의 현실적인 이용상황과 일반적인 이용방법에 의한 객관적 상황을 고려하여 산정하되, 일시적인 이용상황과 주관적 가치 및 특별한 용도에 사용할 것을 전제로 한 경우 등은 고려하지 않는다(동법 70조 2항).

(2) 개별평가

토지에 건축물 등이 있는 경우에는 토지와 건축물 등을 각각 평가해야 한다. 다만, 건축물 등이 토지와 함께 거래되는 사례나 관행이 있는 경우에는 그 건축물 등과 토지를 일괄하여 평가해야 하며, 이 경우 보상평가서에 그 내용을 기재해야 한다(동법 시행규칙 20조)

(3) 건축물 등이 없는 상태 기준 평가

토지에 건축물 등이 있는 때에는 그 건축물 등이 없는 상태를 상정하여 토지를 평가한다(동법 시행규칙 22조 2항).

3. 무허가건축물등의 부지 또는 불법형질변경된 토지(현황 기준 평가의 예외)

무허가건축물등의 부지 또는 불법형질변경토지에 대하여는 무허가건축물등이 건축 또는 용도변경될 당시 또는 토지가 형질변경될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다(동법 시행규칙 24조). 다만, 1989년 1월 24일 당시의 무허가건축물등, 1995년 1월 7일 당시 공익사업시행지구 편입된 불법형질변경토지에 대하여는 현실적인 이용상황에 따라 보상해야 한다(부칙 5조, 6조).

Ⅳ. 사안의 경우

1. 인삼밭(田) 부분

농지법 제2조에서 전·답, 과수원을 농지로 정의하고 있으며, 동법 제41조에서 전·답*과수원간의 지목변경을 원칙적으로 허용하고 있다. 또한 국계법 제56조에서는 경작을 위한 토지의 형질변경은 개발행위허가를 받지 아니한다고 규정하고 있다. 따라서 甲이 과수원을 인삼밭으로 토지형질을 변경한 것은 불법형질변경에 해당하지 않으므로, 인삼밭부분은 공부상 지

목에도 불구하고 현황 기준 원칙에 따라 전(田)으로 평가해야 한다.

2. 무허가건축물부지 부분

건축허가를 받지 않은 甲의 3층 건물부지는 무허가건축물부지에 해당하며 1989.1.24. 이후에 건축되었으므로 부칙 5조는 적용되지 않는다. 따라서 무허가건축물부지는 현황 기준 원칙의 예외로서 건축 당시 이용상황인 전(田)을 기준으로 평가해야 한다.

(물음2) (15점)

I. 논점의 정리

무허가건축물의 보상 여부와 토지보상법 제75조, 동법 시행규칙 제33조를 바탕으로 사안 무허가건축물에 대한 보상평가기준을 검토한다.

II. 무허가건축물의 보상 여부

1. 무허가건축물의 의의

무허가건축물이란 「건축법」등 관계법령에 의하여 허가 등을 받고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가 등을 받지 않고 건축 또는 용도변경한 건축물을 말한다.

2. 무허가건축물의 보상 여부

1) 문제점

1989.1.24 이후 무허가건축물의 보상 여부에 대해서는 명문 규정이 없기 때문에, 손실보상 요건 중 허가유무에 따른 재산권 충족 여부가 문제된다.

2) 학설

- ① 위반건축물에 대한 제재와 보상은 별개이므로 무허가건축물도 보상대상이라는 견해,
- ② 토지보상법 제25조 토지보전의무에 비추어 사업인정고시일 전에 건축된 무허가건축물은 보상대상이 된다는 견해, ③ 무허가건축물을 보상한다면 결과적으로 무질서한 건축행위까지 용인하는 결과가 되므로 보상대상이 아니라는 견해가 있다.

3) 판례

사업인정고시 전에 건축한 건축물은 허가여부와 관계 없이 손실보상의 대상이 된다고 판시했다.

4) 검토

허가는 그 성질에 비추어 행위의 적법성 여부에만 관여하고 유효성 여부와는 무관하므로, 무허가건축물은 재산권 요건을 충족한다. 따라서 토지보전의무가 발생하는 사업인정 시점을 기준으로 보상대상 여부를 판단하는 견해가 타당하다.

III. 지장물의 보상평가 기준

1. 토지보상법 제75조

건축물등에 대하여는 이전에 필요한 비용으로 보상해야 한다. 다만, ① 건축물등을 이전하기

어렵거나 그 이전으로 인하여 건축물등을 종래의 목적대로 사용할 수 없게 된 경우, ② 건축물등의 이전비가 그 물건의 가격을 넘는 경우, ③ 사업시행자가 공익사업에 직접 사용할 목적으로 취득하는 경우에는 해당 물건의 가격으로 보상해야 한다.

2. 동법 시행규칙 제33조

건축물에 대하여는 그 구조·이용상태·면적·내구연한·유용성 및 이전가능성 그 밖에 가격형성에 관련되는 제요인을 종합적으로 고려하여 평가한다.

IV. 사안의 경우

1. 농작물(인삼)의 경우

토지 등의 보전의무(동법 제25조)에 따라 사업인정 이전에 식재된 인삼만이 보상대상에 해당한다. 동법 시행규칙 제41조에 따라 인삼을 수확하기 전에 토지를 사용하는 경우에는 농작물의 종류 및 성숙도 등을 종합적으로 고려하여 평가해야 한다.

2. 무허가건축물의 경우

甲의 건물은 사업인정 이전에 건축되었으므로 보상대상에 해당하며, 원칙적으로 이전비로 평가해야 한다. 다만, 동법 제75조 단서에 따라 이전이 어려운 등의 사정이 있는 경우에는 물건의 가격으로 평가해야 한다.

(물음3) (15점)

I. 논점의 정리

甲의 영업이 토지보상법 시행규칙 제45조에 따른 영업손실보상 요건을 충족하는지 여부를 바탕으로 甲 주장의 타당성을 검토한다.

II. 영업손실보상(토지보상법 제77조 제1항)

1. 의의

- ① 영업이란 일정한 장소에서 인적·물적 설비를 갖추고 행하는 일체의 경제활동을 말한다.
- ② 영업손실이란 수용대상이 된 토지·건물 등을 이용하여 영업을 하다가 그 토지등이 수용됨으로 인하여 영업을 할 수 없거나 제한을 받게 됨으로 인하여 생기는 직접적인 손실을 말한다.

2. 성격

영업손실보상은 주로 재산권 보상 중에서 일실손실의 보상이며 구체적 내용에 따라 생활보상의 성격과 간접보상의 성격도 가지고 있다.

3. 요건(토지보상법 시행규칙 제45조)

1) 일반 요건

(1) 1호 요건

- ① 사업인정고시일 등(사업인정고시와 보상계획공고일 중 빠른날) 전부터 ② 적법한 장소(무허가건축물등, 불법형질변경토지 등이 아닌 곳)에서 ③ 인적·물적시설을 갖추고 ④ 계속적으

로 행하고 있는 영업이어야 한다.

(2) 2호 요건

영업을 행함에 있어 관계법령에 의한 허가 등을 필요로 하는 경우에는 사업인정고시일등 전에 허가 등을 받아 그 내용대로 행하고 있는 영업이어야 한다.

2) 무허가건축물등의 임차인 특례(적법한 장소 예외)

무허가건축물등에서 임차인이 영업하는 경우 그 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하고 있는 영업은 손실보상의 대상이 된다(45조 1호 단서).

3) 무허가등의 영업 특례(적법한 영업 예외)

사업인정고시일등 전부터 허가등을 받아야 행할 수 있는 영업을 허가등이 없이 행하여 온 자가 공익사업의 시행으로 인하여 제45조 1호 본문에 따른 적법한 장소에서 영업을 계속할 수 없게 된 경우에는 제45조 제2호에 불구하고 도시근로자 가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구 3개월분 가계지출비에 해당하는 금액을 영업손실에 대한 보상금으로 지급하되, 영업시설등의 이전비용은 별도로 보상한다(동법 시행규칙 52조).

IV. 甲 주장의 타당성

甲의 3층 건물은 무허가건축물에 해당하므로 장소적 적법성이 결여되고, 무허가 영업이므로 영업의 적법성도 결여된다. 또한 임차인이 아닌 소유자에 의한 영업이므로 임차인 특례 보상대상에도 해당되지 않는다. 그리고 장소적 적법성이 결여된 무허가영업이므로 무허가등의 영업 특례 보상대상에도 해당되지 않는다. 따라서 甲의 식당영업은 영업손실보상 대상이 될 수 없고 甲의 주장은 타당하지 않다.

【문제 2】 30점**(물음1) (15점)****I. 논점의 정리**

토지보상법 시행규칙 제26조의 법적 성질과 甲의 소로부지가 사실상 사도에 해당되는지를 바탕으로 피고의 주장을 법적으로 검토한다.

Ⅱ. 시행규칙 제26조의 법적 성질**1. 법규명령의 의의 및 종류**

법규명령이란 법령의 수권에 근거하여 행정권이 정립하는 일반적·추상적 규범으로서 대외적 구속력을 가지는 것을 말한다. 법규명령은 제정 주체에 따라 대통령령인 시행령과 총리령·행정각부령인 시행규칙으로 구분된다.

2. 관련 판례의 검토

판례는 토지보상법 시행규칙 제22조를 행정규칙의 형식이나 상위법령과 결합하여 대외적인 구속력을 가진다고 판시했다.(2011다104253) 생각건대, 법률의 위임에 따라 부령으로 일정 사항을 규정하면, 그러한 부령은 바로 법규명령이 되는 것이므로, 근거 법률 규정과 결합하여 대외적인 구속력을 갖는다고 하는 판례의 태도는 비판의 여지가 있다.

3. 사안의 경우

토지보상법 시행규칙 제26조는 토지보상법 제70조 제6항의 수권에 근거하여 국토교통부장관이 제정한 부령이다. 따라서 동규정은 법규명령으로서 대외적 구속력을 가진다.

Ⅲ. 사실상의 사도**1. 의의 및 평가기준**

사실상의 사도란 「사도법」상 사도 외의 도로로서, ① 도로개설당시의 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도로, ② 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로, ③ 「건축법」 제45조에 따라 건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로, ④ 도로개설당시의 토지소유자가 대지 또는 공장용지 등을 조성하기 위하여 설치한 도로를 말한다(칙 26조 2항). 사실상의 사도는 인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 평가한다(칙 26조 1항 2호).

2. 관련 판례

1) 자기토지 편익을 위해 스스로 설치한 도로의 의미

나머지 부분 토지의 가치가 상승됨으로써 도로부지의 가치를 낮게 평가하더라도 정당보상 원칙에 어긋나지 않는 객관적인 사유가 인정되어야 하며, 이는 도로개설 경위와 목적, 소유 관계, 이용상태, 주위환경, 인접토지의 획지면적 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다고 판시했다.(2011두7007)

2) 타인통행을 제한할 수 없는 도로의 의미

법률상 소유권 또는 사실상으로 통행을 제한할 수 없거나 제한이 곤란해야 하며, 단순히 통행에 제공하여 왔고 소유자가 용인하였다는 사정만으로는 도로로서의 이용이 고착화되었다고 볼 수 없다고 판시했다.(2006두18492)

IV. 피고 주장에 대한 법적 판단

甲의 소로부지는 자신의 과수원 토지의 영농 편익을 위해 스스로 설치한 것이므로, 개설경위와 목적, 이용상태 등을 고려할 때 사실상 사도에 해당한다. 토지보상법 시행규칙 제26조는 법규성이 있으므로 사실상 사도에 해당하는 경우에는 동규정에 따라 인근토지의 1/3 이내로 평가하여 보상해야 한다. 따라서 동규정에 따라 적법하게 평가되었다는 피고의 주장은 법적으로 타당하다.

(물음2) (15점)

I. 논점의 정리

토지보상법 시행규칙 제26조는 법규명령으로서 헌법이나 법률에 위반되지 않아야 한다. 법규명령의 사법적 통제를 바탕으로 甲의 주장을 관찰할 수 있는 법적 수단을 검토한다.

II. 甲의 주장을 관찰할 수 있는 법적 수단

1. 법규명령에 대한 항고소송 가능성

① 법규명령은 구체적 적용이 아니라 추상적 적용이며, 그 자체는 법이지 법의 집행행위가 아니므로 항고소송의 대상이 될 수 없으나, 처분적 법규명령은 그 실질이 처분이므로 예외적으로 항고소송의 대상이 될 수 있다.

② 사안의 규정만으로는 행정청의 별도의 집행행위 없이 국민의 권리·의무를 직접 규율한다고 볼 수 없으므로 동 규정은 처분적 법규명령에 해당하지 않는다. 따라서 항고소송은 甲의 주장을 관찰할 수 있는 법적 수단이 될 수 없다.

2. 구체적 규범통제 가능성

1) 의의(헌법 제107조 제2항)

구체적 규범통제란 구체적인 처분을 소송으로 다투면서 위법성의 근거로, 처분의 근거가 된 법규명령의 위헌·위법을 주장하는 것을 말한다.

2) 주체, 대상, 재판의 전제성

① 주체는 각급 법원이고 대법원은 최종적으로 심사할 권한을 갖는다.

- ② 대상은 명령과 규칙이다. 명령은 행정입법으로서 법규명령을 말하고, 규칙은 국회규칙, 대법원규칙 등을 의미하며 지방자치단체의 조례와 규칙도 포함된다.
- ③ 재판의 전제가 된다는 것은 특정한 사건을 재판할 때 그 사건에 적용되는 명령, 규칙의 위헌·위법 여부가 문제됨을 의미한다.

3) 효력

명령·규칙이 위법하다는 대법원의 판결이 있는 경우에 해당 명령·규칙은 효력을 상실하는 것으로 보는 견해도 있으나, 법원은 구체적인 사건의 심사를 목적으로 하는 것이지 법령의 심사를 목적으로 하지 않으므로 해당 사건에 한하여 적용되지 않는다고 보는 견해가 타당하다. 판례도 명령이 위법하다는 판결이 난 경우 해당 사건에서만 적용이 배제되는 것으로 본다.

4) 사안의 경우

甲은 보상금증액청구소송에서 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 제2호의 위헌을 주장하고 있으므로 재판의 전제성이 인정된다. 따라서 구체적 규범통제는 甲의 주장을 관철할 수 있는 법적 수단이 될 수 있다.

3. 헌법소원 가능성

- ① 명령·규칙이 재판의 전제성이 없는 경우 헌법소원의 대상이 되는지에 대해 대법원은 부정하고 헌법재판소 <법무사법 시행규칙>에 대한 결정례에서 명령·규칙이 그 자체에 의하여 직접 국민의 기본권을 침해하는 경우에는 헌법소원의 대상이 될 수 있다고 본다.
- ② 헌법소원(헌법재판소법 제68조 1항)의 실체적 요건으로 공권력의 행사 또는 불행사, 헌법상 보장된 기본권 침해주장, 기본권 침해의 직접성, 다른 구제절차가 없는 보충성, 권리보호 필요성이 요구된다.
- ③ 생각건대, 사안의 규정 자체에 의하여 甲의 기본권인 재산권을 직접적으로 침해한다고 보기 어려우므로 헌법소원은 甲의 주장을 관철할 수 있는 법적 수단이 될 수 없다.

4. 결론

앞서 살핀 바와 같이 甲의 주장을 관철할 수 있는 법적 수단은 구체적 규범통제이며, 법규명령에 대한 항고소송과 헌법소원은 그 수단이 될 수 없다.

【문제 3】 10점**I. 논점의 정리**

공법상 제한을 받는 토지의 평가에 관한 토지보상법 시행규칙 제23조와 관련 판례를 바탕으로 乙의 소송상 청구가 인용될 수 있는지 검토한다.

II. 공법상 제한을 받는 토지의 평가**1. 의의**

공법상 제한을 받는 토지란 관계 법령에 의해 이용규제나 제한을 받는 토지를 말한다.

2. 평가기준(토지보상법 시행규칙 제23조)

- ① 공법상 제한을 받는 토지에 대하여는 제한받는 상태대로 평가한다. 다만, 그 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가해진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다(1항).
- ② 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다(2항).

III. 관련 판례

- ① 판례는 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않은 것이 특정 공익사업의 시행을 위한 것일 경우 이는 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 제한이라고 보아 용도지역 등의 지정 또는 변경이 이루어진 상태를 상정하여 토지가격을 평가하여야 한다고 판시했다.
- ② 여기에서 특정 공익사업의 시행을 위하여 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않았다고 볼 수 있으려면, 토지가 특정 공익사업에 제공된다는 사정을 배제할 경우 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않은 행위가 계획재량권의 일탈·남용에 해당함이 객관적으로 명백하여야만 한다고 본다(2012두7950).

IV. 계획재량의 통제

행정계획은 근거 법령의 목적에 부합해야 하고, 그 목적 달성에 필요한 수단이어야 하며, 관련된 이익을 정당하게 형량해야 한다. 형량하자는 형량의 해태, 형량의 흠결, 평가의 과오, 오형량이 포함되며, 이러한 형량하자가 있으면 행정계획은 계획재량권을 일탈·남용한 것으로 위법하게 된다.

V. 乙 소송상 청구 인용 가능성

- ① 용도지역 등의 지정 또는 변경행위는 전문적·기술적 판단에 기초하여 행해지는 계획재량에 해당한다. X토지가 해당 공익사업에 제공된다는 사정을 배제하고 보면, 제3종일반주거지역으로 변경되지 않은 행위가 계획재량권의 일탈·남용에 해당함이 객관적으로 명백하다고 단정하기 어렵다. 따라서 乙의 보상금 감액 주장은 타당하며 인용될 것이다.
- ② 다만, 제3종일반주거지역으로 변경하지 않은 것이 계획재량권의 일탈·남용에 해당함이 객관적으로 명백하다면 乙의 소송상 청구는 기각될 것이다.

【문제 4】 10점**I. 개설**

개간이라 저가 이용의 토지를 고가 이용의 토지로 만드는 것 외에 종전 이용가치를 보다 높이는 협의의 개간·매립·간척 기타 모든 토지형질 변경 행위를 말한다. 개간비보상은 잔여지 공사비보상 등과 함께 실비변상적 성격을 갖는다.

II. 개간비 보상**1. 요건****1) 국유지 또는 공유지의 개간**

개간비 보상은 국유지와 공유지의 경우에만 해당한다. 이 제도가 사유지에 대하여 유추적용할 수 있는지 문제된다. 사유지에 대한 개간으로 토지가격이 상승했을 때, 그 당사자 간에 부당이득의 성립이나 배분에 관한 문제는 별론으로 하고 토지는 현실적인 이용상태에 따라 평가하여 보상되어야 하므로, 이와 같은 제도를 사유지에 대하여 적용할 수 있는 명문 규정이 없는 현재로서는 사유지에 유추적용할 수 없는 것으로 보아야 할 것이다.

2) 토지가치의 상승

토지보상법 시행규칙 제27조 제1항에서 '개간'이란 협의의 개간뿐만 아니라 매립 및 간척 등의 광의의 개간을 포함하고 있다. 즉 개간에는 토지가치의 상승을 가져오는 모든 개량행위가 포함된다고 보아야 한다.

3) 적법한 개간

1995년 1월 7일 (구)공특법(공공용지의취득및손실보상에관한특례법)시행규칙 개정일부부터는 불법개간에 대하여는 그 개간비를 보상하지 않으며, 관계 법령에 의하여 적법하게 개간한 경우에만 보상한다. 다만 1995년 1월 7일 당시 공익사업시행지구내 편입된 무허가개간토지에 대하여는 예외적으로 개간비를 보상하도록 하고 있다(토지보상법 시행규칙 부칙 6조).

4) 계속 점유

개간한 자가 개간당시부터 보상당시까지 계속하여 적법하게 당해 토지를 점유하고 있어야 한다. 개간한 자가 사망한 경우에는 그 상속인이 개간한 자가 사망한 때부터 계속하여 적법하게 당해 토지를 점유하고 있는 경우를 포함한다. 따라서 보상 당시 사실상 점유하고 있지 아니한 때에는 원칙적으로 보상대상이 되지 않는다.

2. 개간비 평가 기준

개간비는 지장물과는 별도로 개간에 소요된 비용으로 평가한다. 다만, 보상액은 개간 후의 토지가격에서 개간전의 토지가격을 뺀 금액을 초과하지 못한다(동법 시행규칙 27조 1항).

개간비를 평가함에 있어서는 개간전과 개간후의 토지의 지세·지질·비옥도·이용상황 및 개간의 난이도 등을 종합적으로 고려하여야 한다(동법 시행규칙 제27조 제2항).

III. 개간지에 대한 보상

개간비를 보상하는 경우 취득하는 토지의 보상액은 개간후의 토지가격에서 개간비를 뺀 금액으로 한다(동법 시행규칙 27조 3항). 이는 이중 보상을 방지하기 위한 규정이다.

1기 6주차 예시답안

【문제 1】 40점**(물음 1) 20점****I. 논점의 정리**

이주대책 수립 신청에 대한 거부처분이 사전통지 대상에 해당하는지, 이유제시 흠결로 인한 절차상 하자가 독자적 위법사유가 되는지를 바탕으로 乙의 거부처분이 위법한지를 검토한다.

II. 이주대책 수립 거부의 처분성

① 이주대책 수립에 대한 공권력 행사의 거부이고, ② 그 결과 甲의 이주대책을 받을 수 있는 권리가 제한되었으며, ③ 토지보상법 제78조 제1항에 따라 이주대책 수립을 구할 법규상 신청권이 인정된다. 따라서 乙의 거부는 항고소송의 대상이 되는 처분이다.

III. 거부처분이 사전통지의 대상인지 여부**1. 문제점**

① 행정절차법 제21조 제1항에서는 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에 사전통지를 하도록 규정하고 있다.
② 이에 사전통지의 적용 범위와 관련하여 수익적 행정처분의 신청을 거부하는 것이 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분인지가 문제 된다.

2. 학설

① 수익적 행정처분의 신청만으로는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부여되지 않았으므로, 그 거부는 권익을 제한하는 처분이 아니므로 사전통지가 불필요하다고 보는 <부정설>,
② 신청을 한 당사자는 긍정적인 처분을 기대하므로 그 거부는 기대이익을 제한하는 처분에 해당하여 사전통지가 필요하다고 보는 <긍정설>,
③ 원칙적으로는 부정하나, 인허가에 부가된 갱신기간의 경우는 신청인의 권익이 보호될 필요가 있는 것으로 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

3. 판례

판례는 신청에 따른 처분이 이루어지지 않은 경우에는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부과되어 있지 않으므로 그 거부가 권익을 제한하는 처분에 해당하지 않고 이에 사전통지의 대상이 되지 않는다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.

4. 검토

① 원칙적으로 신청의 거부는 권익제한이 아니라고 판단된다.
② 다만, 인허가 갱신의 경우는 갱신에 의해 종전의 허가효과가 유지되는 바, 갱신신청의 거부는 권익 제한에 해당한다고 볼 수 있으므로 <제한적 긍정설>이 타당하다.

5. 사안의 경우

甲의 이주대책 수립 신청에 대한 거부는 인허가 갱신과 같이 기존의 권익을 제한하는 경우가 아니므로 사전통지의 대상이 아니다.

IV. 이유제시 결여의 위법 여부

1. 이유제시 의의 및 생략 사유(행정절차법 제23조)

이유제시란 행정청이 처분을 할 때 당사자에게 그 근거와 이유를 제시하는 것을 말한다. 다만, ① 신청 내용을 모두 그대로 인정하는 처분인 경우, ② 단순·반복적인 처분 또는 경미한 처분으로서 당사자가 그 이유를 명백히 알 수 있는 경우, ③ 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우에는 이유제시를 생략할 수 있다.

2. 절차상 하자 유무

사안은 행정절차법 제23조에 따른 이유제시의 생략사유에 해당하지 않는다. 따라서 乙은 거부처분을 할 때 이유를 제시해야 하며, 이유제시가 결여된 거부처분에는 절차상 하자가 존재한다.

3. 절차상 하자의 독자적 위법사유

- ① 절차상의 하자가 독자적인 위법사유인지에 대해 긍정설, 부정설, 절충설(기속행위와 재량행위를 구분하는 학설)이 대립한다.
- ② 판례는 재량행위, 기속행위를 구별하지 않고 절차상 하자는 독자적인 위법사유가 될 수 있다고 본다.
- ③ 취소소송 등의 기속력이 절차의 위법을 이유로 하는 경우에도 준용되므로 긍정설이 타당하다.

4. 위법성의 정도

이유제시의 결여는 일반인의 관점에서 외관상 명백하지만, 적법요건의 중대한 위반이라 보기 어려우므로 취소사유에 해당한다.

V. 사안의 해결

사안의 이주대책 수립 거부는 사전통지의 대상이 아니므로, 사전통지가 없었다는 사정만으로 거부처분이 위법해지는 것은 아니다. 그러나 이유를 제시하지 않은 것은 절차상 하자가 있는 위법한 거부처분으로서 취소사유에 해당한다.

(물음 2) 20점

I. 논점의 정리

처분사유 추가·변경의 인정 여부 및 요건을 바탕으로 취소소송 계속 중에 乙이 처분사유를 추가·변경할 수 있는지를 검토한다.

II. 처분사유 추가·변경

1. 의의 및 취지

- ① 처분사유의 추가·변경이란 처분청이 처분을 하면서 제시하지 않은 처분의 사실상·법률상 근거를 행정소송 계속 중에 추가·변경하여 처분의 적법성을 유지하는 것을 말한다.
- ② 처분사유의 추가·변경은 소송경제 및 분쟁의 일회적 해결을 위해 그 취지가 인정되며, 원고의 방어권 보장과 이유제시 제도의 취지를 고려하여 일정한 한계 내에서 이루어진다.

2. 인정 여부(허용 여부)

1) 문제점

행정소송법은 처분사유의 추가·변경에 관한 명문의 규정을 두고 있지 않아 행정소송 계속 중에 처분사유의 추가·변경이 인정될 수 있는지에 대한 견해가 대립한다.

2) 학설

- ① 처분사유의 추가·변경을 거부하여도 행정청은 새로운 사유를 들어 새로운 처분을 할 수 있으므로 분쟁의 일회적 해결과 소송경제 측면에서 추가·변경을 인정하는 <긍정설>,
- ② 처분사유의 추가·변경을 인정하면 처분의 상대방은 예기치 않은 불이익을 받을 수 있으므로 부정하는 <부정설>,
- ③ 소송경제와 원고의 방어권 보장을 조화시켜 제한적으로 허용하여야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

3) 판례

- ① 판례는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있다고 하여 <제한적 긍정설>의 입장을 취한다.
- ② 다만, 처분상대방이 명시적으로 동의한 경우에는 기본적 사실관계의 동일성과 무관하게 허용된다고 보았다.

4) 검토

- ① 처분사유의 추가·변경을 부정하면 당해 처분이 취소되더라도 처분청은 다른 사유를 들어 새로운 재처분을 할 수 있으므로 소송경제 측면에서 타당하지 않다.
- ② 따라서 소송경제와 원고의 방어권을 보장을 조화시켜 당초 처분사유와 기본적 사실관계가 동일한 범위 내에서만 제한적으로 처분사유의 추가·변경을 긍정함이 타당하다.

3. 인정 요건

1) 시간적 범위

- ① 처분 시에 객관적으로 존재했던 사유만이 추가·변경의 대상이 되며(처분시설), ② 처분사유 추가·변경은 사실심 변론종결시까지 해야 한다.

2) 객관적 범위

- ① 추가·변경되는 처분사유는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계에 있어서 동일성이 인정되는 범위 내에서만 가능하다.
- ② 판례는 기본적 사실관계가 동일하다는 것은 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한 것을 말한다고 보았다.
- ③ 또한 판례는 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실을 변경하지 아니하는 범위 내에서 단지 처분의 근거 법령만을 추가·변경하는 것은 새로운 처분사유의 추가라고 볼 수 없다고 보았다.

Ⅲ. 사안의 해결

1. 시간적 범위

乙이 추가·변경하려는 사유는 거부처분 당시에 존재했던 것이며, 사실심(1·2심) 변론종결 전이라면 시간적 범위 요건은 충족된다.

2. 객관적 범위

당초 사유인 이주택지 공급이 불가능하다는 점과 이주정착지로의 이주를 희망하는 가구 수가 10호에 미달한다는 점은, 추가·변경 사유인 계약체결일까지 계속 거주하지 않았다는 점 및 이주를 포기하고 이주정착금을 수령했다는 점과는 구체적 사실에 착안해 볼 때 기초가 되는 사회적 사실관계가 서로 다르다. 따라서 기본적 사실관계의 동일성은 인정되지 않으므로 객관적 범위 요건은 충족되지 않는다.

3. 결론

乙이 추가·변경하려는 사유는 시간적 범위 요건은 충족하지만, 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않아 객관적 범위 요건이 충족되지 않으므로 처분사유를 추가·변경할 수 없다.

【문제 2】 30점

(물음 1) 20점

I. 영업손실보상

1. 의의

- ① 영업이란 일정한 장소에서 인적·물적 설비를 갖추고 행하는 일체의 경제활동을 말한다.
- ② 영업손실이란 수용대상이 된 토지·건물 등을 이용하여 영업을 하다가 그 토지등이 수용됨으로 인하여 영업을 할 수 없거나 제한을 받게 됨으로 인하여 생기는 직접적인 손실을 말한다.

2. 성격

영업손실보상은 주로 재산권 보상 중에서 일실손실의 보상이며 구체적 내용에 따라 생활보상의 성격과 간접보상의 성격도 가지고 있다.

3. 요건

1) 일반 요건

(1) 1호 요건

- ① 사업인정고시일 등(사업인정고시와 보상계획공고일 중 빠른날) 전부터 ② 적법한 장소(무허가건축물등, 불법형질변경토지 등이 아닌 곳)에서 ③ 인적·물적시설을 갖추고 ④ 계속적으로 행하고 있는 영업이어야 한다.

(2) 2호 요건

영업을 행함에 있어 관계법령에 의한 허가 등을 필요로 하는 경우에는 사업인정고시일등 전에 허가 등을 받아 그 내용대로 행하고 있는 영업이어야 한다.

2) 무허가건축물등의 임차인 특례(적법한 장소 예외)

무허가건축물등에서 임차인이 영업하는 경우 그 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하고 있는 영업은 손실보상의 대상이 된다(45조 1호 단서).

3) 무허가등의 영업 특례(적법한 영업 예외)

사업인정고시일등 전부터 허가등을 받아야 할 수 있는 영업을 허가등이 없이 행하여 온 자가 공익사업의 시행으로 인하여 제45조 1호 본문에 따른 적법한 장소에서 영업을 계속할 수 없게 된 경우에는 제45조 제2호에 불구하고 도시근로자 가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구 3개월분 가계지출비에 해당하는 금액을 영업손실에 대한 보상금으로 지급하되, 영업시설등의 이전비용은 별도로 보상한다(동법 시행규칙 52조).

4. 폐업보상과 휴업보상**1) 구별 기준 : 이전가능성**

영업의 폐지와 휴업의 구별기준은 당해 영업을 다른 장소로 이전하는 것이 가능한지 여부에 달려 있다. 이전 가능성 여부는 법령상의 이전 장애사유 유무와 당해 영업의 종류와 특성, 인근 주민들의 이전 반대 등 사실상의 이전 장애사유 유무 등을 종합적으로 판단해야 한다(2002두5498).

2) 폐업보상(토지보상법 시행규칙 제46조)**(1) 폐업보상하는 경우**

① 영업장소 또는 배후지의 특수성으로 인해 다른 장소에 이전해서는 당해 영업을 할 수 없는 경우, ② 다른 장소에서는 당해 영업의 허가등을 받을 수 없는 경우, ③ 도축장 등 악취 등이 심하여 인근주민에게 혐오감을 주는 영업시설로서 다른 장소로 이전하는 것이 현저히 곤란하다고 시장 등이 객관적 사실에 따라 인정한 경우에는 폐업보상 대상이 된다(2항).

(2) 손실보상액

폐업하는 경우의 영업손실은 2년간 영업이익에 영업용 고정자산·원재료·제품·상품 등의 매각 손실액을 더한 금액으로 평가한다(1항).

3) 휴업보상(토지보상법 시행규칙 제47조)**(1) 휴업보상하는 경우**

폐업보상에 해당되지 않는 경우에는 휴업보상 대상이 된다. 손실보상액은 ① 이전보상을 하는 경우(1항), ② 일부편입에 따른 보상을 하는 경우(3항), ③ 임시영업소 설치 보상을 하는 경우(4항)로 구분된다.

(2) 휴업기간

휴업기간은 4개월 이내를 원칙으로 한다. 다만, 당해 공익사업으로 영업을 4개월 이상 금지·제한되어 영업을 할 수 없는 경우, 영업시설 규모나 정밀성 등으로 인해 4개월 이내에 다른 장소로 이전하는 것이 어렵다고 객관적으로 인정되는 경우에는 실제 휴업기간으로 하되, 그 휴업기간은 2년을 초과할 수 없다

(물음 2) 10점**I. 논점의 정리**

토지보상법 시행규칙 제45조와 영업손실보상 대상 여부의 판단 시점에 관한 판례를 바탕으로 甲이 영업보상 대상인지 여부를 검토한다.

II. 토지보상법 시행규칙 제45조 검토

甲은 사업인정고시일 전부터 사업지구 내에서 인적·물적시설을 갖추고 계속적으로 제조 및 판매업을 영위해왔으며, 장소의 적법성 및 영업의 적법성은 문제되지 않으므로 영업손실보상 대상에 해당한다.

III. 관련 판례

공익사업의 시행으로 인한 영업손실 및 지장물 보상의 대상 여부는 사업인정고시일을 기준으로 판단해야 하고, 사업인정고시일 당시 보상대상에 해당한다면 그 후 사업지구 내 다른 토지로 영업장소가 이전되었다고 하더라도 이전된 사유나 이전된 장소에서 별도의 허가 등을 받았는지를 따지지 않고 여전히 손실보상의 대상이 된다고 판시했다(2011두27827).

IV. 결론 : 甲이 영업손실보상 대상인지

토지보상법 시행규칙 제45조 및 판례는 사업인정고시일을 기준으로 영업손실보상 대상 여부를 판단한다. 甲은 사업인정고시일 당시 영업손실보상 요건을 충족하며, 그 이후 임대기간 종료로 인한 영업장소의 이전은 보상대상 여부를 부정할 사유가 될 수 없다. 따라서 甲의 영업은 영업손실보상 대상에 해당한다.

【문제 3】 20점**I. 논점의 정리**

주거이전비 보상청구권의 법적 성질과 주거이전비에 대한 재결 여부를 바탕으로 甲과 乙에게 적합한 소송수단을 검토한다.

II. 주거이전비**1. 의의, 취지, 근거**

- ① 주거이전비란 공익사업지구내 편입되는 주거용 건축물에 실제 거주하고 있는 소유자 및 세입자에 대하여, 가구원 수에 따라 주거이전에 필요한 비용을 보상하는 것을 말한다.
- ② 이는 실비변상적 성격을 가지며 생활보상의 일환으로 국가의 정책적 배려에 의해 마련된 제도이다.
- ③ 소유자는 토지보상법 시행규칙 제54조 제1항에, 세입자는 같은 조 제2항에 근거를 둔다.

2. 주거이전비 보상청구권의 법적 성질

주거이전비는 조기이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 정책적인 목적과 주거이전으로 인하여 특별한 어려움을 겪게 될 세입자들을 대상으로 하는 사회보장적인 차원에서 지급되는 금원의 성격을 가지므로 주거이전비 보상청구권은 <공법상의 권리>에 해당한다.

따라서 그 보상을 둘러싼 쟁송은 민사소송이 아니라 공법상의 법률관계를 대상으로 하는 행정소송에 의하여야 한다(2007다8129).

Ⅲ. 주거이전비 보상청구소송의 형태

1. 관련 판례

주거이전비 보상청구권은 그 요건을 충족하는 경우에 당연히 발생하는 것이므로, 주거이전비 보상청구소송은 행정소송법 제3조 제2호에 규정된 당사자소송에 의하여야 할 것이다.

다만, 세입자의 주거이전비 보상에 관하여 재결이 이루어진 다음 세입자가 보상금의 증감 부분을 다투는 경우에는 공익사업법 제85조 제2항에 규정된 행정소송에 따라, 보상금의 증감 이외의 부분을 다투는 경우에는 같은 조 제1항에 규정된 행정소송에 따라 권리구제를 받을 수 있다고 판시했다(2007다8129).

그리고 이러한 법리는 주거용 건축물의 소유자가 사업시행자를 상대로 이주정착금, 주거이전비 및 이사비의 보상을 구하는 경우에도 그대로 적용된다(2018두55326).

2. 검토

주거이전비 보상청구권은 공법상의 권리에 해당하므로 행정소송에 의해 권리구제를 받을 수 있다. 토지보상법 제78조 제6항, 동법 시행규칙 제54조는 주거이전비에 대한 손실보상을 규정하고 있고, 이에 따라 동법 제34조, 제50조에 따라 재결이 이루어진다.

따라서 재결의 전과 후를 구분하여 재결 전에는 공법상 당사자소송, 재결 후에는 동법 85조 1항, 제2항에 따른 행정소송을 제기하는 것이 타당하다.

Ⅳ. 권리구제에 적합한 소송

1. 甲의 경우

1) 적합한 소송

甲의 주거이전비에 대해 재결을 거쳤으며, 주거이전비의 증액을 청구하고자 하므로 토지보상법 제85조 제2항에 따라 보상금증액청구소송을 제기하는 것이 권리구제에 적합한 소송이다.

2) 보상금증액청구소송에 대한 설명

보상금증액청구소송이란 보상금에 대한 재결에 불복이 있는 경우 보상금의 증액을 청구하는 소송을 말하며 분쟁의 일회적 해결에 취지가 있다. 보상금증액청구소송은 실질적으로 처분등을 다투는 것이나 형식적으로는 처분 등으로 인해 형성된 법률관계를 다투는 것이므로 형식적 당사자 소송이며, 부족한 보상금의 지급을 구하는 확인급부소송의 성격을 가진다.

2. 乙의 경우

1) 적합한 소송

乙은 주거이전비에 대해 재결을 거치지 않았으므로 행정소송법 제3조 제2호에 따라 당사자소송을 제기하는 것이 권리구제에 적합한 소송이다.

2) 공법상 당사자소송에 대한 설명

당사자소송이란 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의

법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송을 말한다.

【문제 4】 10점

I. 논점의 정리

법률유보의 원칙과 'B시 이주민지원규정'의 법적 성질 및 효력을 바탕으로 甲 주장의 타당성을 검토한다.

II. 이주대책대상자 배제 행위의 법적 근거

甲을 이주대책대상자에서 배제하는 행위는 침익적 행정처분에 해당하므로 법률에 근거가 있어야 한다(법률유보의 원칙). 따라서 법률 또는 그 위임을 받은 법규명령 등의 근거가 있어야 한다.

III. 'B시 이주민지원규정'의 법적 성질 및 효력

1. 행정규칙의 의의 및 한계

- ① 행정규칙이란 행정조직 내부에서 행정의 사무처리기준으로서 제정된 일반적·추상적 규범을 말하며 행정조직 내부에서만 효력을 가질 뿐 법규성은 없다.
- ② 행정규칙은 상위법률이나 명령, 행정법 일반원칙에 위배되어서는 안 되며, 대외적 구속력이 없으므로 국민의 권리·의무에 관한 사항을 새로이 규정할 수 없다.

2. 관련 판례

- ① 사업시행자의 이주대책 사항을 정한 예규는 이주대책에 관한 내부 사무처리기준에 불과하고, 대외적으로 국민이나 법원을 기속하는 효력은 없다고 보았고(96누140672),
- ② 피고가 구체적인 이주대책을 수립하면서 법령이 정한 것 이외의 추가적인 요건을 두는 방법으로 법이 정한 이주대책대상자를 배제하는 것은 강행규정인 공익사업법 제78조 제1항, 공익사업법 시행령 제40조 제3항 각호에 반하는 것으로서 허용되지 않는다고 판시했다(2014두43592).

3. 소결

'B시 이주민지원규정'은 훈령의 형식으로서 행정규칙에 해당하므로 법규성이 없어 국민의 권리, 의무에 관한 사항을 규율할 수 없다. 그런데 사안의 규정은 토지보상법 및 그 시행령이 정하고 있는 이주대책대상자 요건 외에 추가적인 요건을 두고 있으므로, 강행규정에 반하는 위법한 행정규칙으로서 무효이다.

IV. 甲 주장의 타당성

'B시 이주민지원규정'은 무효이며, 이주대책대상자 배제 행위는 법률에 근거 없는 침익적 행위로서 법률유보 원칙에 반하여 위법하므로 甲의 주장은 타당하다.

1기 7주차 예시답안

【문제 1】 40점**(물음1) (10점)****I. 개별공시지가의 의의 및 취지**

① 개별공시지가란 시군구청장이 표준지공시지가를 기준으로 산정한 개별토지의 단위면적당 가격을 말한다(부동산공시법 제10조 제1항). ② 이는 세금 및 각종 부담금 등의 산정을 위하여 결정·공시된다.

II. 개별공시지가의 법적 성질**1. 논의의 실익**

개별공시지가의 **법적성질**이 항고소송의 대상이 되는 행정소송법상의 처분인지가 문제된다.

2. 학설**1) 행정행위설**

부동산공시법이 개별공시지가에 대하여 이의신청을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 개별공시지가는 조세 등의 산정기준이 되므로 국민의 구체적인 권리·의무에 직접 영향을 미친다고 본다.

2) 행정규칙설

개별공시지가는 과세처분 등 정책집행을 위해 일반적·추상적 기준을 설정하는 것으로 본다.

3) 행정계획설

개별공시지가는 대내적으로 행정청에 대해서만 법적 의무를 부과하는 구속적 행정계획으로 본다.

4) 사실행위설

개별공시지가는 토지가격의 지침으로 정보제공이라는 사실적 효과를 갖는다고 본다.

3. 판례

대법원은 개별토지가격 결정은 관계법령에 의한 토지초과이득세, 택지초과소유부담금 또는 개발부담금 산정의 기준이 되어 국민의 권리, 의무 내지 법률상 이익에 직접 관계되므로 행정처분이라고 본다.

4. 검토

개별공시지가는 이후 과세처분 등의 직접적 기준이 되어 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치므로, 이를 조기에 다투어 법률관계를 확정하고 법적 안정성을 도모할 필요가 있다. 따라서 개별공시지가의 처분성을 인정하는 행정행위설이 타당하다.

(물음2) (10점)**I. 논점의 정리**

행정심판법 제51조의 재청구 금지와 부동산공시법상 이의신청의 법적 성질을 바탕으로 P가 제기한 이의신청, 행정심판이 적법한지 검토한다.

II. 개별공시지가의 이의신청**1. 의의 및 취지(부동산공시법 제11조)**

이의신청이란 개별공시지가에 이의가 있는 자가 공시일부터 30일 이내에 시장·군수·구청장에게 이의를 신청하는 것을 말한다. 이는 공시지가의 객관성을 확보하여 공신력을 높이는 데 취지가 있다.

2. 법적 성질**1) 행정심판법상 행정심판과 강학상 이의신청의 구별기준****(1) 학설**

① 심판기관기준설은 행정심판은 행정심판위원회, 이의신청은 처분청에 제기한다고 보아 심판기관을 기준으로 구분하는 견해이다. ② 불복절차기준설은 준사법적 절차가 보장되는 것만을 행정심판으로 보고, 그렇지 않은 것은 이의신청으로 보는 견해이다.

(2) 판례

국가유공자법상의 이의신청에 대하여 <이의신청 담당기관인 처분청에서의 동일한 절차라는 점을 염두에 두고 행정심판이 아닌 이의신청>으로 보아 불복절차기준설을 취하고 있는 것으로 보인다.

(3) 검토

헌법 제107조 제3항이 행정심판절차는 사법절차가 준용되어야 한다고 규정하고 있는 점을 비추어 불복절차를 기준으로 양자를 구별하는 것이 타당하다.

2) 소결

① 부동산공시법에서는 이의신청절차를 준사법적 절차로 하는 어떠한 규정도 두고 있지 않으므로 부동산공시법상 이의신청은 행정심판이 아니라고 보는 것이 타당하다.

② 판례도 부동산공시법에 행정심판의 제기를 배제하는 명시적인 규정이 없고, 부동산공시법에 따른 이의신청과 행정심판은 그 절차 및 담당기관에 차이가 있는 점을 고려하여, 행정심판이 아닌 이의신청으로 보았다(2008두19987).

III. 사안의 해결

부동산공시법상 이의신청은 강학상 이의신청이므로 행정심판법 제51조가 적용되지 않는다. 따라서 P가 제기한 이의신청과 행정심판은 모두 적법하다.

(물음3) (20점)**I. 논점의 정리**

행정행위의 하자의 승계를 바탕으로 개별공시지가의 위법을 재산세 부과 취소소송에서 다룰 수 있는지 여부를 검토한다.

II. 관련 행정작용의 법적 성질

① 앞서 살핀 바와 같이 개별공시지가는 항고소송의 대상이 되는 처분이고, ② 재산세 부과는 과세관청이 납세의무자에게 납세의무를 확정·부과하는 금전급부하명으로서 처분이다.

III. 하자의 승계**1. 의의 및 논의배경**

- ① 하자승계란 둘 이상의 행정행위가 연속적으로 이루어지는 경우에 선행행위의 하자를 이유로 후행행위를 다룰 수 있는지에 대한 문제를 말한다.
 ② 이는 법적 안정성의 요청과 국민의 권리구제의 조화의 문제이다.

2. 전제조건

- ① 선행행위와 후행행위가 모두 항고소송의 대상이 되는 처분일 것, ② 선행행위는 취소사유가 존재할 것, ③ 후행행위는 적법할 것, ④ 선행행위는 불가쟁력이 발생할 것이 요구된다.

3. 인정범위(하자승계 해결논의)**1) 학설**

- ① 선행행위와 후행행위가 결합하여 하나의 법적 효과를 완성하는 경우에는 하자의 승계를 인정하는 하자승계론과 ② 선행행위가 후행행위에 대하여 구속력이 미치는 범위(한계)내에 서는 하자의 승계를 부정하는 구속력론이 대립한다.

2) 판례

- ① 원칙적으로 하자승계론에 따라 판단하고 있다.
 ② (ㄱ) 대집행절차상 계고·영장에 의한 통지·대집행의 실행·비용징수의 각 행위, (ㄴ) 강제징수절차상 독촉·압류·매각·청산의 각 행위 사이에는 하자승계를 긍정하였다.
 ③ 반면 (ㄱ)표준지공시지가결정과 개별공시지가결정, (ㄴ)표준지공시지가결정과 조세부과처분, (ㄷ)건물철거명령과 대집행 계고, (ㄹ)사업인정과 수용재결 사이, (ㄴ) 재조사청구 조정결정 통지를 받은 개별공시지가결정과 과세처분 사이에는 하자승계를 부정하였다.
 ④ 다만, (ㄱ)개별통지가 없는 개별공시지가결정과 과세처분, (ㄴ)표준지공시지가결정과 재결(보상금증감청구소송)은 별개의 법적효과를 목적으로 함에도 불구하고, 예측가능성이 없고, 수인한도를 넘는 경우에는 하자승계를 긍정한 바 있다.

3) 검토

- ① 하자승계론은 일정한 기준을 제시하여 객관적이고, 구속력론은 예측 가능성과 수인 가능성을 고려한다는 점에서 구체적 타당성을 기할 수 있으므로 양자 모두 합리성이 인정된다.

② 따라서 하자승계론을 기준으로 예측가능성이 있는지, 수인한도를 넘는지 등의 사정을 종합 고려하여 하자승계 여부를 개별적·구체적으로 판단함에 타당하다.

4. 사안의 경우

1) 전제조건 충족 여부

① 개별공시지가와 재산세 부과는 모두 항고소송의 대상인 처분이고, ② 개별공시지가에 대하여 행정심판재결서를 송달 받은 날부터 90일 이내에 행정소송을 제기하지 않았다면 선행 행위에는 불가쟁력이 발생하며, ③ 특별한 사정이 없는 한 재산세 부과는 적법하고, ④ 선행 행위인 개별공시지가 결정에 취소사유에 해당하는 위법이 존재한다고 본다면 전제조건은 충족한다.

다만, 개별공시지가에 대해 이의신청과 행정심판을 제기하였음에도 그 청구가 받아들여지지 않을 점을 고려하면, 선행행위인 개별공시지가 결정에 취소사유가 없다고 볼 여지가 있다. 이 경우에는 전제조건이 충족되지 않을 수 있다.

2) 인정범위 검토

(1) 관련 판례

개별공시지가 결정에 대하여 한 재조사청구에 따른 조정결정을 통지받고서도 더 이상 다투지 아니한 경우까지 선행처분인 개별공시지가 결정의 불가쟁력이나 구속력이 수인한도를 넘는 가혹한 것이거나 예측불가능하다고 볼 수 없어, 개별공시지가 결정의 위법을 과세처분의 위법사유로 주장할 수 없다고 판시했다(96누6059).

(2) 하나의 법률효과를 목적으로 하는지 여부

개별공시지가는 개별토지의 단위면적당 가격을 결정하는 처분이고, 재산세 부과는 납세의무자에게 납세의무를 확정·부과하는 처분이다. 따라서 양자는 별개의 독립된 처분으로서 하나의 법률효과를 목적으로 하지 않는다.

(3) 예측가능성, 수인한도 검토

p는 세금의 상승 등을 우려하여 개별공시지가에 대해 이의신청과 행정심판까지 제기하였고, 그 재결 통지에 대해 더 이상 불복하지 않았다. 따라서 이를 예측불가능하거나 수인불가능하다고 볼 수 없다.

IV. 사안의 해결

하자승계의 전제조건을 충족한다고 하더라도, 개별공시지가 결정과 재산세 부과는 하나의 법률효과를 목적으로 하지 않고, 예측불가능하거나 수인불가능한 경우가 아니므로 개별공시지가의 위법을 재산세부과처분 취소소송에서 다룰 수 없다.

[문제2] (30점)**(물음1) (20점)****I. 논점의 정리**

국가배상책임의 되는 법령 위반(위법)의 개념을 바탕으로, 적정가격 보다 훨씬 높게 결정, 공시한 S시의 개별공시지가의 결정행위가 국가배상법 제2조상의 위법행위에 해당하는지 검토한다.

Ⅱ. 개별공시지가의 개관**1. 의의, 취지, 법적 성질(부동산공시법 제10조)**

① 개별공시지가란 시장 등이 표준지공시지가를 기준으로 산정한 개별토지의 단위면적당 가격을 말한다. ② 이는 세금 및 각종 부담금 등의 산정에 취지가 있다. ③ 개별공시지가 결정은 과세의 기준이 되는 등 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치므로 행정처분에 해당한다.

2. 공시절차

① 시장 등은 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상은 표준지공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하고, ② 감정평가법인등의 검증을 받고, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 하며, ③ 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 ④ 개별공시지가를 결정, 공시한다

Ⅲ. 국가배상책임**1. 의의**

국가배상이란 공무원의 고의·과실로 인한 위법한 직무행위로 인하여 발생한 손해에 대하여 국가 또는 지방자치단체 등이 배상을 해주는 제도를 말한다.

2. 법적 성질

① 국가배상청구권의 법적 성질에 대해 국가배상책임은 일반불법행위 책임의 한 유형에 불과한 것으로서, 국가배상법을 민법의 특별법으로 보는 <사권설>과 국가배상책임은 공법적 원인에 의해 발생한 것이므로 공권으로 보는 <공권설>이 대립한다.

② 판례는 국가배상법을 민법의 특별법으로 본다.

③ 생각건대, 국가배상책임은 공법적 원인에 의하여 발생한 손해에 대한 전보이므로 국가배상법을 공법으로 보고, 국가배상청구권의 법적 성질은 공권으로 보는 것이 타당하다.

3. 요건(국가배상법 제2조)

① 공무원이 ② 직무를 집행하면서 ③ 고의 또는 과실로 ④ 법령을 위반하여 ⑤ 타인에게 손해를 입혀야 하며 ⑥ 가해행위와 손해사이에 상당인과관계가 있어야 한다.

3. 법령 위반(위법)의 개념**1) 학설**

① 국가배상법상의 위법을 취소소송의 위법과 동일하게 보아 행위 자체의 법령위반으로 파악하는 <협의의 행위위법설>,

- ② 국가배상법상의 위법을 취소소송의 위법보다 넓게 보아 법령 위반 뿐만 아니라 널리 인권존중, 공서양속, 신의성실의 원칙의 위반 등도 포함된다고 보는 <광의의 행위위법설>,
- ③ 행위자체의 위법뿐만 아니라, 피침해이익의 성격과 침해의 정도, 가해행위의 태양 등을 종합 고려하여 행위가 객관적으로 정당성을 결여하였는지 여부로 판단해야 한다고 보는 <상대적 위법성설>,
- ④ 취소소송의 위법성과는 달리 피해의 결과에 따라 위법성을 판단하여, 손해가 수인한도를 넘으면 위법행위가 된다고 보는 <결과불법설> 등이 있다.

2) 판례

- ① 판례는 공무원의 직무집행이 법령이 정한 요건과 절차에 따라 이루어진 것이라면 특별한 사정이 없는 한 법령에 적합한 것이고, 그 과정에서 개인의 권리가 침해된다고 하여 법령적 합성이 곧바로 부정되는 것은 아니라고 하여 결과불법설은 배척하고 행위위법성설에 입각한 판시도 한 바 있으며,
- ② 최근 피침해이익의 종류 및 성질, 침해행위의 태양 및 원인, 손해의 정도 등 제반사정을 종합하여 객관적 정당성을 상실하였는지 여부를 기준으로 판단하여 상대적 위법성설을 따르는 듯한 판례도 있어, 판례의 입장은 명확하지 않다.

3) 소결

- ① 국가배상법이 법치주의의 요청에 따라 법규범을 위반한 직무행위에 의하여 발생한 손해에 대한 국가 등의 배상책임임을 인정하기 위하여 제정되었음을 볼 때, 기본적으로 행위위법설이 타당하다.
- ② 손해전보를 목적으로 하는 국가배상에서 반드시 항고소송의 위법과 동일하게 볼 필요는 없으며, 인권보장의 측면에서 볼 때, 공무원에게 직무상의 일반적 손해방지의무를 인정하는 것이 타당하므로 행위위법설 중에서도 광의의 행위위법설이 타당하다.

VI. 사안의 해결

부동산공시법 제10조는 적정한 개별공시지가가 결정·공시될 수 있도록 산정, 검증, 의견청취, 심의 절차를 규정하고 있으며, 담당 공무원, 검증을 의뢰받은 감정평가법인, 시·군·구 부동산가격공시위원회는 적정한 개별공시지가가 결정·공시되도록 조치할 직무상 의무를 부담한다. S시는 토지 특성이 잘못 정정된 검증지가의 오류를 검토하지 않고 적정가격보다 현저히 높은 가격으로 개별공시지가를 결정·공시한 것은 주의의무위반으로 국가배상법 제2조의 법령위반에 해당한다.

(물음2) (10점)

I. 논점의 정리

개별공시지가제도의 입법목적과 상당인과관계 유무를 바탕으로 S시장의 항변의 타당성을 검토한다.

II. 개별공시지가제도의 입법목적

부동산공시법 제1조에서 이 법은 부동산의 적정한 가격형성과 각종 조세, 부담금 등의 형평

성을 도모하고 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정한다. 따라서 개별공시지가는 각종 조세 및 부담금 부과를 위한 기준으로 사용되는 것을 목적으로 한다.

Ⅲ. 상당인과관계 유무

1. 판단기준

가해행위와 손해 사이에 상당인과관계가 있어야 하는데, <상당인과관계>의 유무는 일반적인 결과 발생의 개연성은 물론 직무상 의무를 부과하는 법령을 비롯한 행동규범의 목적, 가해행위의 양태와 피해의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다

2. 관련 판례

개별공시지가가 토지의 거래 또는 담보제공을 받음에 있어 실제 거래가액 또는 담보가치를 보장한다거나 어떠한 구속력을 미친다고 할 수 없다고 하여 상당인과관계를 부정하였다 (2010다13527)

3. 소결

개별공시지가는 해당 토지의 담보가치 등 사적 부동산 거래의 직접적인 기준으로 사용되는 것을 목적으로 하지 않으므로, S시 담당 공무원의 직무상 행위와 B은행의 손해 사이에는 상당인과관계가 인정되지 않는다.

Ⅳ. S시장 항변의 타당성

사안의 개별공시지가 결정과 B은행의 손해 사이에는 상당인과관계가 인정되지 않으므로 S시장의 항변은 타당하다.

[문제3] (20점)**I. 논점의 정리**

토지가격비준표의 법적 성질 부동산공시법상 개별공시지가 공시절차를 바탕으로 토지가격비준표와 달리 개별공시지가를 결정한 것이 위법하다는 B주장의 타당성을 검토한다.

II. 개별공시지가의 개관**1. 의의, 취지, 법적 성질(부동산공시법 제10조)**

① 개별공시지가란 시장 등이 표준지공시지가를 기준으로 산정한 개별토지의 단위면적당 가격을 말한다. ② 이는 세금 및 각종 부담금 등의 산정에 취지가 있다. ③ 개별공시지가 결정은 과세의 기준이 되는 등 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치므로 행정청분에 해당한다.

2. 공시절차

① 시장 등은 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상은 표준지공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하고, ② 감정평가법인등의 검증을 받고, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 하며, ③ 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 ④ 개별공시지가를 결정, 공시한다.

III. 토지가격비준표**1. 의의 (부동산공시법 제3조 제8항, 제10조 제4항)**

토지가격비준표란 표준지와 개별토지의 지가형성요인을 비교하기 위해 작성된 표준적인 비교표를 말하며, 표준지를 기준으로 개별토지의 지가를 대량으로 산정하기 위함에 취지가 있다.

2. 법적 성질**1) 문제점**

토지가격비준표는 행정규칙의 형식이나, 부동산공시법 제3조 제8항 등에 근거가 되는 법령의 규정이 있는 법령보충적 행정규칙에 해당하므로 그 법적 성질이 문제된다.

2) 학설

- ① 법규명령설은 실질을 중시하는 견해로서 상위법령을 보충·구체화 하는 기능이 있는 훈령·고시 등의 대외적 구속력을 긍정하여 법규명령으로 보는 견해이다.
- ② 행정규칙설은 법규명령 형식은 대통령령·총리령·부령으로 한정되어 있으므로 이러한 형식에 의하지 않은 훈령 등은 행정규칙이라고 보는 견해이다.
- ③ 수권여부기준설은 상위법령의 수권 유무에 따라 구분하는 견해로서, 위임 있다면 법규명령으로 보고 위임이 없는 경우에는 행정규칙으로 본다.
- ④ 규범구체화 행정규칙설은 대외적으로는 법적 구속력을 인정하나, 내부적으로는 상위법령을 구체화하는 규범구체화 행정규칙으로 보는 견해이다.

3) 판례

- ① 행정규칙의 형식으로 제정된 것이라도 상위법령의 위임이 있고, 위임의 한계를 벗어나지 않으며, 상위법령의 내용을 보충하는 기능을 가지는 경우에는 상위법령과 결합하여 대외적인 구속력이 있는 법규명령이라고 보았다.
- ② 토지가격비준표는 법령 보충적인 구실을 하는 법규적 성질을 가지고 있는 것으로 보아야 한다고 판시하여 법규성이 있다고 보았다(96누17103).

4) 검토

- ① 상위법령의 위임이 있는 경우에는 그와 결합하여 법령을 보충하므로 법규성을 인정하는 것이 행정현실상 타당하다고 판단된다.
- ② 따라서 토지가격비준표는 부동산공시법과 결합하여 상위법령을 보충·구체화 하는 기능이 있으므로 법규명령으로 봄이 타당하다.

IV. B주장의 타당성**1. 관련 판례**

개별공시지가가 표준지공시지가와 균형을 유지하지 못할 정도로 현저히 불합리하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 결과적으로 토지가격비준표를 사용하여 산정한 지가와 달리 결정되었거나 감정평가사의 검증의견에 따라 결정되었다는 이유만으로 그 개별공시지가 결정이 위법하다고 볼 수는 없고 판시한 바 있다(2012두15364).

2. 결론

토지가격비준표는 법규성이 있으므로 부동산공시법 제10조 제4항에 따라 지가 산정 단계에서 대외적 구속력이 인정된다. 다만, 개별공시지가는 토지가격비준표를 사용한 지가만으로 결정되는 것이 아니라, 그 이후 검증, 의견청취, 심의를 거쳐 결정·공시되므로, 토지가격비준표의 구속력이 결정·공시된 개별공시지가에까지는 미친다고 볼 수 없다. 따라서 단순히 토지가격비준표와 달리 개별공시지가가 결정되었다는 사정만으로 위법하다 볼 수 없으므로 B주장은 타당하지 않다.

[문제4] (10점)**I. 개설**

부동산가격공시위원회는 부동산가격공시에 관한 사항 등을 심의하기 위한 필수기관으로서, 국토교통부장관 소속의 중앙부동산가격공시위원회와 시장·군수·구청장 소속의 시·군·구 부동산가격공시위원회가 있다.

II. 중앙부동산가격공시위원회 의의, 근거

중앙부동산가격공시위원회는 부동산공시법 제24조에 따라 표준지의 선정 및 관리지침 등의 사항에 대해 심의를 담당하는 기관을 말한다.

III. 법적 성격

중앙부동산가격공시위원회는 일정한 사항을 심의하기 위하여 반드시 설치되어야 하는 필수기관으로서 심의기관의 성격을 가진 합의제 행정기관이다.

IV. 심의사항

표준지, 표준주택, 비주거용 표준부동산에 대한 선정 및 관리지침, 공동주택, 비주거용 집합부동산에 대한 조사 및 산정지침, 위 부동산들의 공시가격 및 이의신청에 관한 사항 등을 심의한다.

V. 위원의 구성 및 의결 방법

- ① 위원장을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성하며, 성별을 고려하여야 한다.
- ② 위원장은 국토교통부 제1차관이 된다. 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

1기 8주차 예시답안

【문제 1】 40점**(물음1) (20점)****I. 논점의 정리**

조합설립인가의 법적 성질을 바탕으로 조합설립행위의 하자를 다투는 쟁송의 형태를 검토한다.

II. 조합설립인가의 법적 성질**1. 문제점**

- ① 특허란 특정인에 대하여 새로운 권리, 능력 또는 포괄적 법률관계를 설정하는 행위를 말하며, 본래부터 있던 자연적 자유가 아닌 새로운 권리 등이므로 <설권행위>라고 부르기도 한다. ② 인가란 행정청이 제3자의 법률행위를 동의로써 보충하여 그 행위의 효력을 완성시키는 행정행위를 말하며, 제3자의 행위를 보충한다는 점에서 보충행위라고도 한다.
- ③ 조합설립인가의 법적성질이 강학상 특허인지 인가인지 문제된다.

2. 학설

- ① 조합설립행위는 기본행위로, 조합설립인가는 이를 보충하는 행위로서 강학상 인가로 보는 견해, ② 조합설립행위는 조합설립인가를 받기 위한 요건으로 보고, 조합설립인가는 정비사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체로서의 지위를 부여하는 강학상 특허로 보는 견해가 있다.

3. 판례**1) 종전 판례**

종전에는 조합설립인가는 조합설립행위를 보충하여 그 법률상 효력을 완성시키는 보충행위라고 하여 인가설을 취했다.

2) 최근 판례

최근에는 입장을 바꾸어 조합설립인가처분을 도시정비법상 재건축사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체로서의 지위를 부여하는 설권적 처분으로 보고, 조합설립행위는 인가처분을 위한 요건 중에 하나라고 판시했다.

4. 검토

도시정비법상 조합설립인가처분은 조합이 정비사업을 시행할 수 있는 권한을 부여하여 행정주체로서의 지위를 설정하는 능력설정행위이므로 강학상 특허로 보는 것이 타당하다.

III. 쟁송의 형태**1. 인가설과 종전 판례의 경우**

조합설립인가처분에는 고유한 하자가 없고 조합설립행위에만 하자가 있다면 민사소송으로 기본행위인 조합설립행위를 다투어야 하며, 기본행위인 조합설립행위의 무효를 주장하면서 조합설립인가처분의 무효확인 또는 취소를 구할 수 없다고 판시하였다.

2. 특허설과 최근 판례의 경우

① 조합설립인가처분은 강학상 특허로서 조합설립동의를 조합설립인가처분을 하는 데 필요한 요건 중 하나에 불과하다. ② 조합설립동의를 하자가 있다면 그 하자는 조합설립인가처분의 위법사유가 되며, 항고소송으로 인가처분을 다투어야 한다. ③ 따라서 조합설립인가처분이 있는 후에 조합설립동의를 하자를 이유로 민사소송을 통해 그 동의를 효력 유무를 다투는 것은 확인의 이익이 없는 부적법한 소에 해당한다고 판시하였다.

3. 결론

조합설립행위는 설립인가(특허)의 성립요건이므로 조합설립행위의 하자를 다투는 쟁송형태는 항고소송이어야 한다. 따라서 甲은 조합설립인가처분을 대상으로 취소소송 또는 무효확인소송을 제기할 수 있다.

(물음2) (20점)

I. 논점의 정리

원처분주의와 재결주의에 대해 살펴보고, 이의재결(인용재결)이 재결 자체의 고유한 위법에 해당하는지 여부를 바탕으로 이의재결에 대해 항고소송을 제기하는 경우 그 소송의 대상이 무엇인지 검토한다.

II. 관련 행정작용의 법적 성질

1. 수용재결 (토지보상법 제34조)

수용재결이란 사업인정고시 후 협의불성립·불능의 경우 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는 수용 또는 사용결정의 최종적 판단절차를 말한다. 이는 공사익의 조화에 취지가 있다. 수용재결은 형성적 행정행위로서 항고소송의 대상인 처분이다.

2. 이의재결 (토지보상법 제84조)

관할토지수용위원회의 위법부당한 재결에 불복이 있는 토지소유자 및 사업시행자가 중앙토지수용위원회에 이의를 신청하는 것으로서 특별법상 행정심판에 해당한다.

III. 원처분주의와 재결주의

1. 의의

① 원처분주의란 원처분과 재결 모두 취소소송의 대상이 될 수 있으나, 원처분의 위법은 원처분취소소송에서만 주장할 수 있고, 재결취소소송에서는 원처분의 위법은 주장할 수 없고, 재결 자체의 고유한 위법만을 주장할 수 있도록 하는 제도를 말한다.

② 재결주의란 원처분에 대해서는 소송을 제기할 수 없고, 재결에 대해서만 소송을 제기할 수 있도록 하되, 재결 자체의 위법뿐만 아니라 원처분의 위법도 재결취소소송에서 주장할 수 있도록 하는 제도를 말한다.

2. 행정소송법 제19조 원처분주의

행정소송법은 취소소송은 처분등을 대상으로 한다. 다만, 재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다고 규정하여 원처분주의를 택하고 있

다.

3. 토지보상법이 원처분주의를 택하는지

1) 토지보상법 제85조 제1항

토지보상법은 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인은 제34조에 따른 재결에 불복할 때에는 재결서를 받은 날부터 90일 이내에, 이의신청을 거쳤을 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날부터 60일 이내에 각각 행정소송을 제기할 수 있다고 규정한다.

2) 소결

① 종래 토지수용법은 <이의신청의 재결에 대하여 불복이 있을 때에는>이라는 표현을 사용하여 재결주의를 채택하고 있었다. ② 그러나 토지보상법은 이와 같은 문구를 삭제하고, <제34조에 따른 재결에 불복할 때>라고 규정하여, 행정소송법상 원칙대로 원처분주의를 명확히 규정하고 있다. ③ 다만, 이의재결 자체의 고유한 위법이 있을 경우에는 중앙토지수용위원회를 상대로 이의재결의 취소를 구할 수 있다.

4. 재결 자체의 고유한 위법의 의미

원처분에는 없고 재결 자체에만 존재하는 위법을 의미하는 것으로 재결 자체의 주체·내용·절차·형식의 위법이 있는 경우를 말한다.

IV. 제3자효 행정행위의 인용재결이 재결 자체의 고유한 위법인지

1. 문제점

인용재결로 비로소 권리가 침해된 자가 인용재결을 다투고자 하는 경우, 인용재결을 제3자의 입장에서 ① 재결 자체의 고유한 위법이 있는 것으로 볼지 ② 원처분으로 볼지 문제된다.

2. 학설

① 제3자효 행정행위에서 인용재결로 권익을 침해당한 자가 인용재결의 당부를 다투는 것은 재결 자체의 고유한 하자를 주장하는 것이라는 견해와(행정소송법 제19조 단서설), ② 해당 인용재결은 형식상으로는 재결이나, 실질적으로는 권익을 침해당한 자에 대한 별도의 새로운 처분이므로 인용재결이 최초의 처분이라는 견해가 있다(행정소송법 제19조 본문설).

3. 판례

① 대법원은 제3자효를 수반하는 행정행위에 대한 행정심판청구에 있어서 그 청구를 인용하는 내용의 재결로 인하여 비로소 권리이익을 침해받게 되는 자는 그 인용재결에 대하여 다투는 필요가 있고, ② 그 인용재결은 원처분과 내용을 달리하는 것이므로 그 인용재결의 취소를 구하는 것은 원처분에는 없는 재결에 고유한 하자를 주장하는 셈이어서 당연히 항고소송의 대상이 된다고 판시하였다.

4. 검토

① 인용재결로 비로소 권익을 침해받게 되는 자는 인용재결을 대상으로 소를 제기할 수 있다. ② 인용재결은 원처분과 내용을 달리하는 것이므로 이는 재결 자체의 고유의 하자를 주장하는 것으로 보는 것이 타당하다.

V. 사안의 해결

Y가 제기한 이의신청을 인용한 재결은 원처분인 수용재결과 내용을 달리하므로, 제3자인 乙 등의 입장에서는 재결 자체의 고유한 위법을 다투는 것이 된다. 따라서 乙등은 중앙토지수용위원회를 피고로 하여 이의재결을 대상으로 항고소송을 제기해야 한다.

[문제2] (30점)**I. 논점의 정리**

징계는 침익적 처분이므로 행정절차법에 따른 사전통지(21조), 의견청취(22조), 처분의 이유 제시(23조)의 절차가 적용된다. 이하에서는 감정평가법 제27조를 위반한 甲에 대한 감정평가법령상의 징계절차를 검토한다.

II. 징계의 개관**1. 의의, 취지, 법적 성질**

① 감정평가사가 감정평가법 제39조의 사유에 해당하는 경우 국토교통부장관이 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 해당 감정평가사를 제재하는 것을 말한다. ② 이는 감정평가사의 관리, 감독에 취지가 있다. ③ 징계는 감정평가사의 권익을 제한하는 침익적 처분이다.

2. 종류

① 자격의 취소, ② 등록의 취소, ③ 2년 이하의 업무정지, ④ 견책이 있다.

III. 징계절차**1. 징계의결 요구**

① 국토교통부장관은 감정평가사에게 징계사유가 있다고 인정되면, 그 증명서류를 갖추어 감정평가관리·징계위원회에 징계의결을 요구해야 한다(동법 시행령 제34조 제1항).
 ② 감정평가사협회는 감정평가사에게 징계사유가 있다고 인정하는 경우, 그 증거서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 징계를 요청할 수 있다(동법 제39조 제3항).
 ③ 징계의결의 요구는 위반사유가 발생한 날부터 5년이 지나면 할 수 없다(동법 제39조 제7항).

2. 의결

① 감정평가관리·징계위원회는 징계의결의 요구를 받으면 지체 없이 징계요구 내용과 징계심의기일을 해당 감정평가사에게 통지해야 한다(동법 시행령 제34조 제2항).
 ② 징계위원회는 징계의결의 요구를 받은 날부터 60일 이내 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 때에는 위원회의 의결로 30일의 범위에서 그 기간을 한 차례만 연장할 수 있다(동법 시행령 제35조).
 ③ 당사자는 징계위원회에 출석하여 구술 또는 서면으로 자기에 유리한 사실을 진술하거나 필요한 증거를 제출할 수 있다(동법 시행령 제41조).
 ④ 감정평가관리·징계위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다(동법 시행령 제42조).

3. 징계

국토교통부장관은 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 징계처분을 한다.

4. 징계사실의 통보

국토교통부장관은 위원회의 의결에 따라 징계를 한 때에는 지체 없이 그 구체적인 사유를 해당 감정평가사, 감정평가법인등 및 협회에 징계의 종류와 사유를 명확히 기재하여 서면으로 알려야 한다(동법 시행령 제36조).

5. 징계의 공고

국토교통부장관은 감정평가사에 대한 징계를 한 때에는 지체 없이 그 구체적인 사유를 해당 감정평가사, 감정평가법인등 및 협회에 각각 알리고, 그 내용을 대통령령으로 정하는 바에 따라 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게시 또는 공고하여야 한다(동법 제39조의2 제1항).

(물음2) (10점)

I. 논점의 정리

처분사유 추가·변경의 인정 여부 및 요건을 바탕으로 취소소송 계속 중에 A가 처분사유를 추가·변경할 수 있는지를 검토한다.

II. 처분사유 추가·변경

1. 의의

처분사유의 추가·변경이란 처분청이 처분을 하면서 제시하지 않은 처분의 사실상·법률상 근거를 행정소송 계속 중에 추가·변경하여 처분의 적법성을 유지하는 것을 말한다.

2. 인정 여부

① 처분사유 추가·변경을 인정하는 견해, 인정하지 않는 견해, 제한적으로 인정하는 견해가 있다. ② 판례는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있다고 하여 <제한적 긍정설>의 입장을 취한다. ③ 소송경제와 원고의 방어권을 보장을 조화시켜 당초 처분사유와 기본적 사실관계가 동일한 범위 내에서만 제한적으로 처분사유의 추가·변경을 인정함이 타당하다.

3. 인정 요건

1) 시간적 범위

① 처분 시에 객관적으로 존재했던 사유만이 추가·변경의 대상이 되며(처분시설), ② 처분사유 추가·변경은 사실심 변론종결시까지 해야 한다.

2) 객관적 범위

① 추가·변경되는 처분사유는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계에 있어서 동일성이 인정되는 범위 내에서만 가능하다.
 ② 판례는 기본적 사실관계가 동일하다는 것은 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한 것을 말한다고 보았다.
 ③ 또한 판례는 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실을 변경하지 아니하는 범위 내에서 단지 처분의 근거 법령만을 추가·변경하는 것은 새로운 처분사유의 추가라고 볼 수 없다고 보았다.

Ⅲ. 사안의 해결

1. 시간적 범위

A가 추가·변경하려는 사유가 징계처분 당시 존재했던 것이며, 사실심(1·2심) 변론종결 전까지 추가·변경이 이루어진다면 시간적 범위 요건은 충족된다.

2. 객관적 범위

당초 처분사유인 자격증을 대여하거나 부당하게 행사했다는 점과 국토교통부장관에게 등록하지 않았다는 점은 행위의 태양 등 구체적 사실에 착안해 볼 때 기초가 되는 사회적 사실관계가 서로 다르다. 따라서 기본적 사실관계의 동일성은 인정되지 않으므로 객관적 범위 요건은 충족되지 않는다.

3. 결론

A가 추가·변경하려는 사유는 시간적 범위 요건은 충족하지만, 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않아 객관적 범위 요건이 충족되지 않으므로 처분사유를 추가·변경할 수 없다.

[문제3] (20점)**I. 논점의 정리**

감정평가법 제27조 위반을 이유로 하는 자격취소가 청문 대상에 해당하는지, 청문 결여로 인한 절차상 하자가 독자적 위법사유가 되는지를 바탕으로 甲에 대한 자격취소처분이 적법한지를 검토한다.

II. 자격취소처분의 법적 성질

자격취소처분은 甲이 감정평가를 수행할 수 있는 권리를 장래를 향하여 소멸시키는 침익적 행정행위로서 강학상 철회에 해당하며, 감정평가법 제39조 제1항 단서에 '~할 수 있다'라고 규정하므로 재량행위이다.

III. 자격취소 시 청문을 실시해야 하는지 여부**1. 청문의 의의**

청문이란 행정청이 어떠한 처분을 하기 전에 당사자등의 의견을 직접 듣고 증거를 조사하는 절차를 말한다(행정절차법 제2조 5호).

2. 문제점

감정평가법 제45조에서는 징계로서 자격취소처분을 받는 경우를 청문 사유로 규정하고 있지 않으므로, 이 경우 청문을 생략할 수 있는지 문제된다.

3. 청문 요건(행정절차법 제22조)

① 다른 법률등에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우, ② 행정청이 필요하다고 인정하는 경우, ③ 인허가 등의 취소, 신분·자격의 박탈, 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소의 처분을 하는 경우 행정청은 청문을 해야 한다.

4. 예외 사유

① 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우, ② 법령등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우, ③ 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우, ④ 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우에는 청문을 하지 않을 수 있다.

5. 사안의 해결

행정절차법 제22조 제1항 제3호는 자격을 박탈하는 처분은 청문을 실시한다고 규정하고 있으며, 이러한 청문제도는 행정처분의 사유에 대하여 당사자에게 변명과 유리한 자료를 제출할 기회를 부여함으로써 위법사유의 시정가능성을 고려하고, 처분의 신중과 적정을 기하려는 데 그 취지가 있다. 본 사안은 감정평가사 자격을 박탈하는 처분이고 예외사유에 해당하지 않으므로 청문을 반드시 실시해야 한다.

IV. 청문 결여의 위법 여부

1. 문제점

청문을 반드시 실시해야 함에도 불구하고 청문을 실시하지 않았으므로 자격취소처분에 절차상 하자가 존재한다. 이러한 절차상 하자가 처분의 독자적 위법사유가 되는지 문제된다.

2. 절차상 하자의 독자적 위법사유

- ① 절차상의 하자가 독자적인 위법사유인지에 대해 긍정설, 부정설, 절충설(기속행위와 재량행위를 구분하는 학설)이 대립한다.
- ② 판례는 재량행위, 기속행위를 구별하지 않고 절차상 하자는 독자적인 위법사유가 될 수 있다고 본다.
- ③ 취소소송 등의 기속력이 절차의 위법을 이유로 하는 경우에도 준용되므로 긍정설이 타당하다.

3. 사안의 해결

청문절차를 결여한 자격취소처분은 절차상 하자로 인하여 위법한 처분이 된다. 청문절차의 결여는 내용상 중대하나 외견상 명백하지 않아 취소사유에 해당한다.

V. 관련문제

1. 문제점

甲의 행위가 감정평가법 제27조의 자격증 대여가 아니라 '부당행사'에 해당하면, 제39조 제1항 단서에 따른 자격취소처분을 할 수 없다.

2. 관련 판례

감정평가사가 자신의 감정평가경력을 부당하게 인정받는 한편, 소속 법인으로 하여금 설립과 존속에 필요한 감정평가사의 인원수만 형식적으로 갖추게 하거나 법원으로부터 감정평가물량을 추가로 배정받을 수 있는 자격을 얻게 할 목적으로 자신의 등록증을 사용한 경우, 자격증 등의 부당행사에 해당한다고 판시했다(2013두11727).

3. 사안의 경우

A법인에서 감정평가사 본연의 업무를 전혀 수행하지 않았고 그 법인의 운영에도 관여하지 않은 행위가 자격증의 부당행사에 해당한다면, 감정평가법 제39조 제1항 단서에서 규정한 자격취소사유에 해당하지 않으므로 자격취소처분은 위법하다.

[문제4] (10점)**I. 감정평가법 제28조 손해배상책임**

감정평가법인등이 감정평가를 하면서 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 하거나 감정평가 서류에 거짓을 기록함으로써 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 감정평가법인등은 그 손해를 배상할 책임이 있다(제1항).

II. 감정평가법 제28조와 민법 제750조의 관계

① 감정평가법 제28조가 민법 제750조의 손해배상책임을 배제하는 특칙이라는 견해와, 특칙이 아니라는 견해가 있다. ② 판례는 감정평가법인등의 부실감정으로 인하여 손해를 입게 된 감정평가의뢰인이나 선의의 제3자는 감정평가법상 손해배상책임과 민법상의 불법행위로 인한 손해배상책임을 함께 물을 수 있다고 판시한 바 있다. ③ 감정평가에 의한 적정가격의 산정이 어려움에도 손해배상책임을 널리 인정하면 평가제도가 위태로울 수 있으므로 특칙으로 봄이 타당하다.

III. 손해배상책임의 성립요건**1. 감정평가를 하면서**

- ① 감정평가는 가치판단작용을 말하며, 단순한 사실조사의 잘못은 그 배상책임이 없다.
- ② 다만, 판례는 임대차 사실관계 조사상 과실을 이유로 배상책임을 인정한바 있다.

2. 고의 또는 과실이 있을 것

① 고의란 부당한 감정평가로 인한 손해의 발생을 인식하는 것을 말하고, ② 과실이란 손해의 발생을 부주의로 인식하지 못하는 것을 말한다. ③ 판례는 감정평가규칙의 기준을 무시하고 자의적인 방법에 의해 토지를 감정평가한 것은 고의·중과실에 의한 부당한 감정평가로 볼 수 있다고 판시했다.

3. 부당한 감정평가를 하였을 것**1) 적정가격과 현저한 차이가 있을 것**

판례는 현저한 차이를 인정함에 있어 1.3배가 유일한 판단기준이 될 수 없고, 부당감정에 이르게 된 감정평가 법인등의 귀책사유를 고려하여 사회통념에 따라 탄력적으로 판단해야 한다고 판시했다.

2) 거짓의 기재

감정평가서에 물건의 내용, 산출근거, 가격에 변화를 일으키는 요인, 평가액 등을 사실과 다르게 거짓으로 기재하는 것을 말한다.

4. 의뢰인 또는 선의의 제3자에게 손해가 발생하였을 것

① 선의의 제3자란 감정내용이 허위 또는 적정가격과 현저한 차이가 있음을 인식하지 못한 것뿐만 아니라, 감정평가서를 감정의뢰 목적 이외에 사용하거나 감정의뢰인 이외의 타인이 사용할 수 없음이 명시되어 있는 경우 그 사용사실까지 인식하지 못한 제3자를 의미한다.

- ② 손해란 재산권적 법익에 대한 불이익을 말한다.

5. 상당 인과관계가 있을 것

- ① 부당한 감정평가와 손해발생 사이에 상당인과관계가 있어야 한다.
② 인과관계란 특정 행위가 없었다면 그 결과가 발생하지 않았다고 볼 수 있는 관계를 말하며 가해행위의 태양, 침해의 정도 등 제반 사정을 종합하여 판단한다.

6. 위법성 요건이 필요한지 여부

- ① 감정평가법 제28조 제1항의 손해배상책임의 요건에 위법성이 명시되어 있지 않아 위법성 요건이 별도로 필요한지가 문제된다.
② 이에 대해서는 (a) 별도로 필요하다는 견해, (b) 고의·과실 속에 포함되어 있다는 견해, (c) 부당한 감정평가의 개념에 속에 포함되어 있다는 견해 등이 있다.
③ 생각건대, 감정평가법 제28조는 민법 제750조의 특칙으로 봄이 타당하다는 점에서 명시적 규정이 없는 위법성의 요건은 별도로 필요하지 않고, 부당한 감정평가의 개념 속에 위법성 요건이 포함되어 있는 것으로 보는 것이 타당하다.